

Contenido

DEBATES

El proyecto de Ley de Gestión de Intereses y sus riesgos para la sociedad civil	3
<i>Pablo Secchi</i>	
Objeción de conciencia y conflicto de intereses	5
<i>Mariela Puga</i>	
La guerra contra el derecho	7
<i>David Dyzenhaus</i>	

ENSAYOS

Autores y libros en derecho: los “big bang” (los que me educaron y cambiaron la forma de pensar)	10
<i>Roberto Gargarella</i>	
Una entrevista con Scanlon (parte 1)	14
<i>Yascha Mounk</i>	
La cárcel “bingo fuel”	19
<i>Ezequiel Kostenwein</i>	
Democracia, excepcionalismo gubernativo y protesta social en Bolivia	20
<i>Mijhail Pavel Pardo Lafuente</i>	
Una entrevista con Scanlon (parte 2)	25
<i>Yascha Mounk</i>	
Por qué la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario es “técnicamente dictatorial”	29
<i>Pedro Caminos</i>	
¿Cómo he de vivir?	32
<i>Gustavo Pereira</i>	
Fundación y refundación	35
<i>Cass Sunstein</i>	
Una ley contra el hacinamiento	42
<i>Gianella Bardazano</i>	
¿Hay lugar para la política en la destitución judicial?	45
<i>Emiliano Vitaliani</i>	
Sueños de restauración o utopía resalista	50
<i>Andrés Sajó</i>	
El fin de un consenso institucional	55
<i>Adrián Federico Ambroggio</i>	

El tortuoso camino de Keiko Fujimori a la presidencia	62
<i>Natalia Sobrevilla Perea</i>	
Cuando el jurado le dice "no" a la ley	66
<i>Catalina Finn · Martín César Giorgi · Morella Riemersma</i>	
Nosotros somos los otros	70
<i>Giuseppe Martinico</i>	
La Corte contra los inmigrantes	75
<i>Irwin Stotzky</i>	

El proyecto de Ley de Gestión de Intereses y sus riesgos para la sociedad civil

por Pablo Secchi

Invocando la transparencia, el proyecto habilita mayores mecanismos de control sobre organizaciones civiles.

2 de junio de 2026

La regulación del lobby es una práctica extendida en democracias consolidadas y puede constituir, en principio, una herramienta legítima de transparencia institucional. El [proyecto de Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses](#), enviado hace días por el Ejecutivo, se presenta exactamente con esa justificación. Sin embargo, el texto tiene problemas estructurales que exceden su objetivo declarado y comprometen el funcionamiento autónomo de la sociedad civil.

Antes de entrar en el análisis, despejemos un malentendido que seguramente surgirá en este debate. Las organizaciones de la sociedad civil presentan anualmente memoria y balance donde constan todos sus ingresos, egresos, donantes -argentinos y extranjeros- y proyectos. La transparencia sobre su financiamiento no es una deuda pendiente: es una obligación que ya se cumple. El proyecto no viene a cubrir ese vacío porque ese vacío no existe.

Problemas de diseño y el alcance del proyecto

El primer problema del proyecto es de diseño. La definición de “gestión de intereses” del artículo 2 incluye prácticamente cualquier forma de incidencia pública: una reunión, una llamada, un correo electrónico a un legislador, un

funcionario o incluso un asesor. En la práctica, casi cualquier acción de una organización de la sociedad civil destinada a influir en una política pública queda alcanzada por el régimen.

La ley no distingue entre lobby corporativo e incidencia ciudadana. Somete a ambos a los mismos mecanismos de control, registro y sanción. Equiparar a una ONG que impulsa una reforma institucional con una empresa que contrata lobistas para obtener beneficios regulatorios es una confusión conceptual con consecuencias políticas graves. Actividades normales en una democracia -reunirse con legisladores, impulsar reformas, participar del debate público- pasan a quedar sujetas a supervisión estatal permanente.

El segundo problema es la obligación de inscripción y el esbozo de una habilitación previa. “La gestión de intereses únicamente podrá ser llevada a cabo por personas humanas o jurídicas habilitadas por la Autoridad de Aplicación en el Registro Público de Gestores de Intereses”. Parecería que, sin una autorización de la Autoridad de Aplicación, ninguna organización puede realizar gestión alguna. Esto convierte un requisito administrativo en una condición de acceso al espacio cívico.

A eso se suma la obligación de reportes trimestrales: con quiénes se reunieron, qué temas

abordaron, sobre qué asuntos buscan incidir, todo bajo declaración jurada. Y si en ese período la organización no realizó ninguna gestión, igual deberá presentar una declaración que certifique esa inactividad. Para organizaciones pequeñas, esta carga es difícil de sostener. Para organizaciones dedicadas al control del Estado -cuya tarea central es justamente reunirse con funcionarios y promover reformas- el efecto es todavía más grave: sus actividades más esenciales quedarían bajo fiscalización permanente del mismo poder que buscan controlar.

Control agravado sobre los fondos de cooperación internacional

El tercer problema -y quizás el de mayor potencial estigmatizador- es el tratamiento específico para organizaciones con financiamiento o vínculos internacionales (artículos 22 a 24). Esto alcanza a una cantidad significativa de organizaciones que trabajan en derechos humanos, transparencia, ambiente o fortalecimiento democrático, donde la cooperación internacional es habitual.

Estas organizaciones quedan sujetas a un régimen de control mucho más exhaustivo: declaraciones especiales, documentación adicional y la posibilidad de que la Autoridad de Aplicación exija reportes extraordinarios invocando razones tan amplias como “seguridad interior” o “interés público debidamente justificado”. En otras palabras, el Estado puede pedir lo que quiera cuando quiera, sin que la ley establezca límites claros. Eso es incompatible con cualquier régimen que incluya sanciones.

Sanciones penales y su efecto disuasorio

El proyecto incorpora penas de entre dos meses y seis años de prisión para quienes realicen

gestiones sin inscripción previa (lo tipifica como “gestión clandestina de intereses” en el art. 39). Convertir un incumplimiento burocrático en delito penal con esas escalas eleva significativamente la presión sobre organizaciones y activistas. El efecto no es solo punitivo, es disuasorio. Frente al riesgo de investigaciones o procesos penales, muchas organizaciones optarán por reducir actividades de incidencia o directamente dejar de interactuar con funcionarios. La autocensura no requiere sanciones efectivas para operar, sino que solo basta con que la amenaza sea creíble.

El derecho comparado ofrece advertencias sobre estas cuestiones. En Rusia, la ley de “agentes extranjeros” fue utilizada para estigmatizar y limitar el trabajo de organizaciones de derechos humanos y medios independientes. En Hungría, una norma similar fue declarada incompatible con los principios de libertad de asociación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En El Salvador, iniciativas como la que se reporta en esta nota fueron denunciadas por organismos internacionales como herramientas de presión contra grupos críticos del gobierno. En todos estos casos aparece el mismo patrón: normas presentadas como instrumentos de transparencia que terminaron ampliando las capacidades estatales de control sobre la sociedad civil.

Transparentar el lobby corporativo es un objetivo legítimo. Pero una regulación que no distingue entre interés comercial e incidencia ciudadana, que exige habilitación estatal previa para reunirse con un legislador, que impone cargas trimestrales sobre organizaciones sin fines de lucro y que criminaliza errores formales no fortalece la democracia. La debilita, justamente en el eslabón que más importa: el de quienes controlan al poder desde afuera. ■

Objeción de conciencia y conflicto de intereses

por Mariela Puga

Sobre las declaraciones del Presidente y la Senadora Patricia Bullrich en relación a la designación como jueza de M.V. Michelli.

5 de junio de 2026

Me duelen los oídos al escuchar a Bullrich repetir *ad nauseam* que se abstiene de votar el pliego de Michelli por “**objeción de conciencia**”... ¿nadie le va a decir nada? Se me nubla la vista y me empiezan los mareos, cuando escucho al presidente argumentar que quiere evitar el “**conflicto de intereses**” que causaría la jueza... Llamen a la ambulancia!!! creo que me dio algo.

A ver, todos y todas sabemos que Bullrich trata de disimular su desacuerdo, y de resaltar la independencia de su voto ¿pero por qué le estamos dejando decir que eso es una “objeción de conciencia”? ¿Así como así?... Ella tiene todo el derecho del mundo a poner lo que hace a su mejor luz, pero algunas instituciones jurídicas son lo que son, y no lo que el espíritu generativo de la IA delire. Sabemos también que Milei trata de revestir de razonabilidad el uso abusivo (y hasta negligente) del poder presidencial, abiertamente dirigido a castigar a la prensa crítica. Y él también tiene derecho a narrar su versión de los hechos en sus propios términos. Pero vamos, ¿le dejamos decir, sin más, que está evitando “conflicto de intereses”? Está usando el discurso jurídico como quien se limpia la boca con las sábanas y los medios repiten el cantito como si fuera la poesía del 25 de mayo. Bueno, tendré que digo algo:

El instituto de objeción de conciencia, baluarte liberal, si los hay, es la permisión para no cumplir la ley estatal en razón de lo que nuestras creencias más íntimas, y moralmente constitutivas, nos indican. Pero la orden que da el jefe de tu partido no es una ley estatal, Patri. Puede ser una prescripción con mucha fuerza normativa sobre sus huestes, pero no es una prescripción

general del estado, no es una norma jurídica. No estamos en una monarquía absoluta, obligados y obligadas a cualquier capricho del presidente como si fuera *the law of land*. De hecho, si lo estuviéramos vos no tendrías ningún derecho a la objeción de conciencia. Te das cuenta Patricia? **Tu enunciado es una contradicción en sus propios términos.**

Y lo del “conflicto de intereses”, ¿en serio? Este tipo de conflictos funciona como una razón jurídica crucial para impugnar una decisión jurisdiccional en un caso concreto. El conflicto es entre intereses en conflicto. La idea es crucial para garantizar la imparcialidad jurisdiccional, otro baluarte del derecho liberal, un monumento, diría yo. Pero el discurso del presidente se limpia los zapatos en este monumento. Obvio que esto tiene que ver con los jueces, Javito, y con cualquier poder de decisión jurisdiccional. Pero lo más obvio es que sólo funciona en un conflicto concreto, o previsible, frente a intereses desnudos. Nadie te avisó que en este caso este es un argumento bumerang. Es una forma de socavar tu propia decisión en relación a la designación de la jueza. Digo, la decisión jurisdiccional es tuya, toda tuya, pero si decís que hay un conflicto de interés entre vos y ella, **estas impugnando la imparcialidad de tu propia decisión.** Te escuchaba y pensaba en Larry, el de los tres chiflados, cuando golpeaba con un martillo que le rebotaba en la cara.

Aún si asumiéramos que el periodista Alconada Mon es un “ensobrado” por los rusos, esos que quieren perjudicar al presidente, la verdad es que no estamos discutiendo si él va a ser juez. ¿Por qué ese supuesto vicio de carácter del perio-

dista afectaría a su cuñada?, ¿no era liberal este presidente? Ni siquiera tienen la misma familia de sangre, como para discutir una buena hipótesis genetista de los vicios de carácter.

Detrás de este aparente error conceptual hay un razonamiento pseudo-fascista: cualquiera que tenga alguna vinculación con la oposición o la prensa crítica tendría un conflicto de interés con el presidente, y no podría ocupar ningún cargo público. ¿Será ésta su concepción de conflicto de intereses? O solo busca destruirnos los oídos alardeando su ignorancia jurídica.

Si rastreamos el origen de la confusión, quizás debamos recordar al Ministro de Desregulación diciendo que la clave estratégica del gobierno era la de “empobrecer a los grupos de interés” de la oposición. Parece plausible que el presidente confundió el concepto jurídico espe-

cífico de “conflicto de intereses”, con el concepto Sturzeneggeriano de castigar “a los grupos de interés.” Esto es fascismo con lenguaje liberal, acá y en la China.

Ahora, digamos todo: puede hacerlo. La potestad constitucional es de él. No está obligado a designarla si no quiere. Pero hubiera sido lindo, y más sano, que nos ahorraran los vilipendios de la lengua del poder...

Y digamos todo también, teniendo en cuenta que en La Plata no hay una sola jueza o camarista mujer (ver [justicia federal de La Plata](#)). Es una de las dos jurisdicciones federales con mas desigualdad de género del país. Justo cuando se va a nombrar una jueza ahí, es la cuñada de.... El vilipendio no es solo de la lengua...

■



La guerra contra el derecho

por David Dyzenhaus

Una crítica al "constitucionalismo del bien común".

26 de junio de 2026

Presentamos un resumen del último libro de David Dyzenhaus: *The War against Law: What's Wrong with Common Good Constitutionalism*.

—

Los juristas de las universidades de élite están arrasando con el Estado de derecho y la democracia, al tiempo que afirman defender ambos. Según ellos, esto se hace en aras del «bien común», que, según afirman, es una versión del pensamiento católico clásico sobre el derecho natural, pero que yo desenmascaro como una ideología iliberal con raíces en el pensamiento autoritario de la década de 1930 de los teóricos políticos y jurídicos fascistas Carl Schmitt y Eric Voegelin. Examino las ideas de estos juristas en un contexto específico, prestando especial atención a un episodio concreto. En el Reino Unido, los juristas del «Judicial Power Project», principalmente John Finnis y Richard Ekins, que mantienen estrechos vínculos con figuras de extrema derecha de Estados Unidos y Europa —como, por ejemplo, Adrian Vermeule, de Harvard—, arremeten contra la «extralimitación judicial». Sin embargo, al analizar detenidamente sus argumentos, se observa que su objetivo es establecer un gobierno por parte de un ejecutivo iliberal. Para demostrarlo, me centro en la Ley de Ruanda de 2024, que exigía la devolución de los solicitantes de asilo a Ruanda. Los debates, tanto previos como posteriores a la ley, permiten dar respuestas concretas a preguntas profundas sobre la naturaleza del Estado de derecho y su papel en una democracia liberal.

Resúmenes de los capítulos

Introducción

Presento al lector la saga de Ruanda, la idea de que se está librando una guerra contra el Estado de derecho y a los dos profesores de Derecho que han liderado la lucha: John Finnis y Richard Ekins. Explico mi enfoque en los debates sobre el Estado de derecho en torno a la Ley de Ruanda, que exigía que los solicitantes de asilo que llegaran al Reino Unido fueran deportados a Ruanda —un país gobernado por un régimen conocido por sus violaciones de los derechos humanos— para que se tramitaran sus solicitudes de estatus de refugiado. Allí permanecerían incluso si sus solicitudes fueran rechazadas.

1: Los defensores constitucionales



Este capítulo vuelve a presentar a los «abogados del bien común» que son las figuras principales del Proyecto del Poder Judicial, John Finnis y Richard Ekins, así como al think tank que acoge el proyecto, Policy Exchange, y esboza cómo dicho proyecto ha operado en colaboración con los gobiernos conservadores para socavar el derecho internacional y el Estado de derecho.

A su vez, dicho proyecto opera en colaboración con el «Proyecto del Bien Común», una alianza entre académicos de derecha de ambos lados del Atlántico, cuyas figuras destacadas están profundamente vinculadas a intelectuales y políticos de extrema derecha de Europa del Este. El capítulo concluye con un análisis de las similitudes entre la ideología de las personas implicadas en estos proyectos y la de los teóricos políticos y jurídicos autoritarios del periodo de Weimar, Carl Schmitt y Eric Voegelin, en el sentido de que su concepción del bien común es mayoritariamente negativa: todo lo que no sea liberalismo.

2: La soberanía parlamentaria y el Estado de derecho

Este capítulo presenta la paradoja de un orden constitucional en el que existe la supremacía parlamentaria: el parlamento puede promulgar cualquier ley que desee, incluida una ley que socave el Estado de derecho de tal manera que socave la propia supremacía parlamentaria. A continuación, esbozo la tensión presente en el análisis clásico de A. V. Dicey sobre los dos «fundamentos constitucionales» de la soberanía parlamentaria y el Estado de derecho. Muestro hasta qué punto esa tensión está arraigada en el common law y cómo los desarrollos de la posguerra en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Ley de Derechos Humanos de 1998 y el entramado institucional del orden constitucional agravan dicha tensión al expresar un compromiso cada vez más firme con los derechos humanos, al tiempo que preservan la soberanía parlamentaria. El capítulo prepara el terreno para el argumento del siguiente capítulo: que la Ley de Ruanda podría ser a la vez perfectamente válida e inconstitucional, en la medida en que introduce una peligrosa incoherencia en el orden constitucional del Reino Unido.

3: Una historia de un universo paralelo

En este capítulo, destaco la forma en que Ekins y sus coautores del Judicial Power Project promocionan políticamente sus publicacio-

nes como telón de fondo del debate sobre el proyecto de ley de Ruanda. A continuación, el capítulo describe la sentencia del Tribunal Supremo que declaró a Ruanda «insegura» y cómo el posterior tratado entre el Reino Unido y Ruanda, junto con el proyecto de ley, lejos de hacer que Ruanda fuera segura desde la perspectiva del derecho de los derechos humanos, hizo que dicho derecho resultara irrelevante. Esto pone de manifiesto que Ekins y sus coautores intentaban defender lo indefendible. Pero lo que realmente llama la atención es que querían que la Ley eliminara las escasas vestigios de control jurisdiccional que conservaba, otorgando así al poder ejecutivo total libertad de acción. También pongo de manifiesto las incoherencias en su enfoque del derecho internacional en sus diferentes intentos por demostrar que infringir el derecho internacional es compatible tanto con el Estado de derecho como con el propio derecho internacional.

4: Herejía contra herejía: el debate sobre el Estado de derecho

Este capítulo se centra en el debate celebrado en la Cámara de los Lores y en el ataque que allí se lanzó contra la adopción por parte del fiscal general Richard Hermer de la definición «amplia» de Estado de derecho de Lord Bingham, en lugar de su definición «restringida», supuestamente apolítica. Sostengo que los principales detractores no pueden sino defender una concepción «amplia» del Estado de derecho que, aunque menos amplia que la de Hermer y Bingham, sigue demostrando que la Ley de Ruanda violó el Estado de derecho. También demuestro que los juristas defensores del «bien común» se basan en una postura positivista jurídica, que excluye los derechos humanos y el derecho internacional del contenido del Estado de derecho, mientras que Hermer y Bingham, siguiendo a Dicey, adoptan una metodología del common law que incluye los derechos humanos y el derecho internacional en el contenido del Estado de derecho.

5: Soberanía, derecho internacional y Estado de derecho

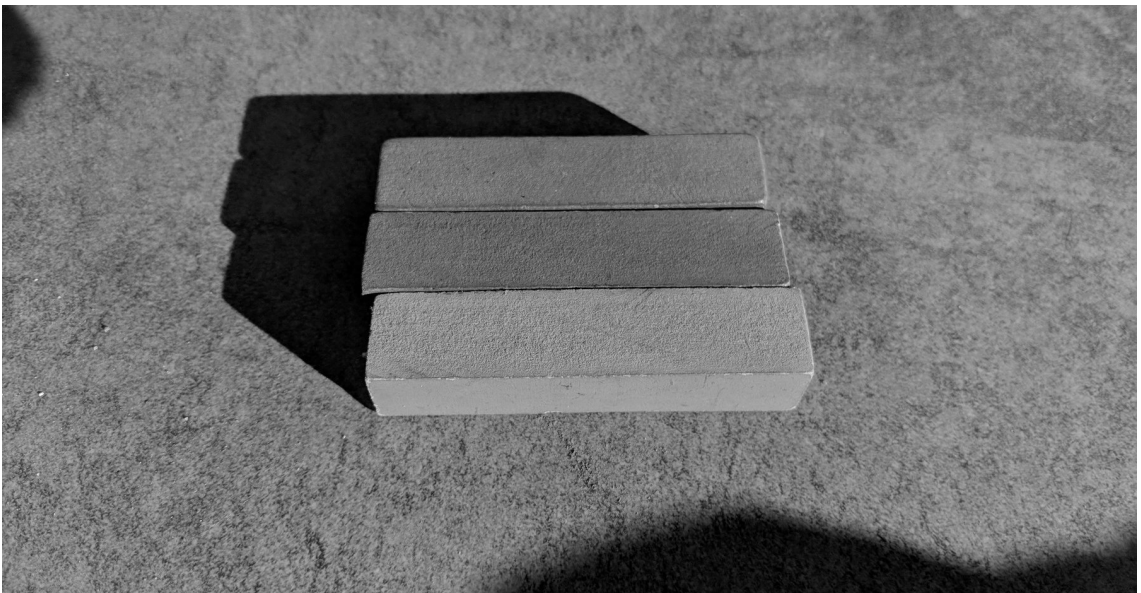
Estado de derecho, soberanía, derecho internacional, positivismo jurídico, esclavitud

Este capítulo expone los argumentos a favor de la concepción del Estado de derecho de Bingham. En primer lugar, expongo las raíces políticas de la concepción «restringida» y positivista del Estado de derecho. En segundo lugar, muestro que los ejemplos en los que se basa la concepción «delgada» —en particular, la esclavitud y el apartheid en Sudáfrica—, cuando se examinan adecuadamente, respaldan la concepción «gruesa» e ilustran la importante conexión entre las dimensiones procesales y sustantivas del Estado de derecho. Esa conexión plantea la cuestión del estatus del derecho internacional y, en tercer lugar, muestro cómo la tradición dualista del Reino Unido no es más que la forma en que este país gestiona su compromiso con el derecho internacional, entendido como parte de su compromiso con el Estado de derecho.

Por último, muestro que la concepción de la soberanía de los juristas del bien común es una soberanía ejecutiva, no parlamentaria.

6: La teología política del universo paralelo

En este capítulo, muestro que el Proyecto del Poder Judicial pretende allanar el camino para el Proyecto del Bien Común, de modo que el ejecutivo pueda «promulgar el bien común» de acuerdo con una interpretación controvertida de la teología católica. Además, la combinación de ambos proyectos hace que los juristas del bien común tengan más en común con el pensamiento de los dos pensadores fascistas alemanes Carl Schmitt y Eric Voegelin que con la teología católica o el derecho natural clásico. Para mi argumento es importante señalar que esta afirmación no se basa únicamente en la constatación de las similitudes entre estas dos figuras y los juristas del bien común. Adrian Vermeule es discípulo de Schmitt, y Finnis ha recibido a lo largo de su carrera la influencia de Voegelin, quien también es una figura destacada de la ideología de derechas en Estados Unidos. ■



Autores y libros en derecho: los “big bang” (los que me educaron y cambiaron la forma de pensar)

por Roberto Gargarella

Roberto Gargarella reconstruye un árbol genealógico de sus lecturas y sus influencias explosivas

2 de junio de 2026

Puesto a pensar sobre una lista de los autores y libros que definieron el modo en que concibo el derecho, comenzaría por una lista de los “big-bang”. Quiero decir, los libros escritos por autores que sacudieron mis cimientos, y que me ayudaron a ver y entender los problemas de un modo diferente -un modo mucho más interesante del que conocía. La lista, quiero aclararlo desde ya, no pretende ser universal sino, como lo anuncié, una que incluye a los autores que me cambiaron y mejoraron a mí. Aclarado esto -el punto de vista muy personal de este reporte- señalo también que, por supuesto, presento estos títulos con la expectativa de que puedan servir a otros, en sus búsquedas. Como mi lista está muy marcada por el derecho anglosajón, cada vez que pueda agregaré, sobre el final, referencias más locales que encontré, de alguna manera, relevantes.

Derechos humanos/Filosofía del derecho. Sin lugar a dudas, el libro que cambió mi modo de entender el derecho -el libro que, finalmente, me cambió la vida- fue *Ética y derechos humanos*, de Carlos Nino. Al leerlo, entendí que era posible pensar al derecho de un modo serio, inteligente, fundado -y no de una manera meramente autoritaria, dogmática, irrazonada, irrazonable, que era la manera en que me había acostumbra-

do hasta entonces la Facultad de Derecho, que comencé a conocer durante la dictadura. Supe que había que dar razones persuasivas, para sostener aquello que uno quería sostener, y que no todas las razones eran igualmente válidas. Por fin, con Nino, encontraba a un autor que concebía al derecho -todo el derecho- a partir de una teoría comprensiva, que incluía una filosofía política (liberal igualitaria), una filosofía del derecho (constructivista), una teoría de la democracia (deliberativa). Por contar con fundamentos semejantes, Nino pudo ingresar luego en las áreas más diversas del derecho, para hablar del derecho de familia, del derecho penal, del derecho procesal, con autoridad, tranquilidad y sentido. No todos sus libros me parecieron excelentes, pero en todo caso destacaría otros muy buenos, como *La Constitución de la democracia deliberativa*, *Fundamentos de Derecho Constitucional*, y *Juicio al mal radical. Introducción al análisis del derecho*, mientras tanto, funciona como una buena puerta de ingreso hacia discusiones que, hasta el momento (y, en parte, todavía), no se daban bien, en la Argentina. En el área, también destacaría los trabajos de otros dos grandes maestros argentinos, a quienes quise mucho: el genial Genaro Carrió, *Notas sobre derecho y lenguaje* -un ejemplo fuera de lo común del razonar claro y

escribir bien; y al gran Ernesto Garzón Valdés. (¿ha habido algún mecenas, formador de gente y propulsor de publicaciones, mejor que él?). Una colección de ensayos como la que le publicaran, sobre *Derecho, Ética y Política*, valen mucho la pena como aproximación, comprometida y seria, a los principales problemas jurídicos de nuestro tiempo.

Derecho constitucional/ Derecho administrativo. Fui a hacer mi doctorado en la Universidad de Chicago por dos razones: por el grupo de “marxistas analíticos” que se encontraban en el Departamento de Ciencias Políticas (Jon Elster, Adam Przeworski, principalmente), y por Cass Sunstein, que enseñaba Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho Leí, antes de viajar a los Estados Unidos, y tratando de entrenarme un poco frente a la revolución a la que iba a enfrentarme, un libro que Cass acababa de publicar, sobre Derecho Administrativo: *After the Rights Revolution* -un texto que me pareció, en su momento, complejo (muy cargado de jurisprudencia norteamericana, que desconocía) y muy bueno. Sin embargo, fue otro libro que él presentaría poco después, *The Partial Constitution*, el que me abriría la cabeza en el área, y el que me invitaría a pensar el derecho constitucional con un ojo en la historia, y el otro en la filosofía. En esa época (que no duró mucho) Cass Sunstein era Rawlsiano (y yo conocía bien ese libro extraordinario que es *A Theory of Justice*), y Madisoniano a la vez (y yo estaba muy marcado por un libro que había robado en el Instituto Gioja, en mi juventud, y que devolvería 30 años después -*The Federalist Papers*). Don Cass escribió muchísimos libros, desde entonces. Algunos me interesaron mucho (como *A Second Bill of Rights*), pero fueron aquellos libros y artículos de los 90 los que más me impactaron. Otro libro “big bang” que mencionaría, en el área, fue el que editara Jon Elster junto con Rune Slagstad, *Constitutionalism and Democracy* -una compilación de autores extraordinarios, como fue su característica (un gran seleccionador). Elster (en parte, como Adam Przeworski) fue otro autor “big bang”, pa-

ra mí, y muchos de sus libros (*Ulysses and the Sirens*; *Sour grapes*, *Ulysses Unbound*) y artículos (“Arguing and Bargaining”) me ayudaron muchísimo. Hablando desde la Argentina, podría decir que los tempranos aportes de los entonces jovencísimos Christian Curtis y Víctor Abramovich, en textos como *Los derechos sociales como derechos exigibles* (entre otros de ambos y cada uno) destacaron, desde su aparición, por su calidad e interés inusual: agua en el desierto argentino. El amigo Gerardo Pisarello también escribió al menos un libro de constitucional que me gustó mucho - *Un largo termidor. Historia y crítica del constitucionalismo antidemocrático*. Puedo mencionar, por otra parte, que cuando estudiaba derecho, leí con agrado a Miguel Marienhoff, y su *Tratado de Derecho Administrativo*.

Historia del derecho. Durante mi doctorado en Chicago le tomé el gusto a escribir derecho con atención a la historia. Y esa historia fue, primero, la del derecho norteamericano, por lo cual -como anticipara- los *Federalist Papers* ocuparon un lugar importantísimo en ese tiempo, y desde entonces. La claridad con que Madison y Hamilton pensaban el derecho me resultaron excepcionales, dejándome una gran enseñanza: se puede escribir de manera profunda, aguda y clarísima, y quien no lo hace, y escribe de manera oscura y rebuscada, es porque quiere (o porque necesita ocultar algo, posiblemente lo que no sabe). En ese entonces, y para ese propósito (entender mejor a los federalistas) el libro *Philosophy, The Federalist and the Constitution*, de Morton White, me sirvió mucho. De ese tiempo destacaría otro libro “big bang”, *The Creation of the American Republic*, un texto increíble de Gordon Wood. Sólo años después empezaría un recorrido similar al que había elegido hacer entonces, sobre los Estados Unidos y su tiempo fundacional, para estudiar la historia del derecho constitucional argentino y latinoamericano. En ese tránsito, el libro *Bases*, de Alberdi, me resultó excepcional, otro caso maestro de cómo escribir bien, profundo y claro (¿cómo pudo, Alberdi, escribir sobre derecho comparado, tan detalladamente, con tanto

conocimiento, en una época sin grandes bibliotecas, sin internet?). Si tuviera que agregar un texto decisivo para adentrarme en el particular estudio del derecho latinoamericano (un día escribiré los que me influyeron en el área) mencionaría a (no un libro, sino, por única vez aquí, un artículo): “Politics, Ideology and Society in Post-Independence Spanish America,” de Frank Safford, que aparece en *The Cambridge History of Latin America*.

Derecho penal/Teoría del castigo. En esta área también tuve la suerte de cruzarme con algún autor “big bang,” como lo fue Antony Duff, con quien pude trabar, asimismo, una relación muy cordial. Muchos textos de él, pero sobre todo su libro *Punishment, Communication and Community*, me parecieron fuera de serie: otro hallazgo muy iluminador. Una vez más -lo que reafirma la manera en que prefiero acercarme al derecho- en este escrito de Duff encontré un estudio completo y profundo -una teoría- que se animaba (y nos animaba) a pensar el derecho penal de una manera interdisciplinaria, y con un enfoque atento a la teoría democrática (comunicativa, habermasiana) y a la filosofía política (Rawlsiana). Recopilamos algunos muy buenos textos de Duff, también, en el libro *Sobre el castigo*, que publicamos desde la colección que dirijo en Siglo XXI. En el rubro, mencionaría otro libro que me sacudió mucho, que fue el que escribieran un penalista republicano, John Braithwaite, y un gran filósofo político, adalid del republicanismo, como Philip Pettit: *Not Just Deserts: A Republican Theory of Criminal Law* (que también traducimos al castellano). El libro vale mucho la pena, ayuda mucho a pensar. En la Argentina, había leído con algún interés a Sebastián Soler, y su *Derecho penal Argentino*, y a Raúl Zaffaroni (et al), con su *Derecho penal, parte general*. De todos modos, y sin desmerecer a nadie -lo de Duff (o lo de Pettit), en comparación, me parecen, simplemente, otros mundos: distintos y mucho mejores. En esta línea, en todo caso, agregaría a una autora improbable en el área, Aída Kemelmajer, cuyo libro *Justicia Restaurativa* la muestra en su

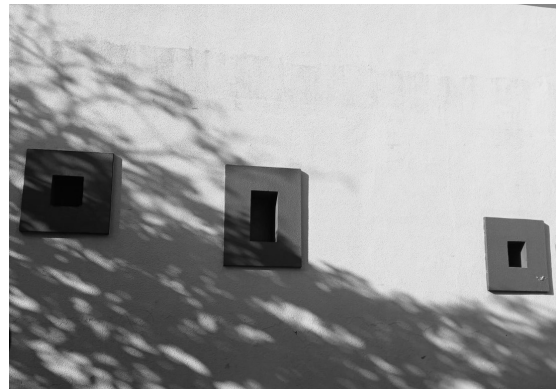
mayor forma: culta, interesada, abierta a pensar diferente. Y, como anunciara, el libro autobiográfico de Nino, *Radical Evil on Trial*, sobre su vínculo con el Juicio a las Juntas, también me parece interesantísimo.

Derecho procesal. Owen Fiss es muchas cosas, y también un gran profesor de Derecho Procesal. Lo coloco, por tanto, en este apartado, aunque podría referirme a él para hablar de derecho constitucional o, sobre algunos temas constitucionales particulares, como la libertad de expresión. Menciono a Fiss, en este caso, como otro autor “big bang” en mi vida: alguien que me conmovió y conmueve profundamente, en su aproximación al derecho. Lo cual, en áreas como ésta -el derecho procesal- puede resultar insólito: ¿cómo puede haber textos que lo conmuevan a uno, en materias como las vinculadas con el derecho procesal? Y sin embargo...es posible. Fiss (como dice muy bien Gustavo Arballo, en su [selección de libros](#), con la que coincidí muchísimo) es alguien que cree en el derecho, alguien que está convencido de que el derecho puede cambiar y mejorar a la sociedad, y alguien que predicó toda la vida (porque es un predicador) sobre el deber de trabajar para esa transformación. Así, por tanto, *The Law as it Could be*, el derecho como podría ser, y como debería ser. En todo caso, cualquier libro, y cualquier escrito de él, muestra las mismas cualidades excepcionales (*El derecho como razón pública, Estructura social y libertad de expresión*). Fiss hace y piensa el derecho para cambiar el mundo, y si no se hace así -así lo asume, con razón- no tiene sentido decir nada. En la Argentina, el trabajo del amigo, procesalista, Alberto Binder (por citar alguno de sus libros, su inacabable *Tratado de derecho procesal penal*) tiene alguna conexión con el de Fiss, más allá de las distancias infinitas en sus enfoques: ambos piensan el derecho con convicción, y con voluntad de buscar un mundo más justo.

Judicial review/Interpretación del derecho. Abro un espacio aparte para esta área amplia y específica, dado que ha sido demasiado importante -tal vez la más importante- en mi trayec-

toria académica (me doctoré primero, en la Argentina, con una tesis sobre el “carácter contramayoritario” del poder judicial, y desde entonces trabajé toda la vida sobre temas relacionados con la cuestión). Aquí también me encontré con autores y libros (no sé si decir “big bang”, pero que me marcaron muchísimo). Pienso, en particular, en tres autores/libros. Primero, John Ely, y su *Democracy and Distrust* (un libro de interés relativo, pero con una idea/enfoque -la teoría procedimentalista sobre el control judicial- que lograría cambiar el estado de cosas vigentes en el área, desde su publicación (el mismísimo Jurgen Habermas -otro autor “big bang,” como Rawls, sobre quienes aquí no me detengo- se apoyaría mucho en la visión procedimentalista de Ely para su extraordinario estudio, de ambición jurídica, *Between Facts and Norms*). Luego (en orden temporal, no ordinal), mencionaría a Jeremy Waldron y su *Law and Disagreement* (una colección de ensayos excepcionales, que lo colocarían como el mejor crítico del control de constitucionalidad), y también Mark Tushnet y libros como *Taking the Constitution Away from the Courts* (uno de los múltiples aportes críticos sobre la teoría del control de constitucionalidad, de un autor con saludable e inusual vocación comparativa). Como addenda, podría mencionar también a Bruce Ackerman y su trabajo *We the People* (un libro que incluye una única -diríase- grandísima idea, sobre cómo conciliar democracia y constitucionalismo); y a Roberto Mangabeira Unger, el más sólido de los *Critical Legal Studies*, con varios libros de interés para acercarse al derecho desde la izquierda (pienso, por caso, en su *What Should Legal Analysis Become?*). Dicho esto, agregaría que de nadie aprendí tanto

sobre interpretación del derecho como con Ronald Dworkin -otro autor “big bang”. Sin coincidir en todo con Ronnie, creo que pocos piensan tan agudamente como él, y por eso varios de sus libros (que son, a su vez, compilaciones de textos) resultan (me resultan) fabulosos. De ellos, el que más me gusta, y que tradujimos para Siglo XXI, fue *A Matter of Principle*. Allí, Dworkin, desde una cosmovisión teórica bien fundada, nos muestra que puede y merece hablarse de todos los temas de relevancia pública, con propiedad, justificadamente: desde la justificación de las acciones afirmativas al derecho a la desobediencia; desde el aborto a la interpretación constitucional (su texto sobre “el derecho como literatura”!! su polémica anti-originalista contra Antonin Scalia!!), etc.. El liberalismo más decente (el liberalismo igualitario) ha tenido la extraordinaria fortuna de que apareciera un genio (literalmente, un genio) como él: pensemos o no como Dworkin, es fabuloso haberlo tenido entre nosotros.



—
N, de la R.: Véase, del autor, [Diez textos que marcaron mis estudios de sociología](#), publicado en enero de 2026. ■



Una entrevista con Scanlon (parte 1)

por Yascha Mounk

Recuperamos y traducimos una vieja, y notable, entrevista sobre el castigo y sus justificaciones.

5 de junio de 2026

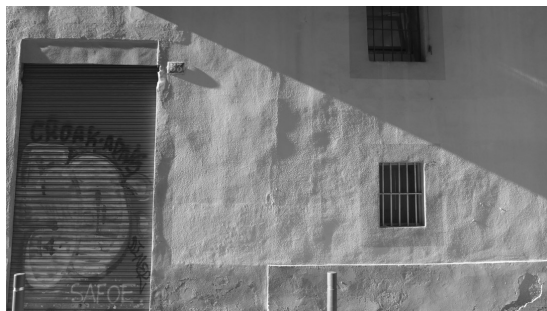
T. M. Scanlon es uno de los filósofos morales en activo más prestigiosos de la actualidad. Además de su obra maestra, *What We Owe to Each Other*, ha escrito tratados revolucionarios sobre temas que van desde la importancia de la elección hasta la naturaleza de la permisibilidad, el significado y la culpa.

Es natural esperar cierta pomposidad de los filósofos, quizá especialmente de los filósofos morales. La talla de Scanlon —y esas iniciales anticuadas e impersonales que utiliza en sus publicaciones— lo convierten en un blanco especialmente prometedor para tales sospechas. Pero los lectores de sus obras se desengañan rápidamente de tales expectativas. Su prosa es elegante, directa y accesible. A veces, es fácil pasar por alto la verdadera importancia de lo que dice, ya que expone con tanta calma incluso sus conclusiones de mayor alcance.

Para sus colegas y alumnos de Harvard, T. M. Scanlon es, en cualquier caso, simplemente Tim: siempre amable, siempre jovial, es un hombre alto y desgarbado de unos setenta años, con cara alargada y manos enormes. Hay algo claramente campechano en él. En seminarios y conferencias, su cautivadora sencillez hace que su explicación del origen de nuestra preocupación moral —no un austero imperativo categórico, argumenta, sino un deseo profundamente humano de establecer relaciones de reconocimiento mutuo entre nosotros— resulte aún más razonable. La visión de un mundo en el que, como Tim, cada agente moral se preocupa sin pretensiones por hacer lo correcto por sus semejantes suena realmente muy atractiva.

Nos reunimos para esta entrevista la mañana del 19 de febrero de 2012, un domingo, en las es-

caleras del departamento de filosofía donde Tim fue estudiante de posgrado y ahora es miembro del cuerpo docente. Al entrar en el edificio, nos cruzamos con decenas de estudiantes con trajes que les quedan mal y que deambulan nerviosamente por el Emerson Hall. Él otea el pasillo con irritación antes de darse cuenta de que el departamento de filosofía se ha reconvertido en sede de un torneo de debate durante el fin de semana. Tim, con su risa estruendosa y pícara resonando por toda la escalera, dice que desapruueba a estos aspirantes a sofistas: en lugar de sumar puntos unos contra otros, deberían, me dice, usar su inteligencia para cuestionar sus propias creencias.



Por fin llegamos a la espaciosa oficina de Tim, en la tercera planta, y nos acomodamos en una larga mesa al fondo de la sala. Hablamos hasta bien entrada la tarde, con vistas al Harvard Yard mientras un día sombrío se desvanece rápidamente. Durante todo ese tiempo, nos observan los felices ciudadanos de Siena que aparecen en una reproducción de la *Allegoría del Buon Governo* de Ambrogio Lorenzetti.

El libre albedrío, el castigo y el significado de la elección

— *The Utopian: Una de las preocupaciones más antiguas de la filosofía es el determinismo causal: el temor de que, si lo que hacemos y pensamos está determinado por procesos físicos que escapan a nuestro control, entonces deberíamos abandonar categorías morales como el elogio, la culpa y la elección. Pero, ¿sintiendo que eso le preocupa menos que a muchos de sus colegas?*

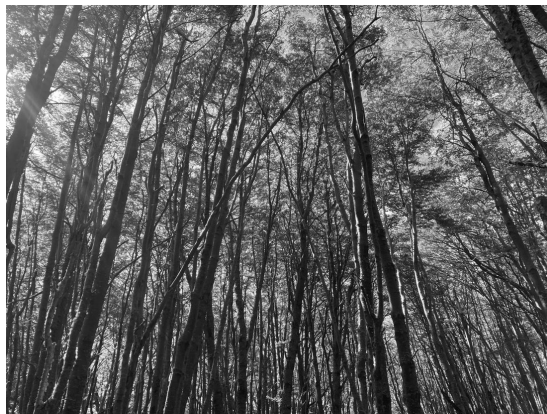
— *Tim Scanlon:* Creo que hay tres formas en las que surge este problema —siendo el problema la posibilidad de que una explicación causal de una reacción que damos socave su significado de una forma u otra.

La más comúnmente discutida es el problema de la llamada responsabilidad moral: el hecho de que haya una explicación física o causal de cómo somos socavaría la idoneidad de las evaluaciones morales —de la culpa, en particular. La segunda, la versión más política, es el hecho de que si nuestras elecciones estuvieran causadas por factores externos a nosotros, sobre los que no tenemos control, eso las socavaría como factores que pueden legitimar los resultados. El hecho de que haya consentido algo no podría implicar que no pueda objetarlo. O el hecho de que haya firmado un contrato no significaría que tenga que cumplirlo. Y el tercero, lo que yo llamo el problema personal del libre albedrío, es que las explicaciones causales socavarían la importancia para mí. Mi sentido de la propiedad, o lo que sea —que yo soy la persona representada, en lugar de que estas sean simplemente cosas que sucedieron por razones que no tienen nada que ver conmigo.

Y creo que estos tres problemas —lo que denomino el problema moral, el problema político (aunque no es exclusivamente político, pero lo expresaré así) y el problema personal— presentan grados de dificultad crecientes a medida que se desciende en la lista.

Creo que el problema moral, que probablemente ha recibido mayor atención, es el menos

problemático, al menos en lo que respecta a la culpa moral y otras actitudes o reacciones, sean cuales sean. Porque ahí creo que lo que estamos haciendo es reaccionar ante la forma de ser de la persona. La persona se define por su psicología. En esto David Hume tenía razón. Los factores que hacen que una acción no revele mi psicología real socavan la responsabilidad porque en realidad no soy así. Estimular mi cerebro para que diga algo que nunca habría dicho significa que eso no refleja nada de cómo me siento hacia ti. Tales factores socavan lo que podemos llamar la libertad de la espontaneidad. Pero el hecho de que haya alguna explicación de por qué soy como soy no cambia, en general, el hecho de que sea así.



— *Así que podemos juzgar a las personas por ser de una manera determinada, incluso si no está bajo su control que, de hecho, sean así...*

— Sí, son así.

Ahora bien, el grado en que eso es cierto depende, por supuesto, del tipo de respuesta que implique la culpa. Si la culpa es puramente evaluativa, si solo implica juzgarme como una persona buena o mala, entonces la conclusión que acabo de mencionar se deduce inmediatamente. Eso es esencialmente lo que ocurría en el tratado de Hume. Tenía en mente una idea esencialmente evaluativa, un sentimiento de aprobación o desaprobación hacia ese tipo de carácter.

Creo que hay mucha —no quiero llamarlo confusión— mucha incertidumbre y falta de claridad en cuanto a lo que implica la culpa si no

es puramente evaluativa. Como he dicho, creo que los dos polos entre los que oscila esta idea de la culpa son, por un lado, una evaluación y, por otro, algún tipo de castigo o sanción. Pero siempre resulta algo confuso qué es esa sanción.

En cualquier caso, creo que la idea de la sanción no es una interpretación muy buena de la culpa: cuando culpamos a alguien, no actuamos como ejecutores. Pero también creo que la idea evaluativa de la culpa es demasiado superficial y débil. Debemos estar haciendo algo más que eso. De lo contrario, la idea de que existe un problema porque lo que hacemos no está bajo nuestro control no parecería un problema, salvo en el sentido humeano.

Así que he intentado en el último capítulo de mi libro *Moral Dimensions* decir: ¿qué más podría haber en este ámbito que sea culpa? Ahora bien, quiero destacar que elegí conscientemente no abordar el problema exactamente de esa forma. Es decir, no lo hacía como una respuesta al problema del libre albedrío, por así decirlo. Quería investigar lo que realmente pienso sobre la culpa y lo que estamos haciendo.

Una vez que tienes una idea de lo que estás haciendo cuando culpamos a alguien, entonces puedes abordar la pregunta: vale, ¿qué tiene que darse para que eso sea apropiado? Si es más que tu evaluación, entonces no basta con que se base simplemente en una descripción precisa de la psicología de la persona. Pero dependiendo de cuál sea el contenido adicional que se contemple, obtendremos respuestas diferentes.

Y yo propongo esta idea basada en las relaciones: culpar a alguien es decidir que lo que ha hecho perjudica tu relación con él de una manera que justifica que cambies tus intenciones sobre cómo vas a comportarte con él y cómo vas a entender tu relación con esa persona. Ahora bien, a mucha gente no le gusta ese punto de vista, en particular porque no creen que le dé suficiente peso a las emociones morales. Esa ha sido una de las principales críticas que se le han hecho. Pero, en cualquier caso, está pensada para ocupar ese espacio.

Si se da esa explicación de lo que implica la culpa, además de una cuestión de evaluación, entonces surge una cuestión moral de primer orden sobre cualquier forma concreta de revisar mis intenciones respecto a cómo voy a comportarme con esa persona. Es una cuestión moral de primer orden si eso está justificado, dado cómo es esa persona. Y puede que el problema del libre albedrío salga a la luz en ese punto, porque puede ser que, con algunas formas particularmente desagradables de decidir cómo voy a tratar a esta persona, estas no sean admisibles a menos que la persona haya tenido la oportunidad de evitar entrar en conflicto con mi decisión de tratarla de esa manera. Pero creo que, tal y como interpreto la culpa, esa cuestión de primer orden no surge. Es una cuestión, como digo, de puro merecimiento: que el simple hecho de que una persona sea así puede justificar que retire mis intenciones de convertirme en su amigo, de confiar en él para participar en actividades cooperativas, de ayudarle de ciertas maneras, de preocuparme mucho por lo que le suceda, y así sucesivamente.

— *Así que parte de la razón por la que el problema del libre albedrío no surge en el caso de la culpa es que la carga impuesta a otras personas no es tan pesada. Pero, ¿qué pasa con los casos en los que la carga es pesada, como en el castigo, por ejemplo?*

— Exacto. El castigo es mucho más duro. El castigo implica no solo en el caso típico, algún tipo de juicio expresivo —como Joel Feinberg acertadamente subrayó—, sino también, como se suele decir, algún tipo de trato severo. Y ahí surge una cuestión real. Creo que, en ese caso, la permisibilidad de infligir la mayoría de los tipos de trato severo que se aplican depende en gran medida de si las personas han tenido la oportunidad de evitarlo, en el sentido relevante.

Esto nos lleva al segundo tipo de problema con el libre albedrío. Tiene que ver con el efecto de autorización que supone que alguien haya tomado un determinado tipo de decisión. Y ahí me acerco mucho más —aunque no sea idéntico, y aunque lo utilice de una manera muy diferente— a algo parecido a la visión de J. J. C. Smart. Su-

pongo que este es el valor de la disuasión para la persona que es disuadida: es bueno para nosotros que se nos advierta de la posibilidad de que sucedan ciertas cosas malas en circunstancias en las que eso probablemente nos disuada. Y si no se nos ha advertido en situaciones en las que es probable que seamos disuadidos, entonces no se nos ha dado suficiente protección contra que nos suceda esa cosa mala.

Mencioné la comparación con Smart porque Smart lo ve simplemente como un problema de política social. Es decir, tiene sentido castigar a las personas si se les puede disuadir, porque de lo contrario no es socialmente útil. Ese es, pues, el valor social de la disuasión. Pero lo que yo destaco es su valor para la persona individual. Curiosamente, Smart pensaba que lo que él consideraba la concepción de sentido común de la culpa debía rechazarse porque presupone el libre albedrío. En cambio, cree que la permisibilidad de sancionar a las personas como estrategia disuasoria no presupone el libre albedrío. No se preguntó si la permisibilidad de amenazar a las personas e imponerles estas sanciones con el fin de disuadir a otros dependía de que tuvieran libre albedrío para elegir evitar este castigo. No abordó esa cuestión simplemente porque es utilitarista, por lo que lo único que le importaba era si era socialmente útil hacerlo. Pero a mí sí me importa. No soy utilitarista.

Así que tengo esta teoría básica: la llamada perspectiva del «valor de la elección». Si nos van a suceder ciertas cosas malas, o si existe la posibilidad de que nos sucedan cosas malas, nos quejamos menos de esa posibilidad si está configurada de tal manera que pudiéramos evitarlas si así lo decidimos. Ahora bien, el valor de esa protección depende en gran medida de las condiciones en las que se da, y si muchas personas crecen en condiciones en las que es previsible y comprensible que la amenaza de la ley no vaya a tener ningún efecto sobre ellas, eso hace que sea mucho más difícil —o incluso imposible— justificar su castigo. Así que creo que, desde mi punto

de vista, esa posibilidad de objetar un sistema de castigo está claramente reconocida.

— *Entonces, si el determinismo causal fuera cierto, y si los genes de una persona predeterminaran que iba a cometer un determinado delito, ¿te preocuparía mucho si sería legítimo o no castigarla? ¿Quizás sería legítimo culparla, pero no castigarla?*

— Bueno, eso es lo que estaba a punto de decir, porque el problema del libre albedrío vuelve a surgir. Así que quiero decir: por muy buenas que sean las condiciones en las que una persona tiene la opción de evitar el delito —no es indigente, ha recibido una buena educación, etc.—, sin embargo, algunas personas quizá nazcan psicológicamente de tal manera que vayan a cometer delitos aunque no tengan otras deficiencias. Quizá. Quién sabe. Así que uno podría imaginarse a esa persona diciendo: «Bien, entonces estás diciendo que me ofreciste una protección valiosa contra la posibilidad de ser castigado al darme la opción, en cualquiera de estas buenas condiciones, de vivir correctamente. Puede que haya sido valioso para algunas personas. Pero a mí no me sirvió de nada».

Y yo creo que eso es como la vacunación. La vacunación no funciona para todo el mundo. Pero una de las cosas que tenemos que hacer para proteger a la gente de las enfermedades es darles la oportunidad de vacunarse. Hay un límite en cuanto a lo lejos que tenemos que llegar. No funciona para todo el mundo, pero si no lo has hecho, entonces no lo has hecho. Si has hecho lo suficiente, entonces has hecho lo suficiente.

Es una cuestión de cuánto tienes que hacer. Parece un poco insensible, pero ahí es donde me armo de valor.

— *¿Así que el punto de partida es que existe una necesidad social de un sistema de castigo?*

— Tiene que haber una necesidad social, claro. Tiene que haber una necesidad social. Tiene que ser una necesidad importante. Esta tiene que ser una forma justificable de abordar esa necesidad, por lo que no puede haber otras formas menos destructivas de satisfacerla. Y dado nuestro actual sistema penal, me parece bastante dudoso

que no haya formas de reducir la delincuencia que no impliquen este coste monumental para las personas encarceladas y para las comunidades de las que se las ha separado.

El trabajo de Mark Kleiman en sociología y criminología es un buen ejemplo de otras estrategias para intentar reducir la delincuencia. Y hay otras iniciativas que intentan hacer lo mismo. Así que creo que es algo horrible, la institución del castigo penal que tenemos ahora, pero obviamente no podemos simplemente abandonarla. En particular, estaríamos abandonando las comunidades en las que hay una alta tasa de delincuencia y dejando a las personas más vulnerables a ser víctimas de abusos, quizás. Así que hay que hacer algo. Pero creo que la mayoría de la gente simplemente no es consciente de lo malo que es lo que estamos haciendo. Así que ese es un problema grave.

— *¿Y qué hay del tercer problema, lo que tú llamas el «problema personal del libre albedrío»?*

— Creo que es un problema más difícil. Explicar cómo puedo seguir considerando que mis reacciones son mías, que me reflejan, si sé que hay una historia física que lleva a que diga las cosas que voy a decir, a que sea así, y demás. Ese parece ser el más desconcertante de los tres problemas.

Aunque, por las razones que he mencionado al hablar de la persona que, en última instancia,

era indomable, creo que sigue habiendo un problema en el segundo caso. Pero creo que es más desconcertante en el tercer caso. ¿Cómo puedo pensar en mí mismo como una persona si también me considero alguien a quien se le ha hecho actuar de la forma en que lo hago?

Y creo que eso es un enigma, uno que no va a desaparecer. Pero, al fin y al cabo, creo que lo veo más o menos como veo el primero: es decir, cuando pienso en mí mismo, en lo que pienso es en mi psicología actual. Y gran parte de eso es simplemente espontáneo.

Quiero decir, no solo es cierto que hacemos algunas cosas por impulso, o lo que sea. Quizás no consideremos que algunas de esas cosas sean realmente nosotros, por ser poco características y anómalas. Pero gran parte de lo que ocurre en una conversación no es premeditado. Me haces una pregunta y sale una respuesta. Así que: ese soy yo. (Risas.) A veces descubro quién soy al ver lo que digo.

Así que estoy dispuesto a aceptar eso, y pienso: ¿qué alternativa hay? No es como si hubiera algún otro ectoplasma ahí dentro que fuera realmente yo; para mí, esa idea no parece tener ningún sentido. Así que creo que tengo que sentirme cómodo con eso. Pero entiendo por qué es un problema persistente y desconcertante.

Continuará... → Sigue en la parte 2



La cárcel "bingo fuel"

por Ezequiel Kostenwein

Un tema persistente y central en la obra del Indio Solari.

9 de junio de 2026

“Solo en su celda, el preso está a merced de sí mismo; al acallar sus pasiones desciende hasta las profundidades de su conciencia... la celda no solo debe ser una tumba, sino también el lugar de la resurrección”. Esto no lo escribió el Indio Solari. Lo hizo el cineasta alemán Harun Farocki. Sin embargo, la cárcel tenía para los dos un significado parecido. Aunque no de modo explícito, ambos seguían reflexiones como las de Michel Foucault acerca de los cambios en las tecnologías penales. En su curso de los años 1972-1973, este filósofo señaló cuatro dispositivos sancionatorios junto a sus respectivas formas sociales: *el exilio*, como expulsión más allá de las fronteras y confiscación de bienes, típico de la sociedad griega; *la compensación*, en la que se convierte al delito en una obligación financiera, característica de las sociedades germánicas; *la exposición*, donde la marca y el signo visible sobre el sujeto castigado se tornan privilegiadas, situadas en las sociedades occidentales de la Edad Media; y *el encierro*, que surge en el siglo XIX por las mismas latitudes. Esto implica sugerir que si la prisión se transformó en un método punitivo dominante no fue por la progresiva humanización de la ciudadanía, sino como consecuencia de un muy complejo juego de intereses y condicionantes tanto políticos como económicos. En definitiva, el ámbito penitenciario posee funciones específicas dentro una sociedad como la capitalista: tolerar ciertas infracciones y reprimir otras, en particular las que cometen las siempre perturbadoras clases subalternas.

Por su parte, el Indio Solari se interesó muy tempranamente por la cuestión carcelaria, y en las letras lo evidenciaba con su estilo mordaz: *Barbazul versus el amor letal*, *Todo preso es político*,

Pabellón séptimo, son algunos ejemplos. En *Toxi-taxi* logra una definición realista, elaborada, pero accesible a todo aquel que la quiera escuchar: *Te tenemos allí, abandonado allí, preso como un animal (como un animal feroz), así las cosas, la fiera más fiera ¿dónde está?* Entonces, cabe hacernos la pregunta: ¿dónde estamos si se toma en cuenta la manera en que penalizamos a nuestros semejantes? Siguiendo los planteos del Indio Solari, estamos en un momento límite.

Es sabido que la expresión *bingo fuel*, utilizada por él en su primer álbum solista, proviene de la aviación para definir situaciones en las que no se debe dilapidar combustible, de lo contrario el avión no podrá regresar a salvo. Cuando el Indio Solari alude al trato que soportan los encarcelados y se pregunta, lúcido, si *la fiera más fiera* está del lado de adentro o del lado de afuera de la prisión, advierte sobre los efectos del castigo, no sólo para quienes lo padecen directamente, sino para la sociedad en su conjunto, la cual corre el riesgo de desintegrarse si naturaliza que sus prójimos sufran ciertas vejaciones. La *cárcel bingo fuel* es una señal de alarma: no sigamos malgastando reservas morales porque quizá nos resulte difícil recrear vínculos compasivos. Más en concreto, evitemos transformarnos en unas fieras, así las cosas, *el amor será aquello que pueda sanarnos todavía una vez más*.

De modo breve pero contundente, el Indio Solari planteaba un interrogante existencial insondable: *¿Habrá después?* Él ya sabe la respuesta, y de paso nos legó otra certeza: no habrá después igual sin él.

¡Gora Indio! Y gracias por cambiar definitivamente nuestros destinos. ■

Democracia, excepcionalismo gubernativo y protesta social en Bolivia

por Mijhail Pavel Pardo Lafuente

Algunos desvaríos schmittianos en la "regulación" de la protesta social.

9 de junio de 2026

Las democracias constitucionales — particularmente aquellas estructuralmente erosionadas por prácticas como el hiperpresidencialismo, la captura institucional o, en nuestros tiempos, el excepcionalismo gubernativo— no se degradan únicamente mediante actos espectaculares de ruptura súbita. Con frecuencia, la desustanciación democrática se produce *in crescendo*, es decir, a través de procedimientos formalmente válidos que, paulatinamente, terminan vaciando de contenido los mecanismos de control recíproco entre los órganos del poder público (Ginsburg y Huq, 2018, p. 45). Exactamente allí radica el problema de la recientemente promulgada Ley N° 1732 en el Estado Plurinacional de Bolivia (abrogatoria de la Ley 1341 sobre “Estados de Excepción”), en haber sido concebida bajo la lógica de la “urgencia coyuntural” antes que bajo las exigencias propias de la doctrina de la “legislación racional”.

La discusión asamblearia que antecedió a su aprobación parece haber operado bajo una suerte de lo que algunos autores denominan “deliberación de enclave” (Martí, 2006, p. 36), es decir: rápida, semicerrada, estratégicamente orientada por intereses homogéneos y escasamente abierta al escrutinio público. Un espacio donde la multiplicidad de “voces discordantes” involucradas en la presente coyuntura (v.gr. organizaciones campesinas e indígenas; federaciones sindicales y centrales obreras; organizaciones cocaleras; juntas vecinales y organizaciones territoriales urbanas, entre otras) queda reducida a “obstáculos tácticos”, eclipsando así su condición de interlocutores válidos capaces de

conferir un cariz mínimo de “legitimidad democrática” a dichas deliberaciones. Precisamente sobre este punto adquiere singular relevancia la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0016/2021 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP-B). En esa oportunidad, el máximo órgano de interpretación constitucional desarrolló —quizá una de las pocas veces con relativa rigurosidad teórica— una comprensión de la racionalidad legislativa como exigencia de justificación pública inherente al ejercicio democrático del poder; reconociéndose, entre otros aspectos, que la actividad legislativa presupone una “ponderación crítica de (todos) los intereses en juego”, así como una evaluación seria sobre “la necesidad, pertinencia y efectos” (pp. 15-16) de la decisión normativa.

Más aún, la decisión adoptada por el TCP-B incorpora —siguiendo la influyente teoría que ha desarrollado Manuel Atienza (1997, pp. 11-12) en este campo— la idea según la cual una ley no puede considerarse racional únicamente porque haya sido aprobada conforme a formas procedimentales mínimas previstas en la reglamentación orgánica o camaral (lo que equivaldría, en los hechos, a la sola satisfacción de una de las cinco etapas propuestas por el profesor alicantino, a saber: la “racionalidad lógico-formal”), sino porque debe existir una conexión razonablemente justificable entre fines, medios, contexto social y restricciones constitucionales. Es por ello que la abrogación de la Ley N° 1341 resulta particularmente problemática ya que permitía distinguir algunos márgenes de contención

frente a categorías excepcionalmente vagas y potencialmente expansivas en términos discrecionales tales como “amenaza externa”, “grave riesgo institucional”, “conmoción interna”, “desastre natural” o “afectación a la seguridad del Estado”; conceptos cuya textura abierta puede transformarse, dada la ausencia de perímetros jurídicamente claros, en auténticos dispositivos autoritarios.

En este punto conviene recordar algo elemental, aunque frecuentemente omitido en contextos de extrema polarización. El estado de excepción constituye una de las instituciones históricamente más proclives a la concentración cesarística del poder. Su genealogía es, en gran medida, la genealogía del decisionismo, del “Estado fuerte” o, para decirlo con la conocida formulación de Carl Schmitt, de la tesis según la cual el soberano es “quien decide sobre el estado de excepción” (Dyzenhaus, 2020). La consecuencia institucional de dicha premisa, sostiene Dyzenhaus (2006), consiste en concebir al Ejecutivo como el verdadero “guardián de la Constitución” y, por ende, como la “autoridad jurídica suprema” sustraída a las exigencias materiales del Estado de Derecho (pp. 1-5).

Por ello, toda regulación en esta materia exige satisfacer estándares de “deliberación reforzada” antes que discusiones ficcionales o de simulacro (Gargarella, 2014), donde los mecanismos de control político y jurisdiccional coadyuvan a su prosecución. Ahora bien, el problema de los poderes excepcionales no radica únicamente en su justificación deóntica, sino en la facilidad con la que las medidas extraordinarias terminan institucionalizándose y/o normalizándose bajo la retórica permanente de la emergencia. Repárese, por caso, en el “régimen de excepción continuado” dictado por Bukele en El Salvador desde hace aproximadamente cuatro años y las violaciones colaterales que ha traído aparejada esta determinación en cuanto concierne al ejercicio de garantías y derechos fundamentales (CIDH, 2024, pp. 47-126).

No sorprende, entonces, que la narrativa justificatoria de la Ley N° 1732 haya descansado sobre el mantra de la “conflictividad”, del “desabastecimiento” (energético, alimentario, etc.), del “riesgo de un inminente colapso institucional”, de la “necesidad de garantizar el orden”, etc. El problema no es que tales situaciones no existan, sino que la emergencia se convierta, paulatinamente, en un criterio “autosuficiente” de legitimación política; como si la urgencia suspendiera la necesidad de deliberar, como si la polarización social que actualmente atraviesa el país —azuzada, en parte, por el clivaje “clase/etnia” a pesar de los cambios (de orden simbólico antes que sustantivos) introducidos por la Constitución de 2009— pudiera sustituir los principios de argumentación y deliberación suficiente que exige, siguiendo la clásica formulación que esgrimiese Mill, toda democracia en tanto “gobierno por discusión”.



En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más intensa es la afectación potencial de derechos y cuanto mayor es la posibilidad de expansión del poder estatal, mayor debe ser la carga justificatoria del legislador y, *a fortiori*, del gobierno de turno. Esa es, precisamente, la intuición que subyace tanto en la jurisprudencia comparada como en la teoría deliberativa contemporáneas. Por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana (CCC) ha desarrollado una doctrina exigente sobre el “deber de deliberación mínima”, entendiendo que determinadas decisiones legislativas requieren condiciones materiales de discusión pública suficientes para preser-

var la legitimidad democrática del procedimiento (Otálora Lozano, 2013, pp. 65-108). Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en el marco de un examen de proporcionalidad empleado en el caso *Hirst v. UK*, consideró deficiente el proceso legislativo porque el parlamento británico “no había buscado ponderar los intereses en conflicto”, ni había existido “ningún debate sustancial entre sus miembros” (Oliver-Lalana, 2019, p. 405).

Todos estos estándares convergen en una misma ecuación de signo republicano, a saber: la legitimidad democrática no se agota en el resultado de la votación (dimensión agregativa), sino que exige, antes bien, procedimientos deliberativos mínimamente incluyentes, así como canales de contraste permanentes a través de los cuales la ciudadanía sea capaz de imponer sobre el gobierno una dirección igualmente aceptada por todos (Pettit, 2012, pp. 130-186). Exige, a decir de Sen (2024), “la capacidad de enriquecer el encuentro razonado a través del mejoramiento de la disponibilidad de información y la viabilidad de discusiones interactivas” (p. 16), donde otras voces disidentes, heterodoxas e incómodas sean audibles.

Así las cosas, la aprobación de la Ley 1732 transmite la impresión de una Asamblea Legislativa Plurinacional que, lejos de robustecer sus competencias de control, termina debilitando —cuando no autoliquidando— paradójicamente su propia función fiscalizadora amparada en los arts. 161 (numeral 6) y 158 de la Constitución boliviana. Más delicado aún es que, mientras este artículo era redactado, la Cámara de Diputados aprobara un nuevo proyecto de ley de regulación de estados de excepción (Proyecto de Ley N.º 161/2025-2026), cuyo contenido parece profundizar varias de las tendencias aquí identificadas. La incorporación de presunciones de “legitimidad” (art. 5.f), “buena fe” (art. 5.i) y “legalidad operativa” en favor de la actuación estatal (fuerzas armadas y policía, art. 26) sugiere un modelo de deferencia institucional difícilmente conciliable con la premisa republicana según la cual

cuanto mayor es la concentración del poder, mayor debe ser la intensidad de su control.

Ahora bien, lo anterior tampoco implica asumir una deferencia “romántica” o “acrítica” de los bloqueos indefinidos. Esa simplificación binaria —tan frecuente en el debate público boliviano— impide comprender el trasfondo estructural del conflicto. No existe, ciertamente, un “derecho absoluto al bloqueo”. Ni la jurisprudencia interamericana (i.e., Corte IDH) ni los estándares desarrollados por la Comisión Interamericana (CIDH) han establecido tal categoría. Lo que el Sistema Interamericano ha reconocido es algo bastante más sofisticado —y, al mismo tiempo, más incómodo para las concepciones “securitarias” del orden público a las que, dicho sea de paso, la ultraderecha regional apela sempiternamente—, a saber: que el derecho a la protesta social puede exteriorizarse a través de modalidades disruptivas, incluyendo “cortes de ruta, huelgas, los cacerolazos, vigiliadas, sentadas y ocupaciones pacíficas” (CIDH, 2019, párrs. 8 y 9), en tanto formas de expresión colectiva y amplificación política del disenso.

Ello no equivale —como erróneamente parecen sugerir algunas lecturas maximalistas o simplificadoras del actual conflicto— a consagrar un “derecho irrestricto al bloqueo indefinido” de vías camineras, ni a inmunizar cualquier forma de afectación a terceros frente al control de proporcionalidad. Significa reconocer, *a contrario sensu*, que en sociedades atravesadas por profundas desigualdades y déficits de representación política como la boliviana, la protesta social no puede reducirse a expresiones simbólicamente inocuas o políticamente esterilizadas. Como recuerda la propia CIDH, muchas de estas acciones emergen allí donde los canales institucionales tradicionales han sido históricamente insuficientes para los “sectores subrepresentados o marginados” (CIDH, 2019, párrs. 15-16).

La excepcionalidad constitucional, conviene insistir, no constituye un espacio exento de derecho; es, precisamente, el ámbito donde más intensamente debe operar la normatividad demo-

crática. Por ello, aun tras la abrogación de la Ley 1341, el gobierno de Rodrigo Paz continúa plenamente sometido al bloque de convencionalidad interamericano y, en particular, a las restricciones materiales derivadas de la Convención Americana de 1969 así como de las Opiniones Consultivas OC/08 y OC/09 del 1987 cuyo razonamiento convergente no es otro que afirmar que la emergencia no suspende el Estado de Derecho ni principios jurídicos que precisamente le confieren legitimidad.

Referencias bibliográficas

- . Atienza, M. (1997). *Argumentación legislativa*. Thomson-Civitas.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2019). *Protesta y derechos humanos: Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal* (OEA/Ser.L/V/II, CIDH/RELE/INF.22/19). Organización de los Estados Americanos. <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2024). *Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador* (OEA/Ser.L/V/II, Doc. 97/24). Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2024/informe_estadoexcepcionddhh_elsalvador.pdf
- Dyzenhaus, D. (2006). *The constitution of law: Legality in a time of emergency*. Cambridge University Press.
- Dyzenhaus, D. (2020, June 12). *Lawyer for the strongman*. Aeon. <https://aeon.co/essays/carl-schmitts-legal-theory-legitimises-the-rule-of-the-strongman>
- Gargarella, R. (2014, noviembre 2). *Un debate de ficción en el Congreso*. La Nación. <https://www.lanacion.com.ar/opinion/un-debate-de-ficcion-en-el-congreso-nid1741599/>
- Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2018). *How to save a constitutional democracy*. The University of Chicago Press.
- Martí, J. L. (2006). *La república deliberativa: Una teoría de la democracia*. Marcial Pons.
- Oliver-Lalana, D. (2019). Deliberación legislativa y control judicial de las leyes: Entre el respeto y la desconsideración por los legisladores electos. En D. Oliver-Lalana (Ed.), *La legislación en serio. Estudios sobre derecho y jurisprudencia* (pp. 381-426). Tirant lo Blanch.
- Otálora Lozano, G. (2013). El deber de deliberación mínima en el procedimiento legislativo. *Pensamiento Jurídico*, (38), 65-108.
- Pettit, P. (2012). *On the people's terms: A republican theory and model of democracy*. Cambridge University Press.
- Sen, A. (2024). *La idea de la justicia* (H. Valencia Villa, Trad.). Taurus.





Una entrevista con Scanlon (parte 2)

por Yascha Mounk

Recuperamos y traducimos una vieja, y notable, entrevista sobre el castigo y sus justificaciones.

9 de junio de 2026

[Enlace a la [Parte 1](#)]

— *The Utopian: En «Significance of Choice», expusiste los diferentes tipos de elección que conservan su valor incluso si el determinismo causal fuera cierto. En algunos casos, es obvio por qué debería ser así: el valor instrumental de la elección, por ejemplo. Cuando vas a comer a un restaurante, lo que te sirvan debería depender de tu elección, incluso si el determinismo causal fuera cierto. Pero lo que usted denomina la dimensión «expresiva» de la elección parece más problemática: se trata de la idea de que, en lugar de que lo haga otra persona, es importante que usted elija el regalo que le da a su esposa. Pero podría pensarse que, si está causalmente predeterminado que iba a elegir el regalo para su esposa, eso socava el significado del gesto. Ella podría decir: bueno, está bien que te hayas tomado el tiempo, pero, al fin y al cabo, el hecho de que decidieras tomarte ese tiempo también estaba predeterminado causalmente.*

— *Tim Scanlon.* Bueno, eso muestra la interacción entre estas diferentes formas del problema, creo.

Es decir, mi primera respuesta es decir que es más significativo para mi esposa, mi amigo, mi colega que se jubila o quien sea, si elijo yo mismo un regalo para ellos. Ahora bien, en parte es porque el hecho de que me tome la molestia de elegirlo demuestra un nivel de preocupación. Pero también es que el hecho de que sea esto lo que se me haya ocurrido le da un significado adicional —un significado más allá de que el hecho de que me haya tomado la molestia de pensar en ello sea prueba de un cierto tipo de preocupación. Y no creo que ese tipo de significado se vea socavado por el hecho de que mi ejercicio de originalidad

y perspicacia al pensar en el regalo adecuado sea producto de un proceso causal.

Esto se debe en parte a que —aunque esto pueda verse simplemente como una repetición del mismo problema en otro contexto— como dije al hablar de la justificabilidad de la culpa, nuestras relaciones con otras personas son nuestras relaciones con personas psicológicamente integradas. Quiénes son para nosotros viene definido por la forma en que suelen responder, y así sucesivamente. Lo que tiene significado para mí en relación con mis amigos es la forma en que son realmente, no la forma en que algo independiente de lo que son realmente determina cómo son. Lo que son como criaturas psicológicamente encarnadas y caracterizadas es lo que me importa. Así que, en cuanto al significado que tiene para los demás el hecho de que ejerza mi originalidad, me parece que eso encaja con el tipo de historia que estaba contando sobre la culpa.

Otra versión del significado de la elección es el significado que tiene para mí que la decoración de mi apartamento refleje mi gusto, mi originalidad, mi personalidad y mis ideas al respecto, y así sucesivamente. Ahora bien, eso depende esencialmente del tercer problema: cómo el hecho de que, si entro en una tienda y elijo este sofá en lugar de aquel —o este tipo de muebles de estilo Corbusier en lugar de una lámpara de lava (risas)—, por qué eso debería ser significativo. ¿Cómo puede ser significativo para mí que exprese mi esencia, dado que es igual que mi conversación: hay algún mecanismo causal que funciona de tal manera que me lleva a decir una cosa en lugar de otra cuando me haces una pregunta, y también me lleva a elegir un tipo de muebles en lugar de otro?

Así pues, estos tres problemas están interrelacionados. Las razones que subyacen a nuestra preocupación por la elección, tanto en el caso de la reacción moral como en el de la expresión personal, presuponen en cierto modo algo parecido al significado para una persona del tercer tipo: el significado personal. Así que si realmente no pudieras resolver ese problema en absoluto —si sintieras que la idea de una explicación causal de mi respuesta simplemente destruyera el significado personal—, entonces tendería a destruir también el significado de la elección en esos otros casos.

Quizá salvo la versión puramente instrumental. De las tres versiones del valor de la elección, la instrumental sería la más resistente a ese tipo de socavamiento. Pero también parece la más superficial en algunos aspectos. En definitiva, no es algo sin importancia: no quiero encontrar hígado en mi plato... (Risas.)

— *Me llamaron mucho la atención las últimas frases de «El significado de la elección». Allí dices: «La indignación moral y, si es que existe tal cosa, legal hacia los infractores de la ley está totalmente justificada y el sufrimiento que les infligimos puede estar justificado. Pero al justificar estos sufrimientos e infligirlos no debemos decir: “Te lo has buscado”. Sino: “Por la gracia de Dios, ahí podría estar yo”». ¿Qué significa esto para alguien que ha infringido la ley? ¿Dicen, no «Por la gracia de Dios, ahí podría estar yo», sino más bien algo como: «Por la falta de la gracia de Dios, ahí estoy yo»?*

— Bueno, como alguien que no se toma muy en serio la idea de Dios —o que, en cierto modo, le cuesta entenderla—, simplemente solté esa frase sin pensarlo mucho, y después deseé haber dicho simplemente: tenemos que ver esto como una cuestión de suerte. Porque si se toma al pie de la letra, la idea de la gracia de Dios no es lo que yo diría. Así que me sentí un poco incómodo con esa frase.

Pero creo que hay algo importante y acertado en el análisis que hace Ronald Dworkin de esto en *Justice for Hedgehogs*. Él dice, en esencia, que la persona que realmente es castigada no pue-

de renegar por completo de lo que ha hecho. No puede decir: «Bueno, es solo el cosmos actuando a través de mí; no tiene nada que ver conmigo». No puede hacer eso sin socavar su relación con todo lo que ha hecho y su relación con todos los demás. Sería una especie de nihilismo personal. No es solo que sería imposible de sostener, sino que resultaría poco atractivo.



Ahora bien, se podría decir: «Eso no demuestra que no tenga sentido. Solo demuestra que es lo único que da sentido a esas otras actitudes». Por eso es difícil expresar esta postura de una manera que la haga parecer sólida. Pero, no obstante, me parece que hay algo de cierto en ella. Así que supongo que hay que darle la vuelta y decir: «La responsabilidad se sostiene o se derrumba como un todo. A menos que haya alguna explicación especial de por qué cometiste el delito, no puedes decir: “fue solo el Big Bang actuando a través de mí”». Se sostiene o se derrumba como una unidad completa. Esa es, creo, la idea central detrás de la observación de Dworkin.

Vale, aceptemos eso. No se puede hacer por partes sin alguna excusa especial —lo cual sería un juego completamente diferente—. Se sostiene o se derrumba como un todo. Entonces, ¿por qué no dejar que se derrumbe? Y Dworkin, en efecto, dice: pero nadie querría hacer eso. Destruiría el sentido de tu vida. Pero entonces el siguiente paso es: «bueno, si es realmente cierto que tu vida no tiene ningún sentido si todo se debe al Big Bang —quizás con algunos elementos aleatorios incorporados por el camino—, ¿por qué mante-

ner una visión sin sentido solo porque te sientes apegado a ella?».

Así que creo que en ese punto hay que plantearlo a la inversa y decir: «Sí, eso sería cierto si el hecho de que estas cosas que hago sean causalmente explicables realmente proporcionara una razón sólida e innegable para declarar que todo carece de sentido. ¿Y por qué iba a hacerlo?». Y entonces vuelvo a algo parecido al problema moral del libre albedrío. Todo carecería de sentido si se separaran las cosas que hago de algún tipo de causa o condición previa que, por sí sola, las hiciera más, les diera sentido. Y uno querría decir: bueno, no, eso no ocurre.

Si la única concepción inteligible del yo fuera este tipo de concepción dualista en la que hay un yo acausal que interviene en el universo y piensa estos pensamientos como resultado de una entidad autocausada que genera estos pensamientos que luego cambian la dirección del mundo causal —si eso fuera lo único que da sentido a que nos importen estas cosas—, entonces tendríamos que renunciar a todo, ¿verdad?

Pero, ¿por qué pensar que es así? ¿Por qué no decir algo como lo que dijimos antes: lo que hace que parezca que somos nosotros es el hecho de que, a) proviene de nosotros y, b) proviene de nosotros de una manera que está entrelazada con todas estas otras cosas —y refleja esas cosas, en general.

Así que creo que algo parecido a la respuesta que daba a los problemas morales es relevante aquí: lo que somos para nosotros mismos, así como para los demás, es este complicado conjunto de fenómenos psicológicos. No hay razón para decir que eso es algo por lo que no tenemos motivos para preocuparnos. Así que necesitarías una explicación más convincente de por qué la explicación causal hace que eso sea algo por lo que tenemos motivos para no preocuparnos, más allá de lo que he visto hasta ahora, para poder decir que, dado que todo se sostiene o se derrumba como un todo, deberíamos dejar que se derrumbe. Eso es lo que pienso. Es una pregunta difícil, pe-

ro creo que el análisis que hace Dworkin al respecto es bastante bueno.



— Se podría decir que el impulso de las concepciones modernas de la moralidad proviene del deseo de protegernos de ser responsables de cosas sobre las que no tenemos control. A diferencia de la mayoría de los antiguos, pensamos que es incorrecto culparte por la condición en la que naciste. A diferencia de algunos cristianos, no queremos que lo que te suceda dependa de si naciste o no con la gracia. Solo puedes ser responsable de las acciones si tú las hiciste —y si, a su vez, fuiste responsable de elegir llevarlas a cabo. Ahora bien, tu respuesta a todo esto parece ser: bueno, si vas por ese camino, entonces en algún momento tienes que renunciar por completo a todo sentido de agencia personal.

— Galen Strawson tiene un excelente artículo sobre la imposibilidad de la responsabilidad moral. Y yo lo leí al revés, por así decirlo. Es decir: Strawson dice que la responsabilidad moral es imposible porque, para ser moralmente responsables de una acción, tenemos que ser moralmente responsables de ser psicológicamente como somos, lo que nos llevó a realizar la acción. Pero no podemos ser moralmente responsables de ser así a menos que ser así surgiera de una elección consciente por nuestra parte de ser así, lo cual era en sí mismo un reflejo de ser de alguna manera anterior de la que éramos responsables. Pero no podemos ser responsables de eso... y así sucesivamente. Este retroceso no puede terminar en ningún sitio, por lo que todo esto es incoherente.

Y quiero decir: lo que hay de cierto en eso, lo que impulsa el retroceso, es la idea de que el yo que es responsable tendría que ser de alguna manera anterior a cualquier conjunto particular de características psicológicas. Pero un yo tan desnudo me parecería carente de sentido. Lo que muestra el artículo de Strawson es que no se puede imaginar un yo desprovisto de contenido psicológico tomando decisiones que no tendría ninguna razón para tomar. Así que cada paso que se retrocede solo sustituye una psicología dada por otra psicología dada anterior. Y la conclusión que saco de ello es: sí, nuestra valoración de una persona —y nuestra comprensión de una elección como una elección significativa— siempre se da en el contexto de una psicología dada, que es cómo es esa persona. Y nuestra valoración moral de las acciones de una persona es una valoración de las mismas como reveladoras de que la persona es así, lo cual es un conjunto fijo de psicología. Y la importancia para la persona de hacer algo radica en el hecho de que hacerlo refleja la forma en que realmente se siente a sí misma, psicológicamente.

Así que, ya se trate de elogios o reproches morales, o de lo que yo denomino el problema personal del libre albedrío, lo que esto muestra es que la noción del yo que resulta significativa,

ya sea como objeto de valoración o como fundamento del significado individual, siempre tiene que tener un contenido psicológico. Y luego quiero decir: el hecho de que eso sea hasta cierto punto arbitrario —de hecho, es completamente arbitrario en el sentido de estar causado— no es arbitrario para la persona porque realmente es él. Y no es arbitrario para sus amigos, porque así es como es realmente. Así que no es arbitrario en el sentido relevante, aunque pueda estar causado por todos esos factores fuera de su control. Eso no impide que sea él. El excelente artículo de Strawson pone de relieve ese punto: es una especie de *reductio* de esta visión del yo desnudo.

Ahora bien, cuando Strawson aborda la cuestión de por qué la responsabilidad siempre debería requerir este paso atrás, no deja muy claro qué entiende por responsabilidad. Excepto, dice, «es el tipo de cosa que haría que las ideas del cielo y el infierno al menos tuvieran sentido». Así que ahí parece que estamos entrando en una idea punitiva —lo que yo consideraría una oportunidad que hay que evitar—. Él no lo dice literalmente, y nunca he tenido la oportunidad de preguntarle a Galen qué quería decir realmente con eso, pero a mí me parece que es así como se ve, en cualquier caso. ■



Por qué la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario es "técnicamente dictatorial"

por Pedro Caminos

La negativa de Javier Milei de cumplir la ley aprobada por el Congreso es un precedente peligroso para la democracia y la seguridad jurídica.

11 de junio de 2026

En el discurso jurídico-político, el término dictadura tiene un uso emotivo y otro técnico. La primera acepción consiste en calificar a un gobierno como "dictatorial" por su ejercicio autoritario del poder con el objetivo de descalificarlo. La segunda se refiere a la adopción de medidas con independencia del derecho vigente, en ocasiones suspendiendo las leyes, con el propósito de alcanzar fines que el gobierno juzga muy importantes.

El gobierno de Javier Milei ejerció varios actos dictatoriales en sentido técnico. La suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario es uno de ellos.

Cómo llegamos hasta aquí

La Argentina atravesaba un proceso inflacionario muy preocupante cuando Milei llegó a la presidencia en diciembre de 2023. Según datos oficiales, la inflación anual en 2023 fue de un 275,3%, mientras que en los dos años siguientes fue del 122,5% y del 35,3%, respectivamente.

A pesar de ello, no se sancionó ninguna ley de presupuesto para 2024 ni 2025, por lo que el gasto público presupuestado se mantuvo en los valores de 2023. Esto se debe a que la Ley de Administración Financiera, la normativa que regula la obtención y aplicación de los recursos públicos, prevé que, cuando no se sanciona una ley de presupuesto para un año determinado, automáticamente queda prorrogada la ley del año anterior. De ese modo, el presupuesto previsto para

el año 2023 mantuvo su vigencia durante los dos años siguientes pese a una inflación acumulada del 791,7% durante esos tres años.

Esta situación afectó profundamente a las universidades públicas argentinas, que se movilizaron para revertirla mediante lobby y manifestaciones masivas en las principales ciudades del país. En 2025, el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario. La norma tenía como único objeto actualizar la partida presupuestaria correspondiente a las universidades públicas, ajustándola a la inflación. No se trató de un aumento real del gasto público destinado al sistema universitario, sino de un medio para recomponer dicho gasto para garantizar el funcionamiento de las universidades.

El rechazo del veto presidencial

El presidente vetó dicha ley. Sin embargo, el Congreso insistió con la sanción reuniendo una mayoría especial en cada una de sus cámaras. Cuando ello ocurre, el presidente está constitucionalmente obligado a promulgar la ley y a comenzar a cumplirla. Pero Javier Milei tenía otros planes. El presidente promulgó la ley, pero en ese mismo decreto también suspendió su aplicación.

Para ello, invocó la Ley de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto. Esta ley dispone que, si una ley autoriza gastos -refiriéndose a gastos no previstos en la ley de presupuesto del año en curso-, deberá prever en

forma expresa su financiamiento. Si no lo hiciera, entonces su aplicación quedará suspendida hasta tanto se incluyan las partidas en la ley de presupuesto.

Con la ejecución de la ley suspendida, las universidades públicas tuvieron que mantener su reclamo y presentar una demanda judicial. Esto llevó a los tribunales a emitir una orden provisional para que el gobierno cumpla con la ley. Esa orden fue apelada por el gobierno ante la Corte Suprema, que ahora deberá tomar una decisión.

Por qué es “técnicamente dictatorial”



En su ensayo sobre el concepto de dictadura, Carl Schmitt describió sus tres elementos: técnica, racionalidad y ejecución.

El dictador actúa con fundamento en una comisión que le indica cierto fin a cumplir. La técnica consiste en que el dictador elegirá el medio más apropiado para cumplir con su comisión. En este caso, el fin declamado es evitar el déficit fiscal y el medio técnico elegido es la suspensión de una ley vigente.

La racionalidad, por su parte, tiene una doble dimensión. Por un lado, se sustenta en que dicho medio es el exigido por la razón para alcanzar el fin. Pero también, por otro lado, subyace la idea de la irracionalidad de quien se opone al dictador.

El decreto de Milei recoge este elemento al sostener que el Congreso no entiende las normas

que regulan la prórroga del presupuesto y que la Ley de Financiamiento Universitario formularía una exigencia de imposible cumplimiento. De ahí la racionalidad del medio elegido, que es la suspensión de la ley.

Finalmente, la ejecución se refiere a que la decisión de un dictador no es una mera norma, sino que ella misma constituye una acción. En este caso, la acción técnicamente dictatorial es una omisión: no ajustar la partida presupuestaria de las universidades a la inflación.

Una dictadura es la negación del estado de derecho. Al elegir el medio apropiado para alcanzar el fin indicado en su comisión, el dictador puede actuar sin considerar los derechos previstos en las leyes vigentes. Y efectivamente, ello es lo que ocurre en el caso de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Ley de Administración Financiera no le otorga al presidente una facultad para elegir si incluirá una previsión que permita mantener la prestación de los servicios que brinda el Estado, sino que le impone el deber de hacerlo.

Al mismo tiempo, la Ley de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto no resulta aplicable en este caso. Esto es porque la Ley de Financiamiento Universitario no habilitó un gasto no previsto en la ley de presupuesto ni tampoco a incrementar en términos reales uno ya habilitado, sino que dispuso actualizar un gasto que contaba con partida presupuestaria, manteniendo su valor real.

La aprobación de la ley de presupuesto para el año 2026, con una partida presupuestaria para las universidades, no subsana el problema respecto de los años anteriores. En efecto, sigue siendo verdadero que, durante esos años, se mantuvo la partida presupuestaria desactualizada prevista para el año 2023, que fue lo que la Ley de Financiamiento Universitario vino a solucionar.

Un antecedente peligroso

Este ejercicio dictatorial del poder, en sentido técnico, es preocupante por tres razones.

En primer lugar, porque constituye un antecedente que podrá ser invocado en el futuro por el propio Javier Milei u otros presidentes para negarse a cumplir con una ley del Congreso. Se trata de una pésima señal para los inversores extranjeros, siempre preocupados por la seguridad jurídica.

En segundo lugar, porque se trata de una clara transgresión a las reglas básicas de funcionamiento de una democracia constitucional. La mera voluntad del individuo que ocupa la presidencia no puede prevalecer sobre una ley adoptada por mayorías especiales en el Congreso en el marco de importantes movilizaciones ciudadanas.

Finalmente, porque su objetivo es conducir a la supresión del sistema de universidades públicas, decisión que acompaña la de hacer lo propio con el sistema científico del país. Esto tendrá consecuencias directas en la producción del conocimiento y también en el funcionamiento de la política. Como señaló Vicki C. Jackson, profesora de derecho constitucional comparado de la Universidad de Harvard, las autocracias contem-

poráneas se caracterizan, entre otras cosas, por sus intentos de destruir a las instituciones de conocimiento, como lo son las universidades, para evitar que existan fuentes alternativas de autoridad que puedan competir con ellas.



En síntesis, la Corte Suprema argentina tiene en sus manos mucho más que un caso judicial. Deberá decidir si el presidente puede convertirse, técnicamente, en un dictador y, de ese modo, subvertir el estado de derecho, la democracia y la producción de conocimiento en la Argentina en un único acto. Eso es lo que está en juego. ■



¿Cómo he de vivir?

por Gustavo Pereira

Mujica y su camino filosófico.

13 de junio de 2026



Gustavo Pereira, *¿Cómo he de vivir? El camino filosófico de Mujica*, Crítica/Planeta, 2026.

La pregunta que da título al libro, *¿Cómo he de vivir?*, es una de las preguntas fundacionales de la filosofía, porque demanda una orientación para nuestra vida. Interroga el modo en que usamos nuestro tiempo, los deseos que cultivamos, los vínculos que sostenemos, las instituciones que construimos y las formas de convivencia que consideramos justas. En ese sentido, a pesar de que se formula desde una perspectiva individual, la trasciende y se proyecta hacia el mundo en que queremos vivir y hacia el tipo de sociedad compatible con una vida digna.

José Mujica no fue, ni pretendió ser, un filósofo. Decir que lo fue sería injusto con la filosofía y también con él. Sería aprovecharse de su figura para atribuirle una sistematicidad que no buscó, pero sería igualmente injusto desconocer que tuvo una sensibilidad extraordinaria para detectar problemas filosóficos fundamentales. Mujica pensaba desde una mezcla singular de observación profunda, memoria histórica, intuición moral y aprendizaje político. Esa forma de pensar

no produjo una doctrina, pero sí una orientación vital que nos permite volver a preguntas que la vida contemporánea parece haber sepultado bajo la dinámica del consumo, la aceleración y el cinismo.

En buena medida, el impacto de Mujica se explica por esa capacidad de rememoración. Su voz nos recuerda cosas que de algún modo ya sabíamos, pero que habíamos dejado de tener presentes. Nos recuerda que el tiempo no es solo un recurso administrable, sino la materia misma de la vida; que el consumo no equivale a felicidad; que la libertad puede empobrecerse cuando se convierte en compulsión egocéntrica; que la igualdad es una condición para vivir entre otros sin humillación; o que la política pierde su sentido cuando se separa de la ética. Tal vez sus palabras han tenido tanta recepción en públicos muy distintos porque devuelven centralidad a preguntas que han sido trivializadas.

La primera respuesta que el libro reconstruye a partir de Mujica refiere a la vida buena. La vida buena, en la tradición clásica, está asociada a la formación del carácter, al ejercicio de la razón práctica y a la capacidad de orientar la existencia hacia fines que merezcan ser elegidos. Mujica recupera esa tradición poniendo especial énfasis en lo que podría denominarse inteligencia ética. Su apelación a la reflexión y la deliberación aspira a generar una respuesta inteligente en los ciudadanos ante los imperativos del consumismo y la búsqueda sin sentido de cierto bienestar material. Lo que cuestiona es la confusión entre medios y fines, ya que la economía, la técnica, el mercado y el Estado deberían estar al servicio de la vida. Cuando se autonomizan y empiezan a imponer sus propias lógicas, la vida

humana queda subordinada a instrumentos que ella misma ha creado.

Por eso una de las claves del pensamiento de Mujica es lo que podríamos llamar una ética de lo suficiente. La austeridad que él encarna no debe entenderse como privación ni como culto al sacrificio, sino como un ejercicio práctico de libertad. Consiste en reducir la dependencia respecto de deseos inducidos, necesidades artificiales y formas de reconocimiento superficial. En ese punto, Mujica se acerca a la tradición estoica, pero la desplaza hacia el interior de las democracias contemporáneas, ya que no se trata de aceptar pasivamente el mundo tal como es, sino de adquirir fortaleza interior para no ser gobernados por aquello que nos promete felicidad mientras nos vuelve dependientes. La autolimitación no aparece así como renuncia, sino como condición para recuperar soberanía sobre la propia vida.

Esta crítica se vuelve especialmente relevante frente a la mercantilización contemporánea. Uno de los males de nuestra época es que cada vez más dimensiones de la existencia son traducidas al lenguaje del mercado. La educación se concibe como inversión rentable, los vínculos como capital relacional, el tiempo libre como oportunidad de consumo, la identidad como marca personal. Mujica reacciona contra esa colonización de nuestros espacios vitales por la forma mercancía, y de ahí surge su insistencia en que no todo puede comprarse ni venderse. Es necesario preservar espacios de sentido que solo existen cuando no son reducidos al intercambio. La amistad, el cuidado, la solidaridad, la participación política y el contacto con la naturaleza poseen, en términos kantianos, valor y no precio.

De allí surge otra dimensión central del libro, que es la oposición entre alienación y resonancia. La vida moderna ha multiplicado nuestras capacidades, pero también ha generado formas profundas de extrañamiento. Vivimos en un mundo que hemos construido y que, sin embargo, muchas veces se nos presenta como ajeno.

Trabajamos en sistemas que no controlamos, consumimos objetos que no satisfacen, habitamos instituciones que con frecuencia se vacían de sentido y nos movemos a una velocidad que dificulta la experiencia plena. Hartmut Rosa ha llamado resonancia a la posibilidad de establecer una relación significativa con el mundo, con los otros, con la naturaleza y con nosotros mismos. Mujica, sin utilizar ese vocabulario, parece haber vivido y pensado desde una intuición semejante. Su defensa del tiempo para el amor, la amistad, la contemplación, el trabajo con sentido y la vida comunitaria es una defensa de relaciones resonantes frente a una existencia acelerada y alienada.

La pregunta por cómo vivir conduce inevitablemente a la política. Mujica no entiende la vida buena como una aventura puramente individual. Para él no hay autorrealización suficiente en una sociedad atravesada por la desigualdad, la exclusión y la humillación. Por eso la justicia ocupa un lugar decisivo en el libro. Una sociedad injusta no solo distribuye mal los recursos, sino que también produce formas de desprecio, dependencia y resignación. La promesa democrática que se aspira a recuperar consiste en que nadie sea condenado a vivir una vida disminuida por el lugar en que nació, por su pobreza o por la falta de oportunidades reales para desarrollar sus capacidades.

En este punto, Mujica permite recuperar algo que nuestra época parece haber olvidado: la ética tiene un lugar fundamental en la política. Esto no significa moralizar ingenuamente los conflictos ni suponer que la buena voluntad basta para gobernar. Más bien significa reconocer que ninguna política puede orientarse sin una idea del comportamiento correcto que encarne el carácter de una sociedad democrática y justa.

A esa dimensión se suma la integridad. En tiempos de política espectacularizada, dominada por cálculos de imagen y estrategias de comunicación, Mujica produjo una impresión singular, en particular porque su autoridad se asentó en la percepción de la coherencia entre su ac-

ción y su palabra. Esa coherencia, por supuesto, no significa ausencia de contradicciones. Mujica las tuvo, y algunas fueron importantes. Pero su figura transmite algo cada vez más escaso en la vida pública: la sensación de que las convicciones no eran simplemente recursos discursivos, sino orientaciones efectivas de la vida. La integridad aparece entonces como una virtud política indispensable, porque permite que la palabra pública conserve densidad moral.

Otra respuesta que el libro reconstruye es la del ciudadano del mundo, como un aspecto de su autodefinición como un “viejo estoico”. Mujica fue un dirigente profundamente uruguayo y latinoamericano, pero su mirada desbordó con frecuencia los límites nacionales. Pensó los problemas de la humanidad como problemas comunes. La crisis ambiental, la desigualdad global, la violencia, la mercantilización de la vida y la incapacidad de la política para gobernar procesos económicos y técnicos cada vez más poderosos aparecen en su discurso como síntomas de una civilización que ha perdido orientación. Este cosmopolitismo estoico de Mujica proyecta las pertenencias locales hacia una responsabilidad global.

Finalmente, el libro propone pensar a Mujica desde la idea del hombre nuevo. Esta expresión tiene una larga historia en la izquierda latinoamericana y está cargada de expectativas, excesos y fracasos. En Mujica, el hombre nuevo no puede entenderse como un sujeto perfecto ni como una figura purificada por la revolución. Más bien aparece como una orientación práctica: es

alguien capaz de resistir la mercantilización, gobernar sus deseos, vivir con integridad, comprometerse con la justicia, cultivar vínculos significativos y reconocerse como parte de una comunidad humana y natural más amplia. No es el héroe que se coloca por encima de los demás, sino quien aprende a vivir de otra manera para contribuir a transformar el mundo común.

Así, Mujica se convierte en una excusa para la filosofía. No una excusa menor, sino una especialmente fecunda. A través de su vida y de sus palabras podemos volver a pensar la ética, la justicia, la libertad, la autenticidad, la alienación, la resonancia, la igualdad y la democracia. Su importancia no reside en haber formulado conceptos nuevos, sino en haber encarnado preguntas antiguas en un tiempo que tiende a olvidarlas. Nos recordó que la política no puede reducirse a administración, que la libertad no puede reducirse a consumo, que la igualdad no puede reducirse a consigna y que la vida buena no puede reducirse a éxito.

La pregunta “¿cómo he de vivir?” no admite una respuesta definitiva. Pero sí admite formas de orientación, y Mujica contribuye a ellas como alguien que devolvió espesor ético a la conversación pública. Tal vez ese sea su legado más profundo. En una época que corre demasiado, consume demasiado y piensa demasiado poco sobre sus fines, Mujica nos obliga a detenernos y volver a preguntar qué tipo de vida merece ser vivida y qué tipo de mundo debemos construir para que esa vida sea posible. ■



Fundación y refundación

por Cass Sunstein

Sobre los momentos constitucionales y los minimomentos.

13 de junio de 2026

*Traedme mi arco de oro ardiente: Traedme mis flechas de deseo:/ Traedme mi lanza: /¡Oh, nubes, desplegaos!/ ¡Traedme mi carro de fuego!/
No cesaré en la lucha mental, ni mi espada dormirá en mi mano:/ hasta que hayamos construido Jerusalén, / en la verde y agradable tierra de Inglaterra. - William Blake*

Introducción

A veces se dice que los derechos surgen de los agravios (*rights come from wrongs*).¹ La opresión religiosa podría conducir a una insistencia en la libertad de culto, tal vez en una disposición constitucional. Quienes han sufrido la censura podrían tratar de dar un lugar privilegiado a la libertad de expresión. Una experiencia vivida con ausencia de un procedimiento justo bien podría conducir a una insistencia, constitucionalizada o no, en el debido proceso legal. Si algunas personas han sido objeto de una discriminación generalizada, un principio de igualdad de trato podría parecer sumamente atractivo. La Constitución de los EE. UU. 1 La Constitución es atemporal, o al menos eso parece, pero también es, y de manera enfática, un producto de su época, y el contexto particular de la Revolución Americana, así como el trasfondo monárquico, actuaron como una gran sombra siempre presente.² La Constitución y la Revolución están inextricablemente entrelazadas. La Constitución original

se basaba en principios y compromisos identificables, entre los que se incluían (y quizás sobre todo) el rechazo de la monarquía en favor del republicanismo;³ la democracia deliberativa⁴; la separación de poderes; y las restricciones a la corrupción y al abuso de poder (siendo la Cláusula de Emolumentos un importante ejemplo textual). Estos principios y compromisos han demostrado ser duraderos, pero han sido cuestionados, con mayor o menor severidad, durante ciertos períodos. Estos desafíos han dado lugar a refundaciones periódicas, en forma de «momentos constitucionales», grandes y no tan grandes.⁵ Algunos momentos constitucionales, momentos medianos y momentos minúsculos son esencialmente burkeanos. Intentan recuperar los compromisos originales y renovarlos. Otros momentos constitucionales equivalen a revisiones significativas, con nuevos compromisos. Mi objetivo aquí es sugerir un paso relativamente modesto, o una serie de pasos relativamente modestos, hacia tal refundación, basados en las experiencias de las últimas décadas, y destinados a llevar adelante los principios fundacionales en nuevas circunstancias. Los pasos pertinentes podrían darse para sugerir algo así como un momento constitucional (o quizás un mini-momento constitucional), pero su ubicación inicial estaría en los decretos presidenciales, que emitiría el presidente de los Estados Uni-

¹Esta idea ha sido esbozada por diversas personas en diversos lugares. Cass R. Sunstein, *The Second Bill of Rights* (2.^a ed. 2025), es un ejemplo.

²Véase Gordon Wood, *The Radicalism of the American Revolution* (1991); Jon Elster, *America. Before 1787* (2025).

³Véase Gordon Wood, *The Creation of the American Republic, 1776-1787* (1969).

⁴Joseph Bessette, *The Mild Voice of Reason: Deliberative Democracy and American National Government* (1994).

⁵Véase Bruce A. Ackerman, *We the People, volumen 1: Foundations* (2018). Ackerman es, por supuesto, el principal teórico de los momentos constitucionales. No pretendo aquí discutir cuestiones de definición, ni si una reforma que no altera el texto real puede considerarse como tal momento.

dos. Con el tiempo podrían codificarse. Lo que sugiero aquí pretende ser un punto de partida. Podríamos imaginar otros pasos, y mucho más ambiciosos.⁶

Un poco de contexto: tuve el privilegio de formar parte del equipo de transición del presidente Obama en 2008, y también de mantener un contacto informal, más que ocasional, con el equipo de transición del presidente Biden en 2020. Existe una gran efervescencia de ideas, antes y después de las elecciones presidenciales, sobre lo que se podría hacer en las primeras semanas y meses, en particular.⁷ A menudo, las iniciativas centrales de las primeras semanas se redactan en los meses cruciales previos y posteriores a las elecciones. Por lo general, esas iniciativas responden directamente a errores o transgresiones, reales o percibidas, por parte de la administración inmediatamente anterior. Con frecuencia, esas iniciativas se inspiran en la Constitución; remiten a los ideales fundacionales, vistos a través de una lente presentista. Mientras escribo esto: un presidente electo demócrata, en 2028, probablemente tendría, por supuesto, una agenda de reformas mucho más ambiciosa que un presidente electo republicano, del que se esperaba que favoreciera un alto grado de continuidad con su predecesor republicano. Pero incluso si sale elegido un republicano, cabe anticipar nuevas direcciones, ya que la nueva Casa Blanca tratará de dejar su propia huella. Las siguientes ideas pretenden, de manera enfática, estar inspiradas en la Constitución. También pueden considerarse no ideológicas, con un gran énfasis en la estructura y el procedimiento.⁸ Por

supuesto, tampoco son en absoluto exhaustivas. En todos los casos, se trata de ideas generales que deben concretarse. No pretenden en modo alguno sugerir cuáles deberían ser las principales prioridades para cualquier tipo de refundación del siglo XXI. En cambio, pretenden captar lo que, en mi opinión, es una parte relativamente poco controvertida de la misma. Aunque no establezcan lo que, con el tiempo, sea un conjunto de normas estables y duraderas, hay un buen argumento a favor de cada una de ellas. Y si establecieran tal norma, la mayoría de ellas bien podrían considerarse como una solución a un problema de acción colectiva.⁹ Incluso pueden verse como acuerdos de control de armas, como suelen ser los principios constitucionales y cuasi-constitucionales. Tomemos, por ejemplo, la libertad de religión, que es muchas cosas, por supuesto, y una de ellas es una especie de tratado: no interferiremos en tu libertad de religión si tú no interfieres en la nuestra.

Libertad de expresión y libertad de prensa

En una medida que no se aprecia lo suficiente, los derechos constitucionales dependen de un alto grado de tolerancia oficial. Es esencial, por supuesto, que los tribunales protejan esos derechos, pero si el poder ejecutivo investiga y procesa a las personas por ejercer sus derechos, estas se verán muy disuadidas de ejercerlos, incluso si finalmente pudieran prevalecer en los tribunales. Si el poder ejecutivo no concede a las personas un amplio margen de libertad de expresión, los potenciales oradores se autocensurarán. Como se suele decir, el valor de la espa-

⁶Los lectores pueden seleccionar sus ejemplos preferidos. Podrían reflejar compromisos sustantivos que vayan mucho más allá de los pasos, en gran medida procedimentales, que aquí se proponen sobre órdenes ejecutivas concretas y memorandos presidenciales.

⁷La línea divisoria entre las órdenes ejecutivas y los memorandos presidenciales no es clara y nítida. Por lo general, se considera que las órdenes ejecutivas tienen un grado de formalidad algo mayor, y a menudo se las ve como más propensas a perdurar.

⁸Por supuesto, de un presidente electo demócrata podríamos imaginar una serie de órdenes ejecutivas sustantivas, destinadas a orientar el aparato del poder ejecutivo hacia nuevas direcciones sustantivas. (Consideremos, por poner solo un ejemplo, la protección del medio ambiente.) Incluso de un presidente electo republicano podríamos imaginar una serie de órdenes de este tipo, destinadas a dejar una huella distintiva. No me refiero aquí a órdenes ejecutivas sustantivas, aunque algunas de las ideas, especialmente la segunda, podrían traspasar esa línea.

⁹Ver Edna Ullmann-Margalit, *The Emergence of Norms* (1975).

da de Damocles no reside en que caiga, sino en que penda. El mero hecho de que penda puede suponer un problema devastador para el autogobierno republicano. Esto es válido para muchos derechos: libertad de expresión, libertad de religión, libertad contractual, derechos de propiedad, derechos al debido proceso y otros. En 1988, el presidente Reagan emitió un importante decreto ejecutivo sobre los derechos de propiedad, comprometiendo a su administración a respetar esos derechos y, en algunos aspectos, yendo más allá de lo que exige la Constitución.¹⁰ En vista de las graves controversias relacionadas con lo que muchas personas consideran serias restricciones por parte del poder ejecutivo a los derechos de la Primera Enmienda,¹¹ podríamos imaginar fácilmente un decreto ejecutivo correspondiente sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa. Podría declarar, por ejemplo, que no habrá discriminación por motivos de opinión en el poder ejecutivo ni por parte de este, y prohibir cualquier tipo de discriminación de este tipo por parte de los funcionarios públicos. Podría aplicar esa prohibición directamente a las decisiones de financiación.¹² También podría declarar que las personas nunca serán recompensadas ni castigadas por sus convicciones políticas o sus actividades políticas. Podría imponer restricciones firmes a todos los miembros del poder ejecutivo (incluidas las agencias independientes, sobre todo la Comisión Federal de Comunicaciones). Una orden ejecutiva de este tipo, emitida tal vez el primer día de una nueva administración, enviaría una señal esencial. Por sí sola, no sería exactamente una reforma creativa. Pero constituiría una especie de refundación literal.

No interferir en las decisiones procesales del Departamento de Justicia

Volvamos a la espada de Damocles. Si un ciudadano sabe que podría ser investigado y procesado, su mundo podría empezar a desmoronarse. La mera perspectiva de una investigación penal resulta amenazante para la mayoría de las personas. La separación de poderes tiene por objeto reducir los riesgos pertinentes. Pero no puede reducirlas a cero. Si los oponentes políticos de un alto cargo saben que están en peligro, es muy posible que actúen con cautela. Eso supone un duro golpe para los compromisos constitucionales. De la Declaración de Independencia: «Ha erigido una multitud de nuevas oficinas y ha enviado aquí enjambres de funcionarios para acosar a nuestro pueblo y devorar sus bienes». En virtud de la Constitución, el presidente tiene el poder y el deber de velar por que las leyes se ejecuten fielmente,¹³ lo que casi con toda seguridad significa que tiene la autoridad constitucional para supervisar al Departamento de Justicia.¹⁴ Pero la historia en este caso es complicada y turbia. No hay pruebas de que la generación fundadora contemplara el control presidencial sobre decisiones específicas de la fiscalía, y los presidentes han tendido en general a actuar con cautela respecto a tales decisiones. La razón es sencilla y está directamente relacionada con los principios constitucionales. Si un presidente decide a quién procesar, existen múltiples riesgos para el autogobierno republicano: represalias, castigo de enemigos políticos, disuasión de enemigos políticos, intercambios de favores de diversa índole.¹⁵ Una vez más, podríamos imaginar fácilmente un decreto ejecutivo que codificara las mejores prácticas. El punto más fundamental, que recoge lo mejor de esas buenas prácticas,

¹⁰Véase <https://www.reaganlibrary.gov/archives/speech/executive-order-12630-governmental-actions-andinterference-constitutionally>

¹¹Véase, p. ej., <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/addressing-risks-from-perkinscoe-llp/>

¹²Sobre cuestiones relevantes, véase Cass R. Sunstein, «Our Money or Your Life»: Higher Education and the First Amendment, 139 Harv L. Rev. F. 76 (2025).

¹³Véase el art. II, sección 3.

¹⁴Véase *Trump v. United States*, 603 U.S. 593 (2024).

¹⁵Zephyr Teachout, *Corruption in America: From Benjamin Franklin's Snuff Box to Citizens United* (2016).

es que las decisiones procesales nunca deben ser dirigidas o tomadas por el presidente; eso es simplemente demasiado peligroso. Una orden ejecutiva debería prohibir la dirección presidencial o de la Casa Blanca de tales decisiones. Sin duda, aquí hay algunas cuestiones difíciles y algunos problemas de delimitación. Ciertamente, no se debería impedir que el presidente hable con el fiscal general sobre asuntos procesales. Los informes de situación están bien. Lo menos controvertido es que la Casa Blanca pueda ser debidamente informada de lo que se avecina; la orden ejecutiva pertinente no debería prohibir eso. Debería abordar de manera más amplia la relación entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, y delimitar áreas de independencia, sobre todo con respecto a la decisión de a quién investigar por delitos penales. Podría delegar en el fiscal general la responsabilidad de elaborar directrices adicionales. La idea básica es que la orden debería impedir que la Casa Blanca, y el presidente personalmente, ordenen a los funcionarios iniciar procedimientos penales.¹⁶

Respeto a la independencia de la Junta de la Reserva Federal

En los últimos años, la Casa Blanca ha reivindicado su autoridad sobre las agencias «independientes»,¹⁷ y el Tribunal Supremo ha respaldado firmemente las medidas pertinentes, lo que ha puesto en grave duda el concepto mismo de independencia de las agencias.¹⁸ Las personas sensatas discuten las cuestiones jurídicas, así como las cuestiones de política pertinentes. ¿Es una buena idea que la Comisión Reguladora Nuclear sea independiente de la Casa Blanca? La respuesta depende de las previsiones sobre cómo actuaría probablemente la comisión con o sin un gra-

do de independencia. Algo similar podría decirse de otras agencias independientes, como la Comisión Federal de Comercio, la Junta Nacional de Relaciones Laborales y la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo. Debe admitirse que la Junta de la Reserva Federal presenta consideraciones distintivas e incluso únicas.¹⁹ Si esas consideraciones son jurídicamente relevantes podría ser objeto de una controversia justificada. Pero la cuestión política es clara: un banco nacional independiente es esencial para estabilizar la política económica. Si el presidente está a cargo de sus decisiones, las consideraciones electorales a corto plazo podrían causar un grave perjuicio. Este punto está, a su vez, asociado al compromiso fundacional con los principios republicanos. Si el presidente pudiera reducir los tipos de interés para aumentar sus propias perspectivas electorales, o las de su sucesor preferido, el proceso electoral se vería gravemente comprometido. Un primer paso firme, por parte de un presidente entrante inspirado en los ideales constitucionales, sería un decreto ejecutivo que comprometiera a la nueva administración con la independencia de la Junta de la Reserva Federal. Sin duda, hay detalles importantes que resolver, por ejemplo, en materia de regulación frente a la política monetaria. Pero existe un argumento convincente de que, con respecto a este último caso, la independencia de la Junta debe respetarse, y punto.²⁰ Algo similar puede decirse de los organismos encargados de recopilar información estadística, quizás sobre todo la Oficina de Estadísticas Laborales, independientemente de que dichos organismos sean o no formalmente independientes desde el punto de vista jurídico (teniendo en cuenta que la propia idea de independencia se encuentra ba-

¹⁶También sería una buena idea establecer límites a tales instrucciones en el caso de las investigaciones civiles.

¹⁷Véase <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/ensuring-accountability-for-all-agencies/>

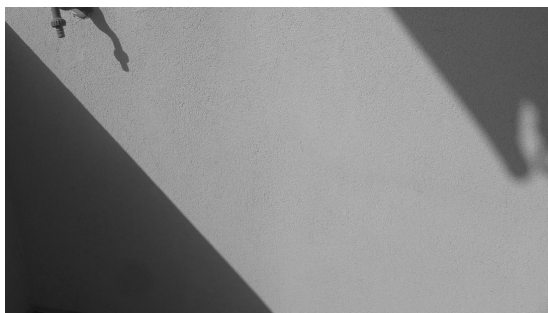
¹⁸Seila Law LLC contra la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, 591 U.S. 197 (2020); *Trump v. Wilcox*, 145 S. Ct. 1415 (2025).

¹⁹Véase Daniel Tarullo, *The Federal Reserve and the Constitution*, 97 So. Cal. L. Rev. 1 (2024), disponible en https://southerncalifornialawreview.com/wp-content/uploads/2024/05/Tarullo_Final.pdf

²⁰Sin duda, el significado de «independencia» aún está por determinar. Los debates son, sin duda, admisibles. Pero las decisiones finales sobre (por ejemplo) si subir o bajar los tipos de interés deben seguir recayendo en la Junta.

jo una nube constitucional).²¹ Algo similar podría decirse de otras agencias que durante mucho tiempo se han considerado independientes, sobre todo la Comisión Federal de Comunicaciones, cuya capacidad para comprometer el sistema de libertad de expresión, y para recompensar a las voces afines y castigar a las que no lo son, es palpable. La relación entre la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios y esas agencias podría replantearse de múltiples maneras. No hay una respuesta obvia a la pregunta de qué podría surgir concretamente de ese replanteamiento. Lo único cierto es que se necesita una «excepción», que establezca la independencia, para aquellas agencias y decisiones cuya sujeción a la voluntad presidencial amenazaría los objetivos de la época fundacional, sobre todo los relacionados con el autogobierno y el proceso electoral.

La domesticación del poder de indulto



El poder de indulto se entendía originalmente como un mecanismo para mostrar misericordia.²² Tenía un ámbito de aplicación muy limitado, a pesar de la amplitud de la concesión de autoridad al presidente. El poder de indulto se ha ampliado de formas muy diversas y en gran medida, y en absoluto para mejor.²³ Ese poder es una parte importante del derecho angloamericano, pero no debería ser un medio mediante el cual los presidentes puedan obtener recursos o

favores e indultar a miembros de su familia, sus amigos, sus aliados políticos o sus solicitantes. Lo que se necesita es sencillo: un proceso regularizado, con profesionalidad y límites. La especificación de tal orden ejecutiva no sería una tarea menor, pero la práctica histórica es una guía excelente; vale la pena establecer principios generales y basarse en las mejores prácticas,²⁴ sin eliminar la discrecionalidad última del presidente. Un enfoque de este tipo se basaría en la interpretación constitucional original de para qué servía el poder de indulto.

Conflictos de intereses

Inspirados por los compromisos de la época fundacional, los funcionarios públicos han tomado múltiples medidas para restringir los conflictos de intereses y el autocontrato, no solo a través de leyes, sino también mediante acciones ejecutivas.²⁴ Las normas éticas están diseñadas para prevenir la realidad y la apariencia de conducta indebida. Algunas de esas normas son esenciales; otras son absurdas, simbólicas y excesivas. Podemos imaginar prácticas que son claramente ilícitas —el soborno, por ejemplo, o la extorsión—. Podríamos imaginar prácticas que son claramente inobjektas —aceptar un puesto de trabajo bien remunerado tras tres años de servicio, por ejemplo, o pronunciar discursos públicos (remunerados) tras el servicio público sin revelar información clasificada o confidencial—. Podemos imaginar órdenes ejecutivas o memorandos presidenciales que irían demasiado lejos —por ejemplo, prohibiciones prolongadas o de por vida para trabajar en sectores regulados. El contenido preciso de cualquier documento de este tipo requiere una reflexión detenida. Pero no hay duda de que un nuevo presidente debería promulgar uno que prohíba los abusos más graves. Esos abusos se producen no solo en ca-

²¹Podríamos imaginar una serie de medidas en materia de integridad científica. Véase, por ejemplo, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/03/09/memorandum-heads-executive-departments-and-agencies-3-9-09/>

²²Véase Saikrishna Prakash, *The Presidential Pardon* (2026).

²³Para un excelente análisis, véase id. 8

²⁴Véase, por ejemplo, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/03/09/ethics-commitment-executive-branch-personnel>

sos de soborno, sino siempre que el presidente o los cargos políticos designados acepten cantidades significativas de dinero o regalos importantes, incluso si aparentemente están fuera de sus funciones oficiales. Una orden ejecutiva debería prohibir eso, incluso si se solapara con la legislación vigente, e incluso si tuviera excepciones de minimis (por ejemplo, una comida de 25 dólares).

Incapacidad presidencial: una presunción en contra de las demandas interpuestas por el presidente a título personal

El presidente se beneficia sin duda de la inmunidad presidencial²⁵ —y, así se espera, también lo hace la nación.²⁶ Es importante subrayar que se trata de una mera esperanza; bien podría pensarse que la existencia de la inmunidad presidencial va en contra del compromiso fundacional con el republicanismo y el rechazo de la monarquía. Independientemente de lo que pensemos sobre esa cuestión, una apreciación de ese compromiso sugiere que la nación bien podría beneficiarse de algo parecido a una incapacidad presidencial correspondiente. La cuestión aquí es sencilla: como regla general, el presidente no debería demandar a personas a título personal mientras ocupe el cargo. La razón es que, si el presidente es el demandante, este tiene demasiada autoridad. Ser demandado por el presidente supone enfrentarse a un poder excesivo, de una forma que coloca a quienes se encuentran en el lado contrario en una enorme desventaja. Podrían recibir amenazas de muerte. Podrían carecer de los recursos necesarios. Se verán sometidos a una especie de asedio. Sin duda, la demanda podría carecer de fundamento, pero su mera existencia puede generar todo tipo de consecuencias colaterales y tal vez incluso arruinar una vida. Es cierto que podemos imaginar fácilmente casos en los que la presunción en contra de tales demandas podría superarse; ¿qué pasaría si se robaba la propiedad personal del pre-

sidente? Pero incluso si ejercemos nuestra imaginación, la presunción debería ser firme. Si el presidente es objeto de algún tipo de conducta indebida, a título personal, sería deseable no interponer una demanda hasta que haya finalizado la presidencia. Sería conveniente establecer la presunción públicamente, probablemente en un decreto ejecutivo o un memorándum presidencial.

Una presunción en contra de los procesos penales contra funcionarios públicos de la administración anterior

La recomendación final es probablemente la más controvertida, y la que tiene una conexión más débil con los ideales fundacionales. La idea básica es que un presidente rara vez, o nunca, debería iniciar procedimientos penales contra personas que trabajaron en la administración anterior. Si, por ejemplo, a la administración actual le sigue una administración demócrata, la nueva administración debería mostrarse reacia a iniciar procesos, incluso si cree razonablemente que estos tienen fundamento. Ese principio de moderación refleja las mejores prácticas de larga data. Como se ha dicho, se trata de una presunción, no de una regla, pero tiene una defensa utilitarista basada en las normas: aunque podría conducir a resultados desafortunados (o peores) en casos concretos, podría estar ampliamente justificada, sobre todo por el hecho de que es importante evitar tanto la realidad como la apariencia de convertir los desacuerdos políticos, o las hostilidades políticas, en una pena de prisión. Por supuesto, hay argumentos en contra. Es rotundamente cierto que nadie debe estar por encima de la ley, y es cierto que una presunción, del tipo que yo tiendo a favorecer, podría eliminar un elemento disuasorio de la ilegalidad. Aun así, consideremos cuatro proposiciones, que admito que se presentan en forma de conclusiones breves más que de argumentos sostenidos: 10

²⁵ Véase *Trump v. United States*, 603 U.S. 593 (2024).

²⁶ *Id.*

(a) *La negativa del presidente Obama a procesar a personas de la administración Bush fue acertada. Cualquier procesamiento de ese tipo habría desviado y dividido al país, de forma perjudicial. Habría provocado un ciclo de recriminaciones. Habría centrado a la nación en las malas acciones del pasado (reales o no), en lugar de en las crisis nacionales apremiantes.*

(b) *El indulto de Richard Nixon por parte de Gerald Ford fue igualmente acertado. Evitó una mayor agitación nacional que habría hecho más daño que bien. Evitó que la atención nacional se centrara en acontecimientos pasados, lo que previsiblemente habría dividido a la nación.*

(c) *Cuando una administración procesa a altos cargos públicos, agita, o peor aún, a muchos millones de personas que apoyaron a la administración en la que prestaron servicio. Tales procesos causan una gran ira.*

(d) *Si la Administración B procesa a personas de la Administración A, podría crearse un ciclo de procesamientos. Hay todo tipo de efectos en cadena, muchos de ellos nada buenos. Una norma contra el procesamiento sería una especie de acuerdo de control de armas.²⁷ Si una administración la afirma, estará tendiendo una rama de olivo.*

Sin duda, aquí no hay pruebas. El análisis que tenga en cuenta todos los factores no puede realizarse a priori, y la presunción que recomiendo no se basa en la lógica, sino en una corazonada empírica, fundamentada en la historia. Es, en esencia, una apuesta. Podríamos imaginar situaciones en las que el enjuiciamiento de quienes trabajaron para una administración anterior tenga mucho sentido e incluso pueda parecer esencial, sobre todo con fines disuasorios. La presunción es refutable. Pero si se aplica, no será refutada fácilmente ni con frecuencia. El país se beneficiaría mucho de ello.

Regreso al futuro

La Constitución de los Estados Unidos se inspiró en principios y compromisos identificables. El documento en sí es una combinación de normas específicas y estándares amplios, no completamente especificados. Más precisamente, se trata de un continuo que va desde el primero (un presidente, y nada más) hasta el otro («el poder ejecutivo»). Periódicamente, Estados Unidos ha experimentado refundaciones, a veces en forma de renovaciones a gran escala (como durante la Guerra Civil, el New Deal y la Gran Sociedad), a veces en forma de reformas significativas que alternativamente recuerdan, replantean, repudian y renuevan los principios y compromisos originales (como durante la Era Progresista, el período posterior al Watergate y la Era Reagan). Algunas de esas reformas son megamomentos constitucionales (véanse las Enmiendas de la Guerra Civil); otras, micromomentos constitucionales (véanse las reformas posteriores al Watergate, aunque se podría discutir esa caracterización). Existe un argumento razonable a favor de otra refundación, tal vez en forma de renovación, pero sin duda en forma de reforma. Cada una de las siete ideas aquí presentadas puede entenderse como modesta y cautelosa (y esencialmente burkeana). Pero si se consideran en su conjunto, pueden verse como el núcleo, al menos, de un momento constitucional, y tal vez como un presagio de algo más grande y ambicioso.

—
Agradezco a Lee Bollinger sus valiosos comentarios sobre un borrador anterior. Este ensayo aparecerá en un volumen que editarán Bollinger y Geoffrey Stone en honor al 240.º aniversario de la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos. ■

²⁷Véase Edna Ullmann-Margalit, *The Emergence of Norms* (1975); Edna Ullmann-Margalit y Cass R. Sunstein, *Decisions and Social Norms* (2026).

Una ley contra el hacinamiento

por Gianella Bardazano

Una iniciativa uruguaya de cupo carcelario (numerus clausus) propone poner un límite legal a la población encarcelada. ¿Quién debe fijar ese límite: los tribunales o la ley?

16 de junio de 2026

Uruguay tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo (cerca a 490 personas presas cada 100.000 habitantes) y la más alta de América del Sur. Esa cifra se traduce, puertas adentro, en hacinamiento. Y del hacinamiento hay una forma cómoda de hablar, que consiste en tratarlo como se trata el clima. Se lo describe con cifras alarmantes, se lamenta su persistencia y se vuelve a empezar al año siguiente con números un poco peores. La metáfora meteorológica tiene una ventaja política, porque convierte una decisión en una fatalidad. El hacinamiento no es el clima. Es el resultado agregado de decisiones (cuántas conductas se castigan con cárcel, con qué probabilidad y por cuánto tiempo) y de una omisión, la de fijar un límite a cuántas personas el Estado puede alojar sin degradarlas. Y lo que es producto de reglas puede, en principio, deshacerse con reglas.

La primera reacción ante una cárcel abarrotada es construir otra. Es una reacción intuitiva e ineficaz. La literatura comparada coincide en un punto incómodo. La construcción llega siempre después del hacinamiento, nunca lo previene, y tiende a poblarse al poco tiempo de inaugurarse. En los Estados Unidos, más de la mitad de las cárceles se levantaron en las dos décadas de mayor expansión, y aun así el sistema siguió funcionando por encima de su capacidad. La razón es conocida. La oferta de plazas opera como una invitación, no como un techo. Y cuando la construcción no alcanza, queda el recurso conceptual de redefinir la capacidad. La “capacidad” es una convención administrativa, no un dato natural, y las administraciones la corren hacia arriba cuando les conviene (de la capacidad de

diseño a la capacidad “operativa”, y de ahí a la “emergencia”), hasta hacer desaparecer el sobrecupo por la vía de cambiar la unidad de medida.

Importa, además, desarmar un supuesto. El crecimiento de la población encarcelada no acompaña al delito. Acompaña a la política criminal. Donde se lo ha medido con cuidado, el aumento de la encarcelación se explica por decisiones punitivas (más ingresos por delito, más tiempo de condena) y no por más delito; durante décadas las tasas de prisionización se mantuvieron estables, hasta que una decisión deliberada las disparó. Ahora bien, esas decisiones no son neutras frente a la Constitución. Cuando producen hacinamiento, contradicen el artículo 26, que prohíbe que las cárceles sirvan para mortificar (lo que el derecho internacional llama trato cruel, inhumano o degradante) y les ordena perseguir la reeducación de las personas que alojan (así como, del otro lado del Río de la Plata, ordena que sean para seguridad y no para castigo). Entonces, si el motor es normativo, el freno también puede serlo.

Ese freno toma prestada una vieja técnica de cupo, el *numerus clausus*. La regla es simple de enunciar. La población de un establecimiento no puede exceder su cupo. Para que no sea una declaración más sin transformaciones reales, necesita tres piezas. La primera es una definición legal de plaza (cuánto espacio, en qué condiciones), sustraída a la discrecionalidad de quien administra, de modo que la capacidad no pueda redefinirse a voluntad. La segunda es la publicidad de la capacidad declarada y la ocupación real, como datos accesibles y actualizados, porque un límite que no puede verificarse no es un límite. La

tercera es una consecuencia normativa. Alcanzado el cupo, no se admiten ingresos por encima de él, y la descompresión se ordena mediante un mecanismo de egreso reglado (una nómina con criterios de prioridad, sujeta a control judicial), de manera que cada ingreso por sobre el límite exija una salida o una medida alternativa al encarcelamiento. No se trata de una amnistía ni de una puerta que se abre sola. Es una regla que obliga a elegir, a la luz del día, quién ocupa la plaza escasa.

Hasta aquí, un problema de ingeniería institucional. La cuestión más interesante es otra, y es quién debe fijar el límite. El cupo, de hecho, ya existe, fijado por la puerta de atrás. Cuando el legislador no lo establece, terminan estableciéndolo los jueces. La Corte Constitucional de Colombia declaró en 1998 un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario, al verificar que la vulneración masiva de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad no era un accidente sino una condición estructural sostenida por omisiones del Estado, y volvió sobre la figura décadas después, ante la persistencia del problema. La Corte argentina, en Verbitsky (2005), enfrentó el hacinamiento de las comisarías bonaerenses por la vía del remedio estructural. Y la Corte Interamericana fue más lejos. En el asunto del Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, ante una densidad cercana al 200 %, razonó que la pena cumplida en esas condiciones inflige un sufrimiento que duplica el previsto; ordenó computar dos días por cada día efectivamente cumplido y dispuso, lisa y llanamente, la prohibición de nuevos ingresos. Un *numerus clausus* fijado caso por caso por tribunales nacionales o internacionales.

Que los jueces fijen el límite es el síntoma de que algo no se hizo antes, no un ideal. La declaración judicial constata el problema pero no lo resuelve, y cuando el tribunal ordena un límite la vía arrastra tres debilidades. Depende de que cada situación sea litigada hasta el final. Su eficacia queda atada a la supervisión y a la voluntad política de cumplir. Y es reversible. En Estados

Unidos, los topes de población que los tribunales habían fijado en acuerdos homologados (*consent decrees*) se desactivaron cuando una ley federal, en 1995, dificultó su ejecución. Lo que hace falta es una regla que opere antes. Una regla legal de cupo no necesita ser conquistada pleito a pleito, tiene la estabilidad de la fuente legislativa y, sobre todo, devuelve la decisión a quien debe tomarla. En una democracia, cuánto y cómo se castiga es algo que define la comunidad directamente o a través de su parlamento, y no algo que se extrae, a regañadientes, de una sentencia. Fijar el límite por ley es, además, lo más respetuoso de la división de poderes. El Parlamento pone el techo y al juez le queda aplicarlo.

La iniciativa, además, dice algo por su origen. La promueven organizaciones de la sociedad civil, con el protagonismo de *Familias Presentes* (una asociación civil que nuclea a familiares de personas privadas de libertad), y tiene por delante dos caminos. Puede tomarla el Parlamento para su consideración, o puede impulsarla la propia ciudadanía a través de la iniciativa legislativa popular, uno de los mecanismos de democracia directa que distinguen al constitucionalismo uruguayo. En cualquiera de los dos, el límite al castigo se decide donde debe decidirse, en el terreno del debate democrático.

Queda la objeción previsible. ¿No es esto resignar seguridad? La respuesta empírica es que los retornos de seguridad de encarcelar más son muy modestos, que buena parte de las personas presas no lo está por delitos violentos y que las alternativas al encarcelamiento son escasamente consideradas. La respuesta de fondo es otra. El *numerus clausus* no decide encarcelar menos. Decide que el Estado no puede encarcelar por encima de lo que él mismo declaró poder hacer con dignidad. Si la comunidad quiere castigar más, el camino está abierto, y consiste en proveer las plazas, y el presupuesto, a la vista de todos. Lo que la regla impide es el atajo de castigar más fingiendo que la cárcel es elástica.

Ahí reside su mayor virtud. El cupo carcelario no es, en el fondo, una técnica penitencia-

ria, sino un dispositivo de honestidad institucional. Redirige la acción del Estado hacia el cumplimiento de la Constitución y pone el sistema penal al servicio del mandato del artículo 26 que las decisiones de política criminal vienen vaciando en los hechos. Obliga al Estado a hacerse cargo de sus decisiones punitivas, a ponerles número y nombre, y a no descargar su costo, en si-

lencio, sobre los cuerpos amontonados que nadie cuenta. Convierte el hacinamiento, de fatalidad administrativa, en lo que siempre fue, una decisión. Y el efecto contrario al mandato de no mortificar que produjeron las decisiones punitivas puede revertirse con decisiones que honren nuestros compromisos constitucionales. ■

**To ~~rejeet~~ the
political is to ~~rejeet~~
your existence.**

¿Hay lugar para la política en la destitución judicial?

por Emiliano Vitaliani

El caso Moliné O'Connor en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

16 de junio de 2026

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está examinando actualmente la destitución del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Argentina Eduardo Moliné O'Connor en 2003. Es poco probable que el caso sorprenda a quienes siguen la jurisprudencia de la Corte. A lo largo de las últimas décadas, la CIDH ha desarrollado una sólida doctrina sobre la independencia judicial y la destitución que favorece claramente la posición de Moliné O'Connor. Sin embargo, el caso también pone de manifiesto tensiones más profundas en la interpretación que hace la Corte de la independencia judicial, especialmente en lo que respecta a los tribunales supremos que se enfrentan a crisis más amplias de legitimidad institucional.

Eduardo Moliné O'Connor fue nombrado juez en 1990. Tras la elección de Carlos Menem como presidente, este amplió la Corte, aumentando el número de jueces de cinco a nueve, lo que le permitió nombrar a una parte significativa de la Corte. Además, dado que los jueces Bacque y Caballero dimitieron en protesta contra el plan de ampliación de la Corte, Menem pudo nombrar a dos jueces adicionales más allá de las vacantes creadas por la ampliación de la Corte. Con el tiempo, estos nombrados se conocieron como la «mayoría automática», ya que se entendía ampliamente que fallaban automáticamente a favor de las posiciones del gobierno de Menem. Durante la década de los noventa, la situación económica se deterioró y los escándalos de corrupción se hicieron frecuentes, lo que condujo a la crisis de 2001, marcada por el lema «todos deben irse».

En 2003, Kirchner fue elegido presidente y solicitó la destitución de los magistrados de la denominada «mayoría automática». Tres magistrados dimitieron y dos, entre ellos Moliné O'Connor, fueron destituidos con el argumento de que habían abdicado de su función judicial al no revisar una decisión arbitral. La destitución tuvo lugar, por tanto, en el contexto de una crisis más amplia relativa a la credibilidad y la legitimidad del Tribunal, lo que brindó una oportunidad útil para reflexionar sobre la relación entre la independencia judicial y la legitimidad.

El futuro del caso contra Argentina

No es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ocupa de destituciones. Por el contrario, ha mantenido de manera constante una doctrina al respecto. Desde el primer caso en el que tuvo que abordar la destitución de magistrados en Perú, la Corte ha sostenido que las garantías judiciales (art. 8 de la Convención) son aplicables a los procedimientos de destitución debido a su carácter adjudicativo y a sus efectos sobre los derechos humanos.

Partiendo de esta premisa, la Corte sostiene que los procedimientos de destitución deben ser independientes e imparciales y garantizar a la persona sometida a juicio el derecho a la defensa, al igual que en un procedimiento judicial ordinario. Además, en el Caso del Tribunal Constitucional, la Corte también destacó que la independencia debe garantizarse especialmente en el caso de los magistrados de los tribunales supremos debido a la naturaleza de los asuntos de su competencia (párr. 75). En el Caso Camba Cam-

pos, la Corte sostuvo que los magistrados solo pueden ser destituidos por «falta grave o incompetencia», y esto se confirmó en el Caso Ávalos Ríos. En el mismo caso, la Corte señaló que los tribunales son «garantes de los derechos humanos» (párr. 191) y, por lo tanto, el juicio político debe ser «objetivo e imparcial» (párr. 88) como requisito previo para el Estado de derecho. Estos principios también se mantuvieron en otras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como *Reverón Trujillo y Quintana Coello*, lo que da lugar a una línea jurisprudencial bien establecida sobre los procesos de destitución judicial. En resumen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en repetidas ocasiones que la mayoría de las garantías exigidas en un proceso judicial ordinario también deben estar presentes en los procesos de destitución.



En este contexto, es probable que se declare responsable a Argentina. En primer lugar, el motivo del Congreso para destituir a Moliné O'Connor fue que consideró inaceptable su decisión en el caso Meller, resuelto por la Corte Suprema en 2002. Sin embargo, las decisiones judiciales están explícitamente excluidas como motivos válidos de destitución en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, la entonces primera dama, Cristina Fernández de Kirchner, era la presidenta de la Comisión de Juicio Político del Senado en ese momento, lo que se ha interpretado

como una violación de la necesaria imparcialidad del Senado como institución juzgadora.

¿Hay lugar para la política en el juicio político?

En español, el juicio político se traduce como «juicios políticos», lo que pone de relieve la naturaleza simultáneamente judicial y política del juicio político. Curiosamente, el magistrado Hernández López de la CIDH señaló durante la audiencia en el sistema interamericano que, si las garantías penales se trasladaran a los procedimientos de juicio político, quedaría poco espacio para la política. A continuación, argumentaré que la jurisprudencia de la CIDH sobre el juicio político de jueces se basa en una interpretación inverosímil de la distinción entre derecho y política en el derecho constitucional.

La jurisprudencia interamericana sobre el juicio político de jueces deja poco o ningún espacio para la política en el derecho constitucional. Al aplicar las normas de los juicios ordinarios a los juicios políticos, la Corte bloquea la introducción de consideraciones políticas en los procedimientos de juicio político. La Corte exige a los actores políticos que se comporten de manera imparcial e independiente, pero los representantes difícilmente pueden ser independientes de sus partidos y votantes, ya que están sujetos a la disciplina de partido y a la rendición de cuentas electoral. Por lo tanto, los representantes difícilmente pueden ser independientes de la política durante un proceso de destitución, ya sea que tengamos una concepción de la política centrada en los partidos o en los ciudadanos.

Además, la imposibilidad de iniciar procedimientos de destitución sobre la base de las interpretaciones constitucionales de los tribunales supremos parece presuponer que esas interpretaciones son indiscutibles, en lugar de ser objeto de desacuerdo social y político. Esto conduce a una concepción juriscéntrica de la interpretación constitucional que traza una distinción nítida entre el derecho y la política. Sin embargo, el derecho constitucional se refiere a des-

acuerdos fundamentales sobre los derechos, la igualdad, la propiedad y la organización de la propia comunidad política. Los tribunales supremos, por lo tanto, no se limitan a aplicar el derecho constitucional y a garantizar los derechos, sino que ejercen autoridad constitucional sobre cuestiones políticas profundamente controvertidas. Por supuesto, si creemos que los jueces son «garantes de los derechos humanos», como sostiene el Tribunal, no tendría sentido evaluar su desempeño constitucional. Sin embargo, si realmente son garantes de los derechos constitucionales es precisamente lo que se discute en los procesos de destitución, por lo que no puede servir como premisa para su evaluación. Cuando pasamos a la concepción subyacente del derecho en el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos (TIHD), surge un argumento más profundo. Como se ha señalado anteriormente, el Tribunal entiende la adjudicación constitucional como una tarea objetiva que, cuando la realizan los tribunales, garantiza los derechos humanos. El derecho constitucional, sin embargo, se refiere a nuestras concepciones básicas como comunidades políticas, que son inevitablemente controvertidas y, por lo tanto, políticas. Los jueces del tribunal supremo deciden sobre cuestiones muy controvertidas, como el aborto, la propiedad, la igualdad y el alcance de los derechos sociales, como la vivienda y la educación. Estas cuestiones son objeto de profunda controversia en la arena política y, por lo tanto, se encuentran en el centro de los desacuerdos que caracterizan a la política. Los tribunales a veces reconocen derechos que no habían sido reconocidos anteriormente en la doctrina constitucional, como hizo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos con el derecho a la intimidad en el caso *Casey*. Sin embargo, el Tribunal sostiene que los tribunales constitucionales deberían estar aún más protegidos de la política, a la que considera menos política que el derecho ordinario. Según la interpretación de la Corte Interamericana, cuestiones como las mencionadas anteriormente deberían estar sujetas a un menor control político, incluso cuando se re-

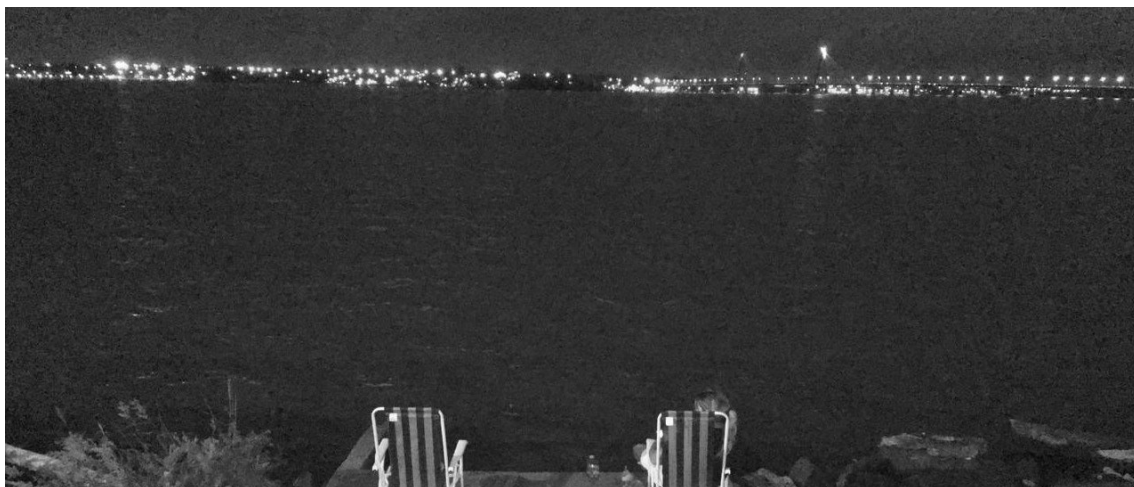
fieren a nuestros desacuerdos constitucionales más fundamentales.

La concepción de los magistrados como actores apolíticos también contradice las prácticas constitucionales actuales. En muchas jurisdicciones, los magistrados son seleccionados mediante procedimientos abiertamente políticos con algunas restricciones técnicas, como el nombramiento presidencial y la confirmación por el Senado. De hecho, el propio Moline O'Connor se benefició no solo del nombramiento y la confirmación políticos, sino también de la decisión política de «llenar» el tribunal, lo que abrió nuevas vacantes. Esto contrasta con la selección de los jueces de instancias inferiores, que a veces se seleccionan mediante procedimientos más técnicos.

Muchos sistemas constitucionales (Argentina y Brasil, por ejemplo) parecen reconocer que hay algo intrínsecamente político en la adjudicación constitucional y, por lo tanto, aceptan consideraciones políticas a la hora de decidir quién ejercerá la máxima autoridad constitucional. En este contexto, el enfoque de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la destitución judicial no solo presenta problemas teóricos, sino que también parece estar en desacuerdo con las prácticas constitucionales latinoamericanas. Además, los tribunales no controlan «ni la espada ni la bolsa», como dijo Hamilton. Por lo tanto, su influencia depende de que otros actores acepten y sigan sus opiniones. En contextos en los que los ciudadanos y los representantes desacreditan profundamente las decisiones de los tribunales superiores, estos se vuelven menos capaces de persuadir a los actores relevantes y, en consecuencia, de desempeñar su función constitucional. Esto es lo que ocurrió en Argentina, donde la sociedad exigió un profundo cambio político e institucional, pero una institución que se había convertido en símbolo del antiguo sistema quedó, por ello, profundamente desacreditada. En contextos como este, la legitimidad sociológica de los tribunales superiores se ve socavada, lo que les impide convencer

a su público de la validez de sus interpretaciones constitucionales. El juicio político, entonces, aparece como una posible respuesta a situaciones en las que los tribunales carecen del apoyo público suficiente para desempeñar eficazmente su función constitucional. Decir que la política es aceptable en el juicio político no significa, sin embargo, que la independencia no sea un valor relevante. Lo es. Los jueces no deben estar sujetos a la voluntad de la política ordinaria, y tienen una voz valiosa en la interpretación constitucional que debe protegerse. Esta voz, además, no podría existir si estuvieran sometidos a una presión política constante. Sin embargo, afirmar que los jueces requieren cierto grado de independencia no es lo mismo que decir que deben estar completamente aislados de la política, lo cual también sería inverosímil dada la naturaleza parcialmente política de su tarea. Por lo tanto, debemos pensar en el juicio político de manera que se garantice cierto nivel de independencia judicial y, al mismo tiempo, se evite que la adjudicación constitucional quede totalmente subordinada a la política partidista ordinaria. Cuando pensamos en esta necesidad, los procedimientos se presentan como una herramienta institucional plausible.

Durante las audiencias del caso Moliné O'Connor, se argumentó que la alternativa a una interpretación estricta de los motivos de juicio político era la pura voluntad presidencial, como demuestran muchos otros intentos de destituir a jueces. Sin embargo, bajo un enfoque que valora la independencia judicial y reconoce al mismo tiempo la naturaleza política de la interpretación constitucional, es posible pensar que lo que garantiza la independencia es la necesidad de mayorías especiales en las cámaras que respondan a diferentes tipos de representación y la posibilidad de que los jueces expongan sus argumentos públicamente. La dificultad de alcanzar estas mayorías cualificadas en ambas cámaras hace que el juicio político solo sea posible cuando existe un amplio acuerdo transpartidista que demuestre un rechazo generalizado hacia los jueces. Los procedimientos, por lo tanto, funcionan como salvaguardias contra la voluntad arbitraria de un partido, exigiendo un acuerdo más amplio sobre la necesidad de destituir a un juez. El caso Moliné O'Connor revela así las tensiones que surgen cuando las doctrinas diseñadas para aislar a los tribunales de la política se enfrentan a amplias demandas multipartidistas de responsabilidad judicial. ■



Inclús motos en vorera



Sueños de restauración o utopía resalista

por Andrés Sajó

Ante el abuso populista, algunas ideas para restaurar de nuestras maltrechas instituciones.

16 de junio de 2026

En medio del ruido de los interminables debates sobre la naturaleza, los nombres y las causas de las actuales desgracias de la democracia, queda relativamente poco esfuerzo para imaginar cómo restaurar la democracia perdida en el feliz escenario en el que la gente se lleva el premio gordo electoral y puede restablecer la democracia constitucional. Por cierto, *restauración* es un término engañoso. Las democracias no son muebles antiguos que puedan devolverse a su estado original. Años de captura institucional, cambio social, redistribución y trauma político dejan huellas. El orden posiliberal no se parecerá al orden anterior a la usurpación. Ni debería hacerlo. Una restauración digna de ese nombre implica reparación, rediseño y aprendizaje institucional y cultural.

Entre las circunstancias del abuso populista, quienes se oponen a este giro de los acontecimientos a menudo especulan únicamente sobre cómo ganar unas elecciones en un régimen populista-bonapartista cada vez más opresivo. Uno de los errores comunes es identificar estas democracias plebiscitarias de líderes iliberales con la autocracia.

La autocracia es el régimen zarista heredado de Pedro el Grande de Rusia. El discurso sobre la autocracia exagera el problema y oscurece las posibles salidas. Las elecciones sobreviven, aunque cada vez se parezcan más a partidos de fútbol en los que un equipo nombra al árbitro y mueve los postes de la portería, casi a su antojo. Sin embargo, la incertidumbre persiste en los regímenes populistas. Ejemplos contemporáneos (Brasil, Ecuador, Hungría) sugieren que la competencia electoral desleal aún puede derro-

car gobiernos, al menos cuando los astros se alinean.

Para que se produzca el milagro de expulsar al usurpador mediante las urnas, se necesita esperanza. Durante el largo invierno del gobierno populista, se necesita una visión realista de un futuro mejor tras las elecciones para movilizar el cambio. De lo contrario, prevalecerá la creencia de que el régimen gobernará para siempre, incluso tras su retirada temporal. Pero en Hungría, tanto antes de las elecciones parlamentarias de 2022 como de las de 2026, los partidarios del apaciguamiento afirmaban que, aunque la oposición ganara las elecciones, poco se podría hacer después, debido a las instituciones capturadas que quedarían y a otros grilletes constitucionales, como los funcionarios leales que actúan como actores con derecho de veto. El antiguo régimen pierde el poder, pero sigue gobernando a través de actores con poder de veto bien afianzados. Se argumentaba que una restauración democrática significativa es imposible dentro de la legalidad. Un cambio significativo requiere apartarse de la legalidad, lo que significa una ruptura constitucional. La ruptura constitucional implica inestabilidad y guerra civil.

Esto es pesimismo constitucional disfrazado de virtud constitucional. Es paralizante. La gente rara vez se moviliza por el cambio si el éxito solo promete una decepción administrada con mayor competencia.

La gente necesita esperanza para plantar cara al régimen amenazante, pero la esperanza es un bien escaso en los cielos cada vez más cerrados del gobierno populista, donde la inamovilidad irradia desde arriba. Por eso importa la imaginación constitucional.

La movilización política requiere algo más que ira contra el presente. Requiere una imagen creíble de la vida tras la victoria. Requiere argumentos razonables de que las instituciones existentes pueden cambiarse sin revolución ni desorden, dentro de los cuatro tranquilizadores pilares del Estado de derecho. De lo contrario, la esperanza se vuelve irracional, la resignación se vuelve prudente, y los ciudadanos seguirán creyendo que incluso una oposición exitosa se limita a reorganizar el personal sin tocar las estructuras.

Lo que se necesita es una utopía realista de justicia impartida. En lo que respecta al Estado y al gobierno, esto significa una utopía constitucional realista.

Esta idea le debe algo a [Karl Mannheim](#). No se trata de un intento de rediseñar la humanidad. Pretende mostrar que el autogobierno constitucional en las condiciones contemporáneas desfavorables puede lograrse sin un coste prohibitivo. Una ambición limitada, pero con apariencia de probabilidad.

El filósofo alemán [Ernst Bloch](#) argumentó que imaginar el futuro es en sí mismo una forma de autodeterminación ante lo posible. La imaginación constitucional desempeña precisamente esta función. Transforma la democracia de nostalgia en un proyecto creíble.

Quizá la utopía sea insuficiente para determinar un futuro, pero determinará qué tipo de demócrata uno desea ser y en qué se convertirá.

Por supuesto, la imaginación constitucional por sí sola es insuficiente. El electorado se preocupa más por la justicia, la dignidad y las perspectivas económicas que por la arquitectura constitucional. Pero sin imaginación, no hay un plan para la transición al servicio de la reconstitución democrática.

Un obstáculo para la imaginación constitucional en Europa continental sigue siendo una cultura jurídica excesivamente apegada al positivismo legal: la creencia de que todo lo que se ha promulgado siguiendo el procedimiento adecuado adquiere una legitimidad casi sagrada. El «posi-

tivismo legal», es decir, el poder incondicional de las leyes debidamente promulgadas, proyecta una larga sombra, especialmente en los países poscomunistas. El «positivismo legal» es la actitud alemana que permitió a la profesión jurídica alemana servir al nazismo. Todas las fechorías (malversación de activos estatales, cierre de medios de comunicación, distorsión de la imparcialidad de las elecciones, etc.) fueron consagradas en la ley por el régimen populista. Así es como [gobernar haciendo trampa](#) se normalizó y se convirtió en algo indudablemente lícito. (Muchos jueces polacos —y anteriormente algunos jueces en Venezuela— han resistido la tentación de la legalidad servil; mucho menos en Hungría.)

El efecto práctico de esta confusión entre el Estado de derecho y la legalidad es bien conocido. ¿Toma de control de los medios de comunicación públicos? Debidamente promulgado, por lo tanto legal. ¿Distorsionar la competencia electoral? Legal. ¿Afianzar a los funcionarios leales? Legal. ¿Redistribuir los activos públicos mediante ingeniería legislativa fraudulenta? Legal.

El jurista constitucionalista aparece entonces para explicar, con seriedad académica, que la legalidad no deja alternativa.

Sin embargo, el Estado de derecho no es obediencia administrativa. Son principios, razón, equidad y decencia —respaldados por la tradición y arraigados en los hábitos profesionales—.

Para resistir las cadenas de la mezquindad legalista, el Estado de derecho ofrece numerosas oportunidades. Esto es imaginación constitucional en acción. Al fin y al cabo, el propósito del Estado de derecho, a pesar de su función habitual de protección del statu quo («seguridad jurídica»), no es preservar todos los acuerdos promulgados independientemente de su función. Como observó Martin Krygier, el objetivo del Estado de derecho es el [control del poder](#). Ese principio deja más margen para la recuperación democrática de lo que admite el fatalismo jurídico.

El Estado de derecho tal y como lo conocemos no descarta una aplicación innovadora de sus

principios fundamentales. Cuando las leyes sirven a fines inconstitucionales, como la concentración y perpetuación inconstitucionales del poder político, la legalización del robo de activos estatales o el indulto a enemigos de la democracia —en otras palabras, cuando prevalece la **anarquía legal**—, el examen de la finalidad permitirá al juez declarar nulo y sin efecto el acto. Este **vigilantismo militante** no es desconocido en la interpretación jurídica tradicional y conforme al Estado de derecho, por ejemplo, cuando se trata de derechos constitucionales fundamentales (para EE. UU., véase, entre otros, [*Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah*]).

Los sistemas constitucionales ya cuentan con técnicas para resistirse a las formas jurídicas utilizadas con fines inconstitucionales: el examen de la finalidad, los principios antifraude, la proporcionalidad, la autoprotección democrática. La imaginación jurídica no es nihilismo jurídico y la transformación es una utopía realista.

Supongamos que la transición tiene éxito. Pero, ¿qué ocurre después? ¿Qué ocurre al día siguiente, cuando se evapora la euforia de la toma de la Bastilla? ¿Será el día siguiente un día decepcionante en el que todo sigue igual? Esta posibilidad decepcionante no es descabellada. La Bastilla ha sido tomada. Los cánticos se desvanecen, es decir, las entrevistas y los comunicados de prensa de los vencedores ya no son noticia de última hora. El partido vencedor descubre que las constituciones, las instituciones y las burocracias siguen ahí, lo cual resulta incómodo.

Una mayoría recién elegida puede adquirir de repente un poder enorme y, como en el caso de Hungría, incluso capacidad constituyente. La oposición de ayer se convierte en el soberano constitucional de hoy. Los tribunales pueden ser rediseñados. Los cargos de larga duración, destituidos. Las instituciones arraigadas, reorganizadas. La constitución heredada se convierte en una barrera de pergamino. Técnicamente, la mayoría en el Parlamento húngaro podría hacer hoy lo que quisiera, o lo que le apeteciera a su líder de presencia carismática. En Hungría, las

elecciones de 2026 dieron como resultado una mayoría constituyente (2/3) con el 53 % de los votos. Debido a una deficiencia en el diseño constitucional que existe en Hungría desde 1989, esta mayoría, que representa a la minoría de la población, puede enmendar la Constitución. De la noche a la mañana. Bueno, en unos ocho días laborables.

La tentación se cuela silenciosamente, pero con rapidez.

El peligro no son necesariamente las malas intenciones. El peligro es el síndrome de omnipotencia. La tentación es continuar con una democracia de líder plebiscitario, en la tradición gaulista como en el mejor de los casos. Esto es especialmente grave en sistemas con frenos constitucionales débiles: sin federalismo, sin bicameralismo, con normas flexibles de enmienda constitucional. El poder ejecutivo concentrado, que da lugar a la **dictadura electiva** del ejecutivo, las culturas políticas poco conocidas por su autoconciencia, y la falta de sensibilidad constitucional y de simpatía y comprensión hacia el formalismo jurídico agravan el problema.

La cuestión central pasa a ser, por tanto: ¿cómo escapar de las limitaciones heredadas sin normalizar la arbitrariedad, cómo superar la falta de un diálogo democrático basado en la razón?

La transición posiliberal debe concebirse como autolimitada desde el primer día

Persisten los problemas prácticos: ¿qué ocurre si los guardianes de retaguardia de la Constitución antiliberal y antidemocrática no dimiten? La Constitución se modificará de la noche a la mañana y estos funcionarios serán destituidos. O bien algunos de los funcionarios afectados seguirán en sus puestos, legitimando humildemente todas las medidas del nuevo Gobierno. El oportunismo no conoce límites.

Ambos escenarios siguen siendo problemáticos.

En primer lugar, según la legislación vinculante de la UE, algunos de los cargos en cuestión se consideran inamovibles sin causa justifi-

cada, y demostrar dicha causa resulta muy problemático o, como mínimo, difícil. La reorganización institucional tampoco es siempre una justificación suficiente. El despido por falta de moralidad (aunque fácil de demostrar) no funciona: destituir a un alto dignatario que actuó al servicio de los fines indecentes del régimen respetando la ley también es problemático desde el punto de vista jurídico, aunque esté moralmente justificado. El caso de los jueces nombrados indebidamente es una cuestión diferente y, según los tribunales transnacionales europeos, dichas personas pueden considerarse **no jueces**, pero en Hungría y en muchos otros regímenes populistas los nombramientos se ajustan a la ley manipulada. En una interpretación militante y adecuadamente amplia del Estado de derecho en una situación de transición, al dismantelar instituciones y leyes inconstitucionales, se puede argumentar que estas leyes servían a fines constitucionalmente indebidos y son, por esa razón, nulas y, por lo tanto, los nombramientos también lo son. Sin embargo, resulta difícil aceptar, dentro del marco del pensamiento tradicional sobre el Estado de derecho, que un juez pueda ser destituido por incumplimiento de sus funciones simplemente por seguir la ley vigente, incluso si su conducta ha contribuido a la consolidación de un régimen opresivo y de expropiación de los bienes públicos. Al fin y al cabo, los regímenes populistas, antes de caer en el despotismo autocrático, no aplican métodos manifiestamente inhumanos y los jueces no son instrumentos del terror de Estado.

En segundo lugar, y lo que es más importante, los controles y contrapesos constitucionales, el control de constitucionalidad, son funciones indispensables para una democracia constitucional, especialmente en países como Hungría o Polonia, con un primer ministro omnipotente al mando del Estado según la tradición de Westminster de dictadura electiva. No existe federalismo, bicameralismo ni normas estrictas de enmienda constitucional; la cultura constitucional es débil, y la nueva mayoría pública exige

represalias, probablemente con un formalismo jurídico mínimo. Es poco probable que los leales heredados reinterpreten la ley heredada en un sentido constitucionalista liberal, aunque no es particularmente difícil insuflar a la constitución heredada de regímenes iliberales (o incluso a la Constitución rusa) un espíritu completamente diferente. El simple hecho de deshacerse de las salvaguardias constitucionales corrompidas o neutralizarlas solo crea un vacío, una oportunidad para que el poder se engrandezca a sí mismo. Con o sin las instituciones heredadas de protección constitucional, el problema persiste. ¿Cómo crear salvaguardias constitucionales eficaces contra el celo de la transición y las ilusiones (o la realidad) de omnipotencia? ¿Dónde encontrar una supervisión constitucional creíble? ¿Cómo no resistir la tentación de nombrar, una vez más, a leales? La oposición (los restos del antiguo régimen comprometido) no ofrece una influencia moderadora legítima, y el dominio de un solo partido puede convertirse en una realidad. Solo cabe esperar que las intensas lecciones de sufrimiento causadas por los abusos del pasado enseñen el autocontrol.

En tercer lugar, el ejemplo de una Constitución fácilmente modificable y de cambios institucionales fáciles en nombre de la justicia puede normalizar y perpetuar una reconstitución radical continua, especialmente si se utilizan los mismos trucos legales y soluciones provisionales que eran el pan de cada día de las democracias iliberales. La tentación es fuerte de contrarrestar las viejas soluciones provisionales con otras similares para deshacer las consecuencias de la primera. Esto ocurrió en Polonia cuando el gobierno de Tusk reestructuró la **televisión pública** porque la cadena seguía produciendo la propaganda del régimen anterior. Aunque la opinión pública pueda apreciar soluciones del tipo *Medida por medida*, esto no puede elevarse a la categoría de tradición.

El dilema de la transición posttotalitaria era cómo construir un **barco en mar abierto**. Los refor-

mistas se enfrentaban a un problema de circularidad:

- Se necesita un Estado eficaz para crear mercados.
- Mercados para generar recursos para el Estado.
- Esto requiere una reforma, pero para llevarla a cabo se necesita legitimidad.
- Sin embargo, la legitimidad en sí misma depende de reformas con resultados socialmente aceptables.

La transición constitucional posiliberal necesaria para «desatar la democracia» (¡no «construir la democracia», por favor!) parece más sencilla. Debe imaginarse como un proceso autolimitado, autolimitado desde el primer día. A diferencia de las transiciones posdictatoriales y poscomunistas, puede basarse en una utopía realista. El Estado «solo» debe liberarse de la captura; la economía, de los amiguismos. Si la liberación tiene éxito, la economía puede generar recursos para el Estado y para el público. Si es así, el rendimiento de la economía, junto con la reparación de la injusticia, generará legitimidad. Además, la transición posiliberal puede basarse en experiencias previas (o al menos coqueteos) con la democracia, e incluso en una economía distorsionada, las habilidades empresariales y los recursos han sobrevivido para hacer que la economía sea sostenible. La transición restauradora también puede basarse en los principios y hábitos del Estado de derecho existentes. La tarea no es construir la democracia a partir de las ruinas, sino liberar las capacidades democráticas existentes de la captura. Pero esto no es suficiente, y la transición necesita garantías poco ortodoxas de constitucionalismo. Las medidas inusuales al servicio de la transición requieren medidas espe-

cíficas de control. Por ejemplo, cuando no sea posible sustituir al tribunal constitucional, el Parlamento debería apoyarse en su propia institución de supervisión paralela creíble, creando un órgano de revisión independiente que supervise todos los proyectos de ley. Del mismo modo, las garantías formales o institucionales de transparencia en el gobierno y el control público del mismo deberán estar habilitadas desde el primer día. Se fijará la duración del período de transición extraordinario (que debería ser lo más breve posible) con objetivos claros, etc. La transición debe ser autolimitada antes de que se convierta en autocomplaciente.

La transición constitucional puede ser una utopía realista.

La reconstrucción constitucional y democrática, si tiene éxito, debería dejar tras de sí instituciones y una cultura de la razón y la decencia que heredarían tanto sus partidarios como sus enemigos.

Quizá haya aquí una lección más amplia. Las circunstancias difieren, especialmente en países con una mayor resistencia constitucional, como Estados Unidos, pero el manual de Orbán tuvo una influencia directa, y el derrocamiento en 2026 del régimen populista en Hungría sigue siendo inspirador. O, tal vez, la única lección que se pueda aprender será que, una vez más, donde el poder absoluto es una posibilidad, la corrupción (casi) absoluta es difícilmente evitable. Sin activar la imaginación constitucional, es probable que dicha corrupción continúe en todo el mundo. Sin imaginación constitucional, el declive democrático se convierte en una profecía autocumplida. Y donde desaparece la imaginación democrática, el poder arbitrario y auto-perpetuante adquiere el hábito de la permanencia. ■

El fin de un consenso institucional

por Adrián Federico Ambroggio

El Decreto 467/2026 y un innecesario retroceso en materia de igualdad, participación y transparencia.

17 de junio de 2026

Introducción

El 16 de junio de 2026, el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 467/2026, suscripto por el Presidente Milei y el Ministro de Justicia Mahiques, mediante el cual se modificaron sustancialmente los Decretos N° 222 del 19 de junio de 2003 y N° 588 del 13 de agosto de 2003. Ambas normas regulaban el procedimiento administrativo previo a la nominación presidencial de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), de los jueces de los tribunales inferiores, y de los integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. La reforma, dictada formalmente con invocación del art. 99, inc. 1 de la Constitución Nacional, aunque referida al ejercicio de la facultad presidencial prevista en el art. 99, inc. 4, suprime la etapa de publicidad y participación ciudadana en sede del Poder Ejecutivo, elimina los criterios de composición plural establecidos para la Corte Suprema y unifica algunas disposiciones procesales entre ambas normas.

La premisa central de este artículo es que los Decretos 222/03 y 588/03, si bien eran autolimitaciones del propio Poder Ejecutivo a sus facultades constitucionales —y por tanto susceptibles de ser modificadas o derogadas por la misma vía—, poseían un valor que excedía el meramente técnico-normativo: representaban un consenso político-institucional ampliamente compartido por la comunidad jurídica y la sociedad civil sobre los estándares mínimos de transparencia y deliberación en el proceso de designación de magistrados. La derogación de esos estándares no resuelve ninguno de los problemas que el propio decreto identifica como fundamento de la re-

forma, y constituye, en consecuencia, una modificación tanto innecesaria como regresiva.

Los Decretos 222/03 y 588/03: autolimitación presidencial y consenso político

El Decreto N° 222/03, dictado durante la presidencia de Néstor Kirchner en un contexto de profunda crisis de legitimidad del Poder Judicial —marcado por los cuestionamientos a la composición y al funcionamiento de la denominada “mayoría automática” de los años noventa—, estableció un procedimiento administrativo previo a la nominación presidencial de los candidatos a integrar la CSJN. El Decreto N° 588/03 extendió un procedimiento análogo a los jueces federales y nacionales de instancias inferiores y a los integrantes del Ministerio Público.

Cabe destacar que el Decreto N° 222/03 no fue una iniciativa espontánea del Poder Ejecutivo: fue el resultado de un proceso impulsado por la Coalición “Una Corte para la Democracia”, integrada por seis organizaciones de la sociedad civil —Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Unión de Usuarios y Consumidores—, que durante 2003 presentaron los documentos “Una Corte para la Democracia I, II y III” como fundamento de la norma (Poder Ciudadano, 2015). Esto explica por qué el decreto fue recibido con aprobación tan amplia: era, en rigor, la respuesta institucional a una demanda articulada por la propia sociedad civil organizada. El Decreto 467/2026 deroga ese legado sin

haber consultado a ninguna de esas organizaciones, ni a ninguna otra.

Los pilares del sistema diseñado por ambas normas eran tres. En primer lugar, la *publicidad de los antecedentes*: la publicación del nombre y currículum del candidato en el Boletín Oficial y en diarios de circulación nacional y local, generando conocimiento público sobre la postulación con anterioridad a la decisión presidencial. En segundo lugar, la *participación ciudadana*: la apertura de un período de consulta durante el cual cualquier ciudadano, organización de la sociedad civil, universidad, colegio profesional u organismo estatal podía formular observaciones al candidato propuesto —sin poder de veto, pero con obligación de consideración por parte del Ejecutivo—. En tercer lugar, los *criterios de composición plural*: la disposición del art. 3° del Decreto 222/03, conforme a la cual al momento de proponer candidatos para la Corte debía procurarse reflejar diversidades de género, especialidad y procedencia regional.

Desde el punto de vista técnico-jurídico, la doctrina reconoció que estas normas constituían una *autolimitación voluntaria del Poder Ejecutivo* a sus propias atribuciones constitucionales (Comadira, 2004), sin que existiese obstáculo constitucional para que el mismo órgano las derogase. Sin embargo, también se advirtió que su cumplimiento era exigible y eventualmente justiciable, puesto que sería irrazonable que el Presidente sometiese algunas nominaciones al procedimiento y otras no (Buteler, 2017).

Más allá de su valor jurídico estricto, los Decretos 222/03 y 588/03 adquirieron con el paso del tiempo un significado político-institucional que superó ampliamente el texto normativo. Ambos decretos gozaron de una excelente reputación en la doctrina especializada (Carnota, 2003; Gelli, 2004), más allá de algunas críticas aisladas (Pastor, 2003), e implicaron, como afirmó Comadira (2005), una línea de “democratización y juridización encomiables del proceso de selección de jueces” con una “enorme trascendencia institucional”. Además, fueron recibidos

con beneplácito por la comunidad jurídica, las organizaciones de la sociedad civil, los colegios de abogados y las universidades. Representaban una respuesta institucional al reclamo histórico de transparencia en un proceso que, hasta entonces, era opaco, discrecional e impermeable a cualquier forma de escrutinio externo. En suma, encarnaban un consenso básico sobre los mínimos de deliberación pública que debían rodear la designación de quienes ejercerían en el Poder Judicial de la Nación.

El Decreto 467/2026: Contenido y fundamentos

Modificaciones introducidas

El Decreto 467/2026 sustituye los arts. 4°, 5°, 8°, 9° y 10 del Decreto 222/03 y los arts. 4°, 8°, 9° y 10 del Decreto 588/03, e incorpora un art. 10 bis al último de los nombrados. Su art. 11 deroga expresamente los arts. 3°, 6° y 7° del Decreto 222/03 y los arts. 5°, 6° y 7° del Decreto 588/03.

Las principales modificaciones son las siguientes:

a) **Eliminación de la etapa de consulta ciudadana en sede administrativa**: se suprimen la publicación en diarios, el período de observaciones y la recepción de impugnaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia. La publicación se reduce a tres días en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio, sin etapa participativa posterior.

b) **Unificación de plazos**: los candidatos cuentan con cinco días para presentar declaraciones juradas; la ARCA dispone de cinco días para elaborar el informe sobre obligaciones impositivas y previsionales.

c) **Derogación del art. 3° del Decreto 222/03**: se elimina el criterio de composición plural de la Corte Suprema, que exigía procurar diversidades de género, especialidad y procedencia regional.

d) **Actualización de la publicidad**: se reemplaza la publicación en diarios de papel por la

publicación digital en el sitio web del Ministerio de Justicia.

e) **Restricción al acceso a las declaraciones juradas:** el nuevo art. 5° dispone que la declaración jurada patrimonial de los postulantes podrá ser consultada conforme a los arts. 10 y 11 de la Ley de Ética de la Función Pública N° 25.188, norma que exige al solicitante acreditar nombre, domicilio y motivación para acceder a ella. Como ha señalado Etchichury, esto implica que quien quiera consultar los bienes declarados por un candidato a la Corte deberá identificarse e invocar una razón: una restricción que no existía en el régimen anterior y que va en sentido contrario a la transparencia que el decreto dice promover.

2. Los fundamentos invocados por el Poder Ejecutivo



El Poder Ejecutivo sustenta la reforma en tres argumentos centrales. El primero es la *existencia de una crisis por vacancias judiciales*: el decreto identifica correctamente el elevado número de cargos vacantes en la justicia nacional y federal como un problema que afecta el debido proceso y los derechos de los justiciables. El segundo es la *duplicación de instancias*: sostiene que los mecanismos de publicidad y participación ciudadana previstos en los Decretos 222/03 y 588/03 duplican las instancias ya garantizadas por el procedimiento de acuerdo senatorial, cuyo reglamento prevé audiencias públicas, recepción de

observaciones y publicidad del proceso. El tercero es la *desnaturalización de la etapa de nominación presidencial*: el decreto afirma que la incorporación de mecanismos propios de la etapa senatorial en sede ejecutiva desnaturaliza la facultad de nominación del Presidente, cuyo carácter es eminentemente político e institucional.

IV. Crítica: la innecesariedad de la reforma y la ruptura del consenso

1. *El problema de la demora existe, pero no es responsabilidad de los procedimientos de los Decretos 222/03 y 588/03.*

El diagnóstico del Poder Ejecutivo sobre la crisis de vacancias es, en lo sustancial, correcto. Como hemos señalado en otra obra (Ambroggio, 2024), el alto porcentaje de cargos vacantes en la justicia nacional y federal constituye un problema estructural de larga data que compromete seriamente la prestación del servicio de justicia. Pero la terapéutica escogida no guarda relación con la enfermedad diagnosticada.

El procedimiento de consulta ciudadana establecido por los Decretos 222/03 y 588/03 nunca fue el cuello de botella. Las demoras reconocen otras causas, más profundas y más difíciles de resolver: con el tiempo, el sistema de designación de jueces inferiores federales se convirtió en una mixtura entre un ámbito de constatación de la idoneidad técnica y un ámbito de negociación de vacantes y cargos entre la corporación política, la corporación judicial y la representación de los abogados y científicos.

Una vacante recorre así tres instancias sucesivas de demora: la negociación en el seno del Consejo de la Magistratura, la retención discrecional del pliego en el Poder Ejecutivo —que puede extenderse por años sin obligación alguna de envío al Senado— y la demora de la Cámara Alta en la tramitación del acuerdo. De esas tres instancias, el Decreto 467/2026 apenas roza la segunda, sin establecer ningún plazo ni obligación concreta. Las restantes dos quedan intactas.

En el caso particular de la Corte Suprema, la causa de demora es distinta pero igualmente ajena al procedimiento del Decreto 222/03: las vacantes se prolongan cuando el Poder Ejecutivo propone candidatos que no cuentan con el consenso necesario para obtener los dos tercios del Senado. Es lo que ocurrió precisamente con los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, tramitados bajo el mismo procedimiento que ahora se deroga, y que permanecieron sin acuerdo senatorial durante meses. El problema, en ese caso, no era el mecanismo de consulta previa: era la falta de consenso político sobre los candidatos elegidos.

La participación previa no duplica la participación en el Senado

El argumento central del Decreto —la supuesta duplicación de instancias— no resiste un análisis funcional mínimo. Las etapas de participación ciudadana en sede ejecutiva y en el Senado no son equivalentes ni intercambiables: cumplen funciones distintas, operan en tiempos diferentes y ante actores institucionales con lógicas propias.

La participación ciudadana ante el Ministerio de Justicia tenía como función permitir el ingreso de observaciones antes de la decisión presidencial de nominar. Era una instancia de retroalimentación previa que podía incidir sobre la propia elección del candidato, o al menos poner de manifiesto públicamente aspectos de su trayectoria que el Presidente estuviese en condiciones de ponderar.

La audiencia pública en el Senado, en cambio, opera después de que el pliego se envió: el Presidente ya tomó su decisión y la hizo pública. En ese estadio, el rechazo del pliego —que históricamente ha sido infrecuente e inusual en nuestra práctica constitucional— es la única vía para que la oposición ciudadana tenga algún efecto jurídico. Desde la recuperación democrática en 1983, el rechazo expreso en el recinto de un candidato propuesto por el Poder Ejecutivo para un cargo judicial con mayoría agravada constituye un he-

cho sin precedentes hasta abril de 2025, cuando el Senado rechazó los pliegos de Lijo y García-Mansilla. La práctica era, hasta entonces, el retiro de los pliegos ante la falta de consenso, tal como hicieron las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández en sus intentos por nombrar jueces de la Corte y para la Procuración General de la Nación. Estos datos confirman que trasladar la participación ciudadana exclusivamente a la etapa senatorial equivale a trasladarla a un momento donde, en la práctica histórica, casi nunca tiene efecto alguno.

Por otra parte, el contraste con las tendencias contemporáneas del pensamiento democrático no puede ser más marcado. En un momento en que la teoría política y constitucional discute cómo ampliar y profundizar los canales de participación ciudadana — por solo dar un ejemplo del nivel de profundidad de esa discusión, Landemore (2021) piensa incluso una plataforma deliberativa de alcance masivo, el “Citizenbook”, como herramienta para escalar la democracia abierta a escala nacional—, el Poder Ejecutivo Nacional suprime una de las pocas instancias de participación directa que existían en el proceso de designación de magistrados. Desde la lógica de la democracia participativa y deliberativa, más participación es siempre mejor participación; recortarla sin necesidad no es solo una decisión técnica inconveniente —es una afrenta a los estándares republicanos mínimos que una sociedad democrática debe garantizar.

El traslado completo de la participación a la etapa del acuerdo en el Senado, lejos de preservar la deliberación, la desplaza a un momento en que su incidencia real sobre la designación es sensiblemente menor.

La ruptura de un consenso político-institucional

Como expresamos anteriormente, los Decretos 222/03 y 588/03 nacieron como respuesta a una demanda histórica de la sociedad argentina tras la experiencia de la “mayoría automática” de la Corte de los años noventa —período carac-

terizado por la falta de independencia judicial y por la designación de magistrados con escaso rigor técnico—Con los años, se convirtieron en un piso institucional no escrito, asumido por todos los actores del sistema como parte de las reglas de juego del proceso de designación de magistrados. Y la práctica lo confirmó: cinco presidentes de las más diversas orientaciones ideológicas —Kirchner, Fernández de Kirchner, Macri, Alberto Fernández y el propio Milei— aplicaron el procedimiento sin cuestionarlo. El actual Presidente lo utilizó para tramitar múltiples pliegos, incluyendo los de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como postulantes a la CSJN.

El Decreto 467/2026 rompe ese consenso sin aportar ninguna contraprestación institucional equivalente. No crea mecanismos alternativos de participación ni establece plazos perentorios para la cobertura de vacancias. Tampoco resuelve el problema de los pliegos retenidos en el Ejecutivo. Suprime estándares ampliamente valorados y no los reemplaza por nada. La reforma resulta, en este sentido, un retroceso injustificable: se renuncia voluntariamente a estándares más exigentes de transparencia y deliberación que habían sido aceptados de forma mayoritaria por la comunidad jurídica y la sociedad civil, sin que ningún interés legítimo y concreto justifique esa defección.

La supresión del estándar de diversidad: un retroceso específico e inadmisibles

El aspecto más grave y específico de la reforma es la derogación del art. 3° del Decreto 222/03, que imponía procurar, en la composición de la CSJN, diversidades de género, especialidad y procedencia regional. Este artículo cumplía una función que excedía la mera declaración programática: en un sistema de nominación presidencial de amplia discrecionalidad, la fijación de criterios de composición plural operaba como límite autoimpuesto a la arbitrariedad y como pauta de objetivación de una decisión que, de otro modo, quedaría librada exclu-

sivamente a consideraciones políticas coyunturales.

La eliminación del estándar de paridad de género resulta particularmente objetable en el contexto actual. El Poder Judicial argentino exhibe una brecha de género en los niveles superiores de la magistratura (Gastiazoro & Moguillansky, 2021). La Corte Suprema, tribunal de máxima jerarquía del sistema judicial, no ha alcanzado nunca una integración paritaria. En ese contexto, la supresión incluso de la *aspiración normativa* de reflejar diversidad de género en la composición del máximo tribunal no es una decisión neutra: es un mensaje institucional de renuncia a ese objetivo, cuyas consecuencias prácticas se proyectarán sobre las próximas designaciones.

La derogación del criterio de diversidad de género no puede leerse de manera aislada. Se inscribe en un proceso más amplio de desmantelamiento de las políticas de igualdad de género que caracteriza a la gestión iniciada en diciembre de 2023: disolución del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, desfinanciamiento de programas, consejos y observatorios especializados, paralización de planes de prevención de violencia de género y eliminación de políticas de cuidado (Copetti, 2026; Amnistía Internacional, 2025). Ese proceso se ha caracterizado como un retroceso de treinta años en la protección de los derechos de mujeres y diversidades, que se produce no mediante derogación de leyes sino a través del vaciamiento sistemático de las políticas públicas que les dan efectividad (Daverio, 2026). En ese contexto, la supresión del criterio de paridad de género en la composición de la Corte Suprema no es una decisión técnica menor: es una pieza más de un programa coherente de desmantelamiento institucional de la agenda de igualdad.

La derogación del criterio de procedencia regional es igualmente preocupante. Argentina es un Estado federal que ha tenido históricamente una Corte Suprema de fuerte sesgo porteño y bonaerense. El art. 3° del Decreto 222/03 procuraba, al menos en el plano aspiracional, corregir

esa distorsión, contribuyendo a una Corte con mayor anclaje federal. Su eliminación naturaliza el centralismo en la composición del máximo tribunal, en abierta tensión con el principio federal que organiza la estructura constitucional del Estado argentino.

Conclusión

A pesar de las críticas efectuadas, el Decreto 467/2026 no es inconstitucional. Los Decretos 222/03 y 588/03 eran autolimitaciones del propio Poder Ejecutivo a sus facultades constitucionales —consagradas en el art. 99, inc. 4 de la Constitución Nacional—, y era jurídicamente posible modificarlas o derogarlas por la misma vía. Pero que una norma sea constitucionalmente válida no la exime de la crítica sobre su inconveniencia institucional.

La reforma es innecesaria porque no resuelve ninguno de los problemas que invoca como fundamento: la crisis de vacancias no se originó en los Decretos 222/03 y 588/03, y la participación previa ante el Ejecutivo no duplica la participación en el Senado sino que la precede con una lógica distinta. Es, además, regresiva: elimina sin reemplazar estándares de transparencia, igualdad y deliberación que cinco presidentes de las más diversas orientaciones respetaron durante más de veinte años. La derogación del art. 3° del Decreto 222/03, que procuraba reflejar diversidades de género, especialidad y procedencia regional en la composición de la Corte, constituye el retroceso más grave: en un Estado que se postula federal y que ha asumido compromisos constitucionales e internacionales en materia de igualdad, abandonar incluso la aspiración de una Corte plural implica un mensaje institucional de renuncia a valores que ya deberían ser políticas de Estado.

Probablemente el procedimiento establecido por los Decretos 222/03 y 588/03 no era perfecto. Con el tiempo, la etapa de observaciones ciudadanas se había desnaturalizado en parte, convirtiéndose en ocasiones en una suerte de recolección de firmas sin verdadera incidencia delibera-

tiva. Esa disfunción podría haber justificado una reforma orientada a perfeccionar el mecanismo: precisar los requisitos de las observaciones, establecer plazos más claros, crear instancias de respuesta formal por parte del Ejecutivo, o fortalecer los criterios de composición plural.



El Decreto 467/2026, sin embargo, no optó por mejorar el procedimiento sino por derogar buena parte de su sentido original. Frente a un instrumento imperfecto pero valioso, la respuesta fue la supresión, no la mejora. Esa es, quizás, la más elocuente demostración de que la reforma no tuvo como objetivo real resolver ningún problema institucional. En síntesis, el decreto sancionado no aporta ninguna solución a los problemas reales del sistema de designación de magistrados y solo representa un innecesario y grave retroceso respecto de dos normas ampliamente valoradas por la comunidad jurídica y la sociedad civil.

Referencias

- Ambroggio, A. F. (2024). La selección de jueces. *La Ley*.
- Amnistía Internacional. (2025). A dos años del actual gobierno, se profundiza el retroceso en los derechos de mujeres y diversidades. <https://amnistia.org.ar/noticias/a-dos-anos-del-actual-gobierno-se-profundiza-el-retroceso-en-los-derechos-de-mujeres-y-diversidades>
- Buteler, A. (2017). Concurso público. *Astrea*.

Carnota, W. F. (2003). Un punto de partida para una mejor selección de jueces de la Corte Suprema. *elDial.com*.

Comadira, J. (2004). Selección de jueces y control judicial. *Revista de Derecho Público*, 2004-I, 22.

Comadira, J. R. (2005). El principio de participación ciudadana en la función administrativa (con especial referencia a la formación de la voluntad de la Administración y a la selección de autoridades públicas). *El Derecho Administrativo*, 2005-400.

Copetti, A. (2026). Derechos en retroceso: cómo se están vaciando las políticas de género en Argentina. *Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad (IDEJUS-CONICET-UNC)*. <https://idejus.conicet.gov.ar/derechos-en-retroceso-como-se-estan-vaciando-las-politicas-de-genero-en-argentina/>

Daverio, A. (2026). Retroceso de género en Argentina: desmantelamiento de instituciones y políticas públicas de igualdad de género y diversidad en el gobierno de Javier Milei. *Revista Perspectivas de Políticas Públicas*, 15(30), 245-269. <https://doi.org/10.18294/rppp.2026.6356>

Gastiazoro, Maria Eugenia; Moguillansky, Martin Oscar; Brechas de género en las designaciones del sistema judicial argentino: Análisis

de tendencias; Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”; *Revista Electrónica Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja*; 27; 12-2021; 275-320 .

Gelli, M. A. (2004). Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada. La Ley.

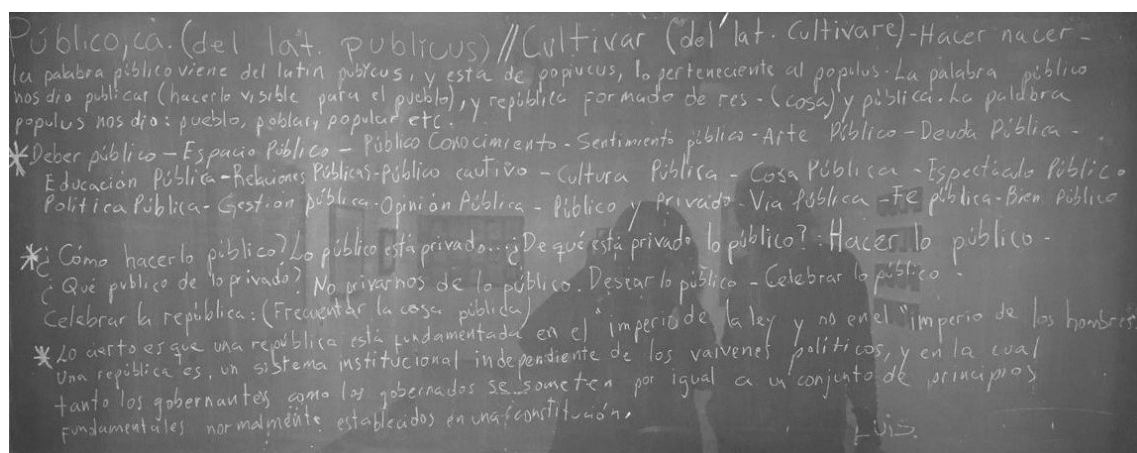
Landemore, H. (2021). *Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century*. Princeton University Press.

Pastor, D. (2003). Acerca del actual régimen plebiscitario de designación de funcionarios judiciales. *elDial.com* - CC58C.

Poder Ciudadano. (2015). Decreto 222: procedimiento participativo para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recuperado de <https://poderciudadano.org/decreto-222-procedimiento-participativo-para-el-nombramiento-de-los-magistrados-de-la-corte-suprema-de-justicia-de-la-nacion/>

Sagüés, N. (2014). A 20 años de la Reforma de 1994: una fórmula constitucional sibilina. *La Ley – Suplemento Constitucional*, 158.

Sagüés, N. (2017). *Derecho constitucional*. Astrea.



El tortuoso camino de Keiko Fujimori a la presidencia

por Natalia Sobrevilla Perea

Orígenes, miserias, miedos, y traiciones de "la hija de" que se convirtió en la primera mujer en la historia del Perú en ser electa para la primera magistratura.

19 de junio de 2026

A pesar de que el resultado oficial no se proclamará hasta dentro de un par de semanas, se puede afirmar ya sin lugar a duda que Keiko Sofía Fujimori Higuchi será la próxima presidenta del Perú. A los cincuenta y un años, la misma edad a la que llegó su padre a Palacio de Gobierno en 1990, y en su cuarto intento, ella se ha convertido en la primera mujer elegida presidenta en la historia peruana (Dina Boluarte llegó por mandato parlamentario).

Volverá a donde llegó hace treinta y seis años, y donde a los diecinueve se convirtió en primera dama, cuando su padre se separó de Susana Higuchi, a quien encerró y aplicó electroshock por denunciar la corrupción que veía en el entorno cercano a su marido. Creció entre Palacio y el Servicio de Inteligencia, en el edificio donde se incineraron los cuerpos de los enemigos del régimen. Estudió en Estados Unidos, y declaró en un juicio que recibía de Vladimiro Montesinos, el asesor de su padre hoy preso, paquetes de diez mil dólares en efectivo cada par de semanas cuando viajaba a Lima. No se sabe realmente como se financiaron sus estudios porque claramente no fue con lo de la venta de un pequeño inmueble como declaró su padre en ese mismo juicio.

En el 2000 Keiko fue encargada de sacar las últimas pertenencias de Palacio cuando su padre se fugó a Japón y la dejó a sus veinticinco años completamente desvalida. No es difícil imaginar que en ese momento se prometió a sí misma que algún día volvería, costara lo que costara. Veintiséis años más tarde, después de ser congresista

entre el 2006 y 2011 y dos estancias en la cárcel de mujeres de Lima entre el 2018 y el 2020, acusada de mal uso de recursos de campaña, sus dos décadas en campaña finalmente han rendido fruto. Se le puede acusar de todo menos de falta de persistencia.

Formada entre su padre y Montesinos, rodeada de la cúpula de su partido, Fuerza Popular, ha dedicado su vida a la política. Nunca ha tenido más trabajo que el congreso o la dirección del partido y solo descansó del trabajo parlamentario para tener a sus hijas Kyara y Kaori. A quienes convirtió en accesorios políticos cuando su exmarido el norteamericano Mark Vito Villanella la dejara para convertirse en personaje de la farándula local. Su hija mayor la ha desmentido en público cuando trató de utilizar de ejemplo diciendo que no la dejaría abortar de quedar embarazada después de una violación. Su hija menor la ha acompañado bailando en los estrados, como hizo ella con su padre en el 2000.

¿Pero cómo ha logrado hacerse de la presidencia después de tres intentos fallidos? Observando, aprendiendo, alimentando la amenaza del comunismo que acecha para convertir al Perú en Cuba o Venezuela. Pero sobre todo tomando las instituciones, una por una, además de cansando y desarticulando a sus opositores. Solo así ha podido por un margen muy estrecho ganar en unos comicios, que, si bien han sido limpios a nivel formal, se caracterizaron por profundas falencias de fondo.

Cada elección en la que participó Fujimori mejoró su estructura de campaña y reclutó a sus

seguidores más fieles entre los grupos empresariales más importantes del país, asegurándoles que como su padre gobernaría en su beneficio. En la segunda vuelta del 2011 desplegó con absoluta virulencia la campaña de miedo, asegurando que el país sería destruido en caso de que un comunista como el militar en retiro que tenía al frente llegara a la presidencia. Ollanta Humala, rápidamente firmó la llamada “hoja de ruta” comprometiéndose a no cambiar el rumbo económico. Mientras que el movimiento conocido como el anti-fujimorismo que fue ganando cada vez más fuerza, logró poner en la agenda los abusos del régimen de su padre, incluyendo la entonces menos conocida campaña de esterilizaciones forzadas llevadas a cabo en los 90s.

En el 2016 cuando enfrentó a Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta estuvo muy cerca de ganar. El poco carismático veterano exministro de economía de Alejandro Toledo era también de derecha, así que la amenaza comunista no le sirvió. Una vez más el anti-fujimorismo hizo lo suyo y a pesar de compartir poco con Kuczynski lo respaldó en su triunfo por poco más de 41,000 votos. Fue aquí en que la diferencia entre como votaba el norte y el sur del Perú quedó claramente plasmada en el mapa electoral. Fujimori domina las provincias amazónicas bajas: Loreto y Ucayali, así como lo que alguna vez fue conocido como el solido norte del APRA, además de la capital, el puerto del Callao y la provincia de Ica, mientras que, en los Andes, sobre todo en las provincias del sur se le rechaza.

Esas elecciones, sin embargo, marcaron un punto de inflexión ya que una reforma electoral que buscaba limitar el número de partidos en el Congreso llevó a que Fujimori controlara el parlamento, con 73 congresistas de 130. Kuczynski le ofreció ser premier o cualquier cargo que quisiese para poder hacer un gobierno conjunto, pero en vez de aceptar Fujimori le declaró una guerra sin cuartel y no cejó hasta forzarlo a renunciar a la presidencia, antes de ser vacado. Keiko peleó también con su hermano menor Kenji quien desde el parlamento buscó liberar a

su padre por todos los medios. Cuando su hermano se alió con Kuczynski para liberar a Alberto, ella lo expulsó del partido. Se dice que el padre quería volver a la presidencia y no creía que ella podría ser elegida.

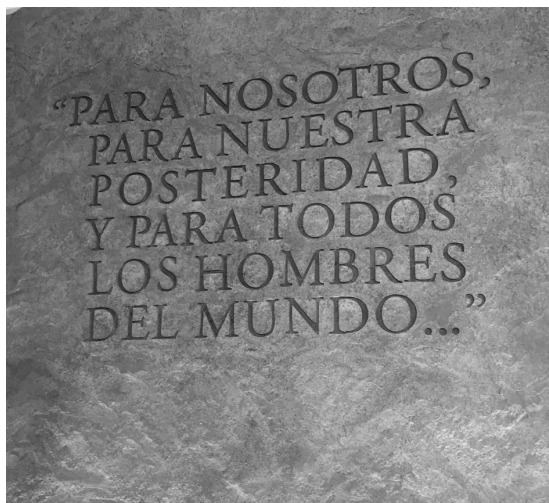
En esos años solo Martín Viscarra logró hacerle un poco de contrapeso cuando como vicepresidente asumió el cargo tras la salida de Kuczynski. Viscarra se enfrentó al parlamento, y por insistencia logró cerrar la cámara y llamar a nuevas elecciones congresales. Organizó un referéndum donde se prohibió la reelección parlamentaria y se rechazó la bicameralidad. Meses más tarde durante la crisis causada por la pandemia Viscarra fue vacado por ese nuevo parlamento cuando trascendió que él y su familia se habían vacunado de manera clandestina. Hoy está preso, acusado de corrupción e inhabilitado de ejercer cargos públicos.



Esos fueron los años más difíciles para Fujimori, ya que al explotar el caso Lava Jato, se investigó el financiamiento de sus campañas presidenciales y terminó presa bajo prisión preventiva, no solo por aceptar dinero bajo la mesa de Odebrecht, sino, sobre todo por mentir al tratar de explicar cómo habían llegado esos fondos a sus manos y por amenazar a las personas en los lugares más pobres del país que se suponía habían aportado al partido. Fue así que el llamado “caso cocteles” o de “pitufeo” porque buscaba cubrir la recepción del dinero con aportaciones ficticias, la llevó a la cárcel por más de un año, en dos periodos.

Fujimori llegó la segunda vuelta del 2021 sintiéndose ganadora porque su contrincante fue un maestro rural, que, si bien no tenía gran habi-

lidad política, era capaz de conectar con los electores que se identificaron con su sombrero y creyeron en su “palabra de maestro” y en su eslogan principal: “no más pobres en un país rico”. Comunicaba un mensaje claro a quienes no habían visto mejora alguna en la década de bonanza económica y que fueron fuertemente castigados durante la pandemia, con el brutal crecimiento de la pobreza y colapso de los servicios de salud.



Fujimori volvió a movilizar el miedo contra el comunismo. Cada campaña anterior resultó en periodistas despedidos por no mentir sobre su contrincante, así que para el 2021 a los medios de comunicación importantes la apoyaban solo a ella. El aparato de reparto de prebendas y movilización de personas pagadas a sus mítines se hizo costumbre y en sus plazas fuertes parecía imparable. Pero Pedro Castillo tenía el sombrero, el apoyo del anti-Fujimorismo y de todo el sur del Perú, además de las provincias andinas del norte como su Cajamarca natal.

Cuando ganó por 44,000 votos Keiko Fujimori utilizó la estrategia de Tump y Bolsonaro gritando fraude. La campaña de demolición de los entes electorales fue intensa y hasta ahora hay quienes están convencidos que esas elecciones les fueron robadas. Pocos días antes del cambio de mando se proclamó a Castillo y la guerra desde el parlamento fue inmediata. Paso a paso los fujimoristas coparon las instituciones

que podían servir de contrapeso: la defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y sobre todo las autoridades electorales.

Mientras lo hacían con la complicidad de los parlamentarios de otras bancadas afines, aprobaron una serie de leyes conocidas como procrimen, porque hicieron cada vez más difícil combatir a las economías ilegales y daban impunidad a policías y militares. El Congreso se convirtió en un espacio de representación de ciertos grupos de interés. Mientras que Castillo demostró no solo que era incapaz de convertir el país al comunismo, sino que tampoco podía gobernar. Fue así que el 7 de diciembre del 2022 intentó un golpe de estado tan mal pensado y organizado que no duró más de cuarenta minutos. Hoy está preso.

Lo reemplazó su vicepresidenta quien solo pudo gobernar con el apoyo del Congreso Fujimorista, porque una vez establecida la mecánica de un número mínimo para sacar a un presidente, el mantenerse en el poder se convirtió en una cuestión de votos y el Perú se pasó a tener un sistema pseudo parlamentario. En el sur del país estallaron protestas demandando la libertad de Castillo, y nuevas elecciones. Boluarte envió al ejército y la situación escaló convirtiéndose en una carnicería donde murieron casi cincuenta personas, incluyendo niños que iban por la calle, un paramédico que buscaba salvarle la vida a un herido y personas que solo querían que se respetaran sus derechos.

Gracias al apoyo de Fujimori, Boluarte se mantuvo en Palacio de Gobierno hasta que dejó de serle funcional en medio de una ola de violencia en el país y así el Congreso eligió a Jerí y Balcázar, pero tomando todas las decisiones importantes en el parlamento, desde donde se modificó la constitución retornando a la bicameralidad y a la reelección parlamentaria. Otras reformas electorales que hubiesen limitado el número de candidatos a la presidencia con una primaria obligatoria no se aprobaron, dispersando el voto lo más posible para asegurar la vulnerabilidad del contrincante de Fujimori, que con su

núcleo duro de votantes llegaría sin duda a la segunda vuelta. 32 candidatos compitieron por la presidencia en la primera vuelta y que menos del 20% de los electores votaran por quienes pasaron a la segunda.

La lucha por el segundo lugar fue tan reñida que el candidato de ultraderecha católica Rafael López Aliaga se negó a aceptar los resultados y aseguró como lo hizo Keiko en el 2021 que se había cometido fraude. Se forzó la renuncia del Jefe del organismo electoral, único funcionario que no estaba en manos del fujimorismo y la discusión sobre la legalidad de los comicios se dilató tanto que la segunda vuelta, que en el Perú suele durar unas seis semanas se redujo a tres. Y si bien Roberto Sánchez logró establecer una alianza con todas las fuerzas de izquierda y algunas de centro, y recibió el apoyo de varias personalidades de la prensa y del anti-fujimorismo, esto no fue suficiente para detener a su contrincante.

La campaña del miedo volvió con una virulencia aun mayor y en su cuarto intento de llegar a la presidencia, Fujimori no dejó nada al azar. La ultraderecha le dio todo su apoyo y los resultados hablan por si mismos. El país está completamente dividido. Ella domina como siempre la costa y la baja Amazonia, mientras que el sur y todo el espacio Andino ha votado por Roberto Sánchez. En algunas localidades, las más pobres,

él ha sacado el 99% de los votos mientras que en las más afluentes ella ha logrado un 80%. Los votos del extranjero que son menos del 3% del total han jugado un papel preponderante porque en las plazas fuertes: Argentina, Chile, Miami, Madrid y Milán, Fujimori ha tenido una alta votación, a pesar del ausentismo.

El conteo ha sido a cuentagotas, con Fujimori liderando primero y Sánchez tomando ventaja al segundo día cuando se contabilizaron las actas de las provincias más alejadas de la capital. El miércoles con la llegada de los votos del extranjero ella volvió a tomar la delantera primero con 600 votos, pero ahora la diferencia es de más de 18,000 a su favor. Quedan unas 1300 actas impugnadas, que deben ser revisadas por los Jurados Electorales Especiales, de donde habrá unos 250,000 votos, de los cuales la mayoría se inclina por Fujimori.

El camino ha sido largo y tortuoso y su dificultad de llegar al poder ha quedado una vez más al descubierto. Pero la experiencia y la capacidad de cambiar las reglas le ha dado la posibilidad de llegar al poder. En este momento su agrupación política cuenta con el control de todos los poderes del Estado y así en un mundo polarizado y una región cada vez más inclinada a la derecha, Keiko Fujimori ha ganado la presidencia peruana. ■



Cuando el jurado le dice "no" a la ley

por Catalina Finn · Martín César Giorgi · Morella Riemersma

Jury nullification y control democrático.

26 de junio de 2026

En su libro *La justicia frente al gobierno: sobre el carácter contramayoritario del poder judicial* (1996), Roberto Gargarella señala una serie de soluciones intermedias frente a las posturas que buscan justificar el control judicial de las leyes desde posiciones elitistas y populistas. Una de ellas es el juicio por jurados. Así, el autor mencionado destacaba, en aquel momento, que esta vía de juzgamiento podía ser una forma de contribuir a la “democratización” de la justicia.

A diferencia de aquellos años, en que ninguna provincia había incorporado este sistema, al día de hoy es una realidad consolidada en 13 jurisdicciones del país. Es por esa razón que, treinta años después, corresponde volver sobre este método de juzgamiento y analizar si se ha cumplido la profecía.

Pero primero vale la pena efectuar unas pequeñas aclaraciones introductorias para el lector.

El juicio por jurados, actualmente y en líneas generales, implica que 12 ciudadanos y ciudadanas decidan la suerte de la persona acusada en un juicio sólo en cuanto a los hechos que son motivo de acusación, no sobre el derecho. Esta es la conformación del llamado “modelo clásico”, que es el que más difusión ha tenido en nuestro país y a lo largo del mundo, aunque también pueda adoptar la forma de un tribunal “escabinado”, lo que significa que el jurado lo conforman jurados junto con algunos jueces profesionales.

Para alcanzar su veredicto, existe una serie de pasos procesales en los cuales intervienen todas las partes del proceso, siendo la autoridad judicial la encargada de guiar el camino. En el modelo clásico, la deliberación de los jurados es secreta y no exponen expresamente los fundamentos

de su veredicto, que únicamente se limita a ser de culpabilidad o no culpabilidad.

Ahora bien, parece evidente que el juicio por jurados es una institución que permite una suerte de democratización de la justicia al permitir que la ciudadanía juzgue a sus pares, como propuso tempranamente Roberto Gargarella en su obra.

Sin embargo, lo que falta ahondar es de qué manera concreta, a través de qué mecanismos o por intermedio de qué rasgos es que el jurado contribuye a aumentar la legitimidad democrática del Poder Judicial. Son conocidas las respuestas que se enfocan en la deliberación de sus decisiones o la mayor imparcialidad que se logra a través del proceso de selección que atraviesa el jurado. Estos mecanismos aparecen de forma recurrente en la discusión sobre jurados, mientras que existe uno, llamado *jury nullification*, que pese a contribuir de un modo concreto a la dificultad contramayoritaria, no ha sido estudiado lo suficiente.

Se trata de la posibilidad de que el jurado invalide los alcances de una ley (digamos, el Código Penal) a sabiendas de que ella, a todas luces y para todos los presentes, debía aplicarse al caso concreto y conducir a un resultado específico. En simples palabras, ocurre cuando los jurados resuelven por la no culpabilidad, a pesar de que correspondía declarar culpable al acusado, según el derecho aplicable y lo que, para un observador objetivo, se encontraba probado en el juicio. En muchos de estos casos, la decisión puede ser la cristalización de una abierta oposición a las consecuencias del veredicto de culpabilidad.

Es cierto que tal veredicto de no culpabilidad bien podría ser fruto de instrucciones erróneamente impartidas o una interpretación distinta de los elementos de prueba producidos en juicio. Aún con esta salvedad, la posibilidad que la ciudadanía tiene de optar por la no aplicación de una norma en un caso concreto es clara y evidente. Son precisamente la deliberación secreta y la falta de expresión de fundamentos –*esto último sólo respecto del modelo clásico*–, sumado al carácter irrecurrible del veredicto absolutorio y la prohibición del doble juzgamiento, las circunstancias que han sido identificadas como fundamento del poder que tienen los jurados para decidir por una declaración de no culpabilidad contraria a la ley.

No resulta sorprendente advertir que este mecanismo revela desde su propio origen una tensión existente entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Antigüamente y hasta mediados del siglo XIX, en el derecho anglosajón, el jurado tenía la potestad de decidir tanto cuestiones de hecho como de derecho –a diferencia de la actualidad donde su decisión se limita a las primeras–, apelando en última instancia a la conciencia de cada individuo, lo que constituía un medio por el cual el pueblo ponía un freno efectivo al poder opresivo del Estado al rehusar la aplicación de una ley en un caso concreto, en contra de las instrucciones expresas del tribunal sobre cuál era la ley aplicable.

En el Reino Unido, tuvo su auge durante el siglo XVIII en las acusaciones formuladas por el gobierno contra los opositores políticos bajo la ley de *seditious libel* que permitía criminalizar publicaciones disidentes que eran consideradas difamatorias respecto del poder, mientras que en los Estados Unidos adquirió preponderancia en la época colonial, cuando los jurados se negaban a aplicar las leyes de navegación que buscaban garantizar un monopolio británico, así como también luego de la independencia en la época de la Ley de Esclavos Fugitivos de 1850, cuya eficacia fue puesta en jaque por la negativa de los jurados a condenar.

Puntualmente, el declive del *jury nullification* se produjo a raíz de una serie de casos en los que el Poder Judicial, bajo argumentos principalmente vinculados al principio de legalidad, se reservó la potestad de decidir sobre la ley aplicable y sólo dejó al jurado la potestad de decidir sobre los hechos.

Este panorama condujo a que en la actualidad, en los Estados Unidos, si bien la potestad de nulificar es reconocida como un poder *de facto* del jurado, no es considerada un derecho. Por ello, los tribunales se encuentran vedados de comunicar esta posibilidad en las instrucciones que le brindan, tanto en el sistema judicial federal como el estadual, con la excepción de algunos pocos estados. Sin embargo, se ha destacado el valor que continúa teniendo la institución como correctivo de la rigidez de las leyes generales cuando resultan opresivas en casos concretos, dotando de legitimidad democrática al ejercicio de la función judicial.

Ahora bien, lo cierto es que para responder las interrogantes anteriormente planteadas hay que abandonar momentáneamente el plano puramente teórico para observar cómo opera el juicio por jurados en la práctica argentina. En efecto, si el *jury nullification* puede ser entendido como una forma de control ciudadano directo sobre la aplicación de la ley en un caso concreto, resulta necesario analizar los supuestos en los que los veredictos dictados por jurados populares parecen haberse apartado de la solución que, al menos desde una perspectiva de un juez técnico, cabría esperar.

Uno de los antecedentes más tempranos puede encontrarse en la provincia de Córdoba con el caso "Eli" (2006): María Elizabeth Díaz, una joven empleada doméstica, fue llevada a juicio acusada del homicidio calificado de su hija recién nacida. Durante el proceso, sostuvo que el embarazo había sido consecuencia de los abusos sexuales sistemáticos sufridos desde los nueve años de edad por parte de su empleador, Arturo Benavidez. Mientras la fiscalía solicitó una pena de ocho años de prisión por homicidio calificado

en virtud del vínculo aunque mediando circunstancias excepcionales de atenuación, la defensa argumentó que “Eli” había actuado en un estado de inconsciencia derivado de las secuelas psicológicas provocadas por años de abusos y por el propio parto, que le impidió comprender la criminalidad de sus actos.

De acuerdo a lo previsto en la legislación cordobesa, el tribunal escabinado encargado de juzgar el caso estuvo integrado por dos jueces técnicos y ocho jurados populares. Al emitirse el veredicto, seis de los ocho jurados legos se pronunciaron por la absolución de la acusada, apartándose del criterio sostenido por los jueces profesionales, quienes entendían que correspondía declarar culpable a “Eli”, aunque ponderando el contexto de abuso sufrido. Fue la primera vez que el jurado popular se apartó de la posición sostenida por los jueces técnicos, circunstancia para la cual la legislación procesal provincial no había previsto una solución expresa.

Ello obligó al tribunal a enfrentar una situación inédita al momento de traducir el veredicto en una decisión judicial formal, que terminó siendo de no culpabilidad. En este sentido, resulta de especial interés lo decidido por los jurados legos, si se toma en consideración que los hechos del caso “Eli” son muy similares al fallo “Tejerina” de la CSJN, donde los ministros de la Corte dejaron firme la condena de 14 años de prisión a Romina Tejerina por homicidio agravado por el vínculo de su hija recién nacida, con circunstancias extraordinarias de atenuación.

Otro antecedente relevante es el caso de Sebastián Bachetti y Estefanía Santa Cruz (2006), también de la provincia de Córdoba. Fueron juzgados por la muerte de su hija de cuatro meses de edad, que falleció a causa de las reiteradas lesiones que Estefanía le había provocado. Durante el juicio, quedó acreditada la responsabilidad de ambos progenitores en los hechos, sin embargo, los jurados populares consideraron que la pena de prisión perpetua prevista para esa figura resultaba excesiva y expresaron de manera unánime ante los jueces técnicos su oposición a im-

poner dicha sanción. A su entender, una pena cercana a los dieciocho años de prisión resultaba más justa, aún a sabiendas que no era materia de su competencia.

Estos casos reflejan la esencia del *jury nullification*, pues la discrepancia de los jurados no parecía recaer sobre la existencia del hecho ni sobre la responsabilidad de los acusados, sino sobre las consecuencias jurídicas que correspondía aplicarles, probablemente por entenderla excesivamente gravosa. Debido a las particularidades del jurado escabinado, sabemos que esta era la intención exacta del jurado, dado a que tienen que exponer los fundamentos, a diferencia del modelo clásico.

El siguiente caso es muy distinto. En la Provincia de Buenos Aires, Daniel Oyarzún (2016) se encontraba trabajando en su carnicería cuando dos hombres armados ingresaron al local para robar. Tras ello, los asaltantes emprendieron la huida en motocicleta, a quienes Oyarzún persiguió en su auto. Durante la persecución, los delincuentes continuaron disparando contra él, luego perdieron el control de la motocicleta, cayeron al asfalto y Oyarzún embistió con su vehículo a Brian González, uno de los asaltantes, quien quedó herido de gravedad en el suelo. Luego, recibió golpes propinados tanto por Oyarzún como por algunos vecinos que se acercaron al lugar, lo que produjo su fallecimiento horas más tarde como consecuencia de las lesiones sufridas.

En el juicio, el jurado debió optar entre tres alternativas: declararlo culpable por homicidio simple, tal como requería la querella; declararlo culpable por haber excedido los límites de la legítima defensa, conforme la acusación de la fiscalía; o dar un veredicto de no culpabilidad por considerar que había actuado amparado por dicha causa de justificación. Finalmente, el jurado se inclinó por la última opción.

No debe perderse de vista que el hecho se produjo en un contexto de fuerte preocupación social por los altos índices de inseguridad y generó una inmediata identificación de amplios sec-

tores de la ciudadanía con Oyarzún, quien momentos antes del desenlace fatal había sido víctima de un robo violento. De hecho, su detención motivó manifestaciones de apoyo vecinal y una amplia cobertura mediática.

Naturalmente, el carácter secreto de las deliberaciones impidió conocer las razones que condujeron al veredicto absolutorio; sin embargo, resulta difícil ignorar que los jurados resolvieron un caso que había sido intensamente debatido en la esfera pública y respecto del cual una parte significativa de la sociedad parecía considerar que el acusado no merecía una condena penal. Es justamente por ello que invita a preguntarse si el veredicto de no culpabilidad constituyó simplemente una determinada interpretación de los alcances de la legítima defensa –o bien, su exceso– o si, por el contrario, expresó una forma de resistencia ciudadana frente a las consecuencias jurídicas que podían derivarse de una aplicación más estricta de la ley penal.

En efecto, el catálogo de casos propuesto permite advertir cómo la participación ciudadana en la administración de justicia introduce valoraciones morales, políticas y sociales que no siempre coinciden con las soluciones previstas por el legislador –que, tal como es esperable, aplicaría un juez técnico–, lo que genera que los jurados decidan no aplicar el derecho.

Siguiendo la línea de *La justicia frente al gobierno*, frente al déficit democrático que presenta la justicia, cabe preguntarse si realmente el juicio por jurados es un mecanismo que logra superar el déficit democrático o si simplemente lo desplaza sin resolverlo. La propia mecánica del instituto implica introducir directamente a la ciudadanía en la administración de justicia,

pero lo hace de un modo acotado a la división tradicional de funciones según la cual el jurado decide sobre los hechos, mientras que el juez establece y explica el derecho aplicable.

Es en este punto donde cobra relevancia el *jury nullification*: cuando el jurado pronuncia un veredicto de no culpabilidad pese a considerar acreditados los hechos y a que la aplicación ordinaria de la ley conduciría a una condena, no invalida formalmente la norma, pero se niega a aplicarla en el caso concreto por vía de la declaración de no culpabilidad. De ese modo, su intervención deja de limitarse a la determinación de los hechos y se convierte en una forma incidental de control popular sobre la aplicación de la ley. La cuestión consiste, por lo tanto, en determinar si ese poder de veto permite reducir el déficit democrático de la justicia al devolver a la ciudadanía cierta capacidad de decisión sobre la aplicación de una ley emanada por un cuerpo destinado a constituirse en “voz” de la ciudadanía.

Nos permitimos dar una respuesta afirmativa a esta cuestión. Entendemos que, en casos particularmente difíciles, en donde la justicia está “en la mira de todos” y en donde la ciudadanía tiene un especial interés, como algunos de los que reseñamos previamente, la justicia tiene que tomar una decisión que, aunque sea legal, puede erosionar su legitimidad popular y no satisfacer el ideal de justicia que tiene la ciudadanía. Por ello, cuando se trata de casos especialmente sensibles, depositar esa decisión en el jurado, que tiene la potestad de no aplicar la ley si la considera injusta y no estaría sujeto a las mismas objeciones, por su mayor legitimidad democrática, parece una mejor solución. ■



Nosotros somos los otros

por Giuseppe Martinico

*Una perspectiva de derecho constitucional sobre la invisibilidad del poder en *El Eternauta.*

30 de junio de 2026



Viñetas de *El Eternauta* en las que uno de los «Ellos» explica el funcionamiento de la jerarquía de la invasión extraterrestre y el sometimiento de las distintas especies. Guion de Héctor Germán Oesterheld e ilustraciones de Francisco Solano López. © Los titulares de los derechos. Reproducida con fines de crítica e investigación.

El objetivo de mi breve contribución es explorar la invisibilidad del poder a través del prisma de una de las obras maestras de la ciencia ficción latinoamericana: *El Eternauta*, escrita por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López. Voy a tomar en cuenta especialmente la primera parte, ya que las siguientes son más explícitas en la representación de la vida bajo el régimen de los Ellos o no siempre fueron escritas por Oesterheld. En una época en la que las historietas están siendo revalorizadas también en el mundo occidental y en la que los cómics, en general, ya no se consideran una subcultura, se aprecia mucho mejor la figura de gigantes como el autor de *El Eternauta*, quien influyó en grandes intelectuales como *Borges* y, a su vez, recibió también su influencia.

Idealmente estas páginas se inscriben dentro del enfoque conocido como “*Law and Pop Culture*”. Retomando las metáforas del espejo y la lámpara desarrolladas por *Michael Asimow*, creo que se puede afirmar que los cómics reflejan las percepciones sociales sobre el derecho y, al mismo tiempo, contribuyen a modelar los imagina-

rios colectivos de la justicia, lo que nos permite observar el derecho desde una perspectiva diferente.

Asimismo, el hecho de que los cómics circulen en distintos contextos jurídicos y culturales demuestra su **potencial transnacional**. Al dirigirse a un público que trasciende las fronteras nacionales, crean un lenguaje visual común mediante el cual las preocupaciones sobre el derecho, la justicia y la autoridad pueden ser abordadas colectivamente. Esta reflexión resulta especialmente relevante en un momento en el que la democracia pierde terreno, el constitucionalismo se debilita y los límites del derecho constitucional se hacen cada vez más evidentes. En este sentido, los cómics no solo constituyen un espejo de las preocupaciones jurídicas contemporáneas, sino también una luz que **ilumina la fragilidad de la propia democracia constitucional**.

Como constitucionalistas, solemos concentrarnos en la arquitectura visible del poder: las instituciones, los tribunales y las leyes. Sin embargo, *El Eternauta* nos obliga a dirigir la mirada hacia las dimensiones invisibles de la autoridad, aquellas fuerzas que operan desde las sombras o, peor aún, que emergen desde el interior mismo de nuestra vida cotidiana. No me detendré aquí en reconstruir la trama de esta obra icónica, que doy por conocida entre los lectores de esta Revista, pero sí quisiera destacar una de sus escenas iniciales, de enorme fuerza simbólica y particularmente relevante para el propósito de este trabajo.

En una noche de invierno en Buenos Aires, un grupo de amigos juega al truco dentro de una casa herméticamente cerrada. De repente, comienza a caer una nieve silenciosa, luminosa y mortal.

Es el principio del fin de lo que, a primera vista, parece una invasión alienígena; pero ¿quiénes son realmente los extraterrestres? ¿Acaso son algo distinto de los seres humanos? La historia de *El Eternauta* gira precisamente en torno a esta pregunta. En una *entrevista* concedida a Televisión Pública hace unos años, Estela Barnes de Carlotto, figura destacada del famoso movimiento Abuelas de Plaza de Mayo, describió al antiguo dictador argentino Jorge Rafael Videla no como un ser humano, sino como alguien que había perdido su humanidad: un “extraterrestre”. Esta llamativa observación sirve como punto de partida idóneo para analizar *El Eternauta*. Se trata también de una poderosa advertencia: a menudo, los enemigos de la democracia no provienen del exterior, sino que se alimentan de las estructuras democráticas y surgen desde dentro.

Para comprender la invisibilidad del poder debemos volver a la historieta original y no a la reciente *adaptación de Netflix*. En la serie de Netflix, la nevada letal ocurre durante una *noche de verano*. Aunque esta decisión resulta visualmente impactante, modifica el significado metafórico profundo de la obra original, donde la nieve cae durante una noche invernal. Precisamente porque ocurre en invierno, el cambio traumático aparece como algo casi natural, fundiéndose con un fenómeno meteorológico esperado. Esto vuelve mucho más insidiosa e invisible la irrupción de la amenaza externa: la violencia estatal y la perversión totalitaria se normalizan, confundidas con la aparente inevitabilidad de un hecho cotidiano. Aunque Oesterheld suele ser presentado como un autor “profético”, la historieta está profundamente arraigada en la historia argentina, caracterizada por elementos que se repetían cíclicamente en aquellos años.

Sin desconocer su extraordinaria capacidad visionaria, debe subrayarse que Oesterheld supo sobre todo identificar con notable lucidez las vulnerabilidades estructurales y los patrones cíclicos que históricamente condujeron a los colapsos democráticos en la Argentina. A lo largo del siglo XX, el país sufrió seis golpes de Esta-

do exitosos (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976). El último de ellos llevó al poder al general Jorge Rafael Videla.

Para comprender esta dinámica propongo articular el análisis en torno a cinco conceptos: invisibilidad, terror, delegación, atomización y memoria.

En cuanto a la *invisibilidad*, en la historieta, los verdaderos responsables de la invasión —los Ellos— permanecen completamente invisibles. No tienen rostro, ubicación precisa ni forma reconocible. Actúan como una presencia abstracta y elusiva, un verdadero una forma de vacío que remite a la conceptualización de Hannah Arendt en *Los orígenes del totalitarismo*.

Como sostuvo Arendt, el *terror* totalitario prospera precisamente gracias a la invisibilidad y la imprevisibilidad, produciendo un estado psicológico cualitativamente distinto del miedo ordinario.

En cuanto la *delegación*, los Ellos nunca ejercen directamente la violencia, sino que recurren a una rígida cadena piramidal de delegación. Utilizan a los *Gurbos*, a los *Cascarudos* y, finalmente, a los *Humanos -Robot* y a los *Manos*.

Entre estos intermediarios desempeñan un papel especialmente significativo los *Manos*. Su nombre deriva precisamente de su rasgo físico distintivo: son una especie altamente inteligente y artística dotada de enormes manos con numerosos dedos. Este detalle anatómico posee un profundo significado simbólico. En la tradición cultural, las manos representan la creación, el arte y el contacto humano. Sin embargo, los Ellos han convertido esos extraordinarios dedos en instrumentos destinados a operar los mecanismos de la destrucción.

Los *Manos* obedecen porque llevan implantada una “glándula del terror”, diseñada para provocarles la muerte en el momento en que experimenten ansiedad, disenso o cualquier forma de pensamiento autónomo.

Esta construcción narrativa constituye una representación extraordinariamente eficaz de lo que Hannah Arendt denominó la “*banalidad del*

mal” durante el juicio a Eichmann. El mal ya no aparece como una fuerza demoníaca o monstruosa, sino como una rutina burocrática y despersonalizada. Los Manos son los funcionarios eficientes y meticulosos de una maquinaria de muerte, los “demonios mediocres” de la modernidad. Habitan esa trágica “zona gris” de la colaboración: son al mismo tiempo victimarios y víctimas de una maquinaria mucho más amplia. Mediante la fragmentación de las acciones y la delegación de responsabilidades, la estructura totalitaria permite que cada ejecutor se perciba simplemente como un engranaje, diluyendo así toda responsabilidad moral individual.

Otro mecanismo totalitario que debemos analizar es la *atomización* social. La nevada mortal destruye instantáneamente el tejido social, obligando a los individuos a un aislamiento radical.

Según Arendt, la creación del “hombre masa”, aislado, apolítico y despojado de vínculos comunitarios, constituye la condición sociológica indispensable para la dominación total. Cuando desaparecen los vínculos sociales, perdemos también nuestro “sentido común”, que se encuentra ontológicamente arraigado en la relación con los demás. Sin esa red compartida de significado, los individuos quedan completamente expuestos a la propaganda, al terror y a la obediencia pasiva.

Frente a esta fragmentación individualista, El Eternauta introduce su mensaje político más radical: el rechazo del héroe solitario. Juan Salvo no es un superhéroe dotado de capacidades excepcionales; es un *hombre común*. En el universo de Oesterheld, el excepcionalismo individual es incapaz de derrotar al poder absoluto. La supervivencia —y, en última instancia, la resistencia— solo son posibles mediante la cooperación y la reconstrucción de los lazos de solidaridad. El grupo, el *héroe colectivo*, constituye así un poderoso antídoto democrático y constitucional frente al aislamiento totalitario.

Como se señala en un famoso diálogo de la obra, a pesar de la destrucción y la aniquilación, lo que realmente importa es la “supervivencia

del espíritu”, que debe alimentarse de la narración.



Escena de El Eternauta en la que el Anciano dialoga con Juan Salvo sobre la supervivencia del espíritu. Guion de Héctor Germán Oesterheld e ilustraciones de Francisco Solano López. © Los titulares de los derechos. Reproducida con fines de crítica e investigación.

Ello nos conduce a la cuestión jurídica central: ¿qué papel desempeña el derecho cuando comienza a caer la nieve?

El inicio de la catástrofe sumerge a los protagonistas en aquello que Giorgio Agamben, desarrollando las intuiciones de Carl Schmitt, denominaría tal vez un *estado kenomático*: un vacío jurídico, una auténtica suspensión del derecho, un verdadero estado de excepción. La invasión de los Ellos podría interpretarse como un poder constituyente destructivo que arrasa el orden jurídico preexistente para instaurar un nuevo régimen de sometimiento absoluto.

Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que durante las transiciones totalitarias el orden jurídico formal suele permanecer aparentemente intacto. El fascismo nunca derogó formalmente el *Estatuto Albertino* en Italia; del mismo modo, durante la dictadura militar de Jorge Rafael Videla la Constitución argentina de 1853 nunca fue formalmente abolida. Lo que ocurrió fue que, en los hechos, la Constitución quedó subordinada a una serie de instrumentos jurídicos dictados por el Proceso, empezando por el *Estatuto del Proceso*. El totalitarismo no siempre anuncia su llegada reescribiendo los textos constitucionales: con frecuencia los vacía de contenido desde su interior.

En ese vacío jurídico, ¿cómo debemos interpretar las acciones violentas de Juan Salvo y sus

compañeros? ¿Cabe hablar de desobediencia civil?

Como sostuvo John Rawls, la desobediencia civil presupone una “fidelidad a la ley” del sistema jurídico que se critica: es estructuralmente no violenta, selectiva e implica la disposición a asumir las consecuencias jurídicas de los propios actos. Las acciones de Juan Salvo trascienden claramente ese marco. Lo que observamos es el ejercicio del derecho de resistencia.

El derecho de resistencia ha sido reconocido en diversas tradiciones constitucionales nacidas del trauma del autoritarismo. Así ocurre, por ejemplo, con el artículo 20, apartado 4, de la Ley Fundamental alemana, que lo configura como una última ratio, admisible únicamente “cuando no exista otro remedio” para preservar el orden constitucional. Disposiciones similares pueden encontrarse en el artículo 21 de la Constitución portuguesa, en el artículo 23 de la Constitución checa y en diversos textos constitucionales latinoamericanos.

Como muestra el derecho constitucional comparado, la constitucionalización del derecho de resistencia cumple una función dual y al mismo tiempo frágil. Por un lado, constituye un instrumento orientado al futuro, destinado a fortalecer a la ciudadanía y prevenir procesos de erosión democrática. Por otro, entraña importantes riesgos interpretativos, ya que históricamente ha sido invocado retrospectivamente por quienes protagonizaron golpes de Estado para justificar sus propias rupturas del orden constitucional.

En El Eternauta, Juan Salvo y sus compañeros ejercen ese derecho en su forma más pura y existencial. No luchan por un programa político determinado, sino por preservar lo que queda de sus vidas anteriores, de sus afectos y de su libertad para seguir siendo humanos, evitando ser transformados en instrumentos automáticos

y desprovistos de memoria al servicio del Estado.

Finalmente, no es posible separar este análisis jurídico y literario de la trágica biografía de su autor. Héctor Germán Oesterheld no solo escribió sobre la guerra sucia y las desapariciones forzadas: terminó siendo una de sus víctimas. En 1977, durante la dictadura de Videla, Oesterheld fue secuestrado junto con sus hijas y pasó a integrar la larga lista de los desaparecidos.

Leída desde esta perspectiva, El Eternauta trasciende los límites de la ciencia ficción y de la cultura popular para convertirse en un poderoso instrumento de memoria colectiva y esto nos lleva a nuestra última palabra clave. La estructura temporal circular de la historieta, con Juan Salvo condenado a vagar eternamente a través del tiempo, adquiere un profundo significado simbólico: representa la persistencia de una memoria histórica que se resiste a ser borrada por la falsa pacificación o por el olvido impuesto por los regímenes totalitarios.

La amenaza en El Eternauta resulta aterrador porque, al igual que una repentina nevada invernal, surge desde el interior mismo de la vida cotidiana. La obra nos advierte que las semillas del totalitarismo no siempre provienen del exterior: constituyen una perversión latente que puede anidar dentro de cualquier sistema democrático y constitucional.

Resistir, como nos enseña Juan Salvo, significa preservar nuestra humanidad, rechazar la atomización y seguir contando nuestra historia. El verdadero escudo de todo orden constitucional no reside únicamente en el texto de la Constitución, sino también en la memoria activa y colectiva de la ciudadanía. Porque, como sutilmente nos recuerda la saga, si perdemos la vigilancia, los verdaderos “otros”, los monstruos definitivos, podríamos terminar siendo nosotros mismos. ■



La Corte contra los inmigrantes

por Irwin Stotzky

Las sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos en materia de inmigración anteponen el poder ejecutivo a la rendición de cuentas constitucional y dismantelan el control judicial efectivo.

30 de junio de 2026

El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó dos sentencias en materia de inmigración que marcarán el derecho estadounidense durante años, con profundas consecuencias para la estructura constitucional y la política migratoria. En el caso *Mullin v. Doe* (acumulado con *Trump v. Miot*), la Corte eximió en gran medida a la decisión del Poder Ejecutivo de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) del control judicial. En *Mullin v. Al Otro Lado*, la Corte sostuvo que los migrantes que esperan en los puertos de entrada no han «llegado a Estados Unidos» en el sentido de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y, por lo tanto, se les puede denegar incluso la oportunidad de solicitar asilo. Ambas sentencias fueron redactadas por el juez Samuel Alito en nombre de una mayoría de 6 contra 3. En conjunto, representan una de las ampliaciones más significativas de la autoridad ejecutiva en materia de inmigración en la historia constitucional moderna.

Las consecuencias jurídicas son inmediatas y profundas. Cientos de miles de personas que han vivido legalmente en Estados Unidos al amparo del Estatus de Protección Temporal se enfrentan ahora a la perspectiva de ser expulsadas a países que siguen siendo peligrosos e inestables. Al mismo tiempo, a cientos de miles de solicitantes de asilo que huyen de la persecución se les podría impedir siquiera presentar sus solicitudes ante las autoridades estadounidenses. La Corte presentó ambas decisiones como simples ejercicios de interpretación legislativa y moderación judicial. Pero, consideradas en su conjunto, revelan algo más preocupante: un Poder Judicial ca-

da vez más deferente, reacio a examinar de forma significativa la actuación del poder ejecutivo en los casos de inmigración, incluso cuando se alegan violaciones de la ley y reclamaciones constitucionales.

La decisión sobre el TPS ilustra esta deriva con claridad. El Congreso creó el TPS porque algunos países se ven tan sumidos en conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias extraordinarias que obligar a sus nacionales a regresar sería inaceptable. Muchos beneficiarios del TPS llevan décadas viviendo en Estados Unidos. Han criado a hijos con ciudadanía estadounidense, han comprado viviendas, han creado negocios, han pagado impuestos y se han integrado profundamente en sus comunidades. Sin embargo, la decisión de la Corte permite al Poder Ejecutivo poner fin a esas protecciones con una supervisión judicial limitada.

Es importante destacar que los demandantes no solo impugnaron el resultado de la política. También alegaron que la decisión de revocación no cumplía con los procedimientos legales exigidos por el Congreso como condición para la administración legítima del TPS. Según la ley vigente, el secretario de Seguridad Nacional debe revisar periódicamente la situación de los países, consultar con las agencias federales pertinentes y tomar una decisión basada en pruebas sobre si se siguen cumpliendo los criterios legales para la designación del TPS. Los demandantes alegaron que estos requisitos no se cumplieron de manera significativa en el caso de la revocación del TPS de Haití. En cambio, argumentaron, el proceso administrativo reflejó una decisión política predeterminada de poner fin al TPS de manera

generalizada, seguida de una racionalización a posteriori, en lugar de una evaluación genuina e individualizada de las condiciones del país.

En otras palabras, los demandantes alegaron no solo que la decisión era inconveniente o severa, sino que no se tomó de la manera que exige la ley. Los requisitos procesales de este tipo son fundamentales en el derecho administrativo. Son el medio por el que el Congreso limita la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y garantiza que las decisiones que afectan a cientos de miles de residentes legales se adopten mediante procesos razonados y basados en pruebas, en lugar de por mera voluntad política. Incluso cuando las leyes otorgan amplia discrecionalidad, dicha discrecionalidad está condicionada al cumplimiento de los procedimientos que el propio Congreso ha establecido.

Sin embargo, la Corte se negó en gran medida a abordar seriamente esa cuestión. Consideró que la resolución del Secretario se inscribía en un ámbito de discrecionalidad exento, en los hechos, de control judicial. En consecuencia, la Corte no examinó seriamente si se habían seguido en lo sustancial los procedimientos legales ni si la decisión reflejaba el tipo de juicio administrativo razonado que exige la ley. El efecto es restringir significativamente la aplicación judicial de las limitaciones procesales impuestas por el Congreso, lo que permite que se mantengan en vigor importantes medidas ejecutivas incluso cuando se han presentado alegaciones sustanciales de incumplimiento legal.

Esa deferencia tiene consecuencias que van más allá del TPS. Las garantías procesales no son meros tecnicismos; son el mecanismo principal mediante el cual el Congreso garantiza la rendición de cuentas en el Poder Ejecutivo delegado. Cuando los tribunales se niegan a hacer cumplir esas garantías, incluso en casos que afectan a la situación legal de grandes poblaciones, el resultado no es simplemente una moderación judicial, sino un desplazamiento del equilibrio constitucional, alejándolo del control judicial y acer-

cándolo a una administración ejecutiva sin control.

Para muchos beneficiarios del TPS, la expulsión no es simplemente una cuestión de reubicación. Significa regresar a lugares donde la seguridad y la supervivencia pueden estar en peligro. En ningún sitio es esa realidad más evidente que en Haití.

Haití atraviesa hoy una de las crisis humanitarias más graves del hemisferio occidental. Gran parte de Puerto Príncipe sigue bajo el control de bandas fuertemente armadas. Los secuestros, los asesinatos y la violencia sexual están generalizados. Las instituciones gubernamentales básicas han colapsado en gran medida. Los hospitales se esfuerzan por seguir funcionando, las escuelas han cerrado, la inseguridad alimentaria ha alcanzado niveles catastróficos y cientos de miles de personas se han visto desplazadas internamente. Las organizaciones internacionales han advertido repetidamente del peligro extraordinario que corren los civiles. Para los beneficiarios haitianos del TPS que llevan mucho tiempo establecidos en el país, la expulsión no supone meramente la pérdida de su estatus legal; es un retorno forzoso a un país donde el Estado no puede garantizar de forma fiable ni siquiera la seguridad básica ni la subsistencia.

La Corte no reconoció ninguna de estas realidades en ningún sentido constitucional significativo. En cambio, la mayoría se centró casi exclusivamente en el texto legal y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Si bien es indudable que el Congreso otorgó al Ejecutivo una autoridad sustancial sobre las designaciones del TPS, el derecho administrativo y constitucional ha presumido tradicionalmente que los tribunales siguen estando facultados para revisar la actuación del ejecutivo —especialmente cuando se plantean intereses sustanciales en materia de libertad y denuncias de discriminación inconstitucional—. El enfoque de la mayoría reduce drásticamente esa presunción, aislando de hecho amplias categorías de decisiones en materia de inmigración de un escrutinio judicial significativo.

La cuestión de la cláusula de igual protección es donde el fallo resulta aún más preocupante. Los demandantes haitianos alegaron que la decisión de poner fin a la designación del TPS para Haití estuvo motivada, al menos en parte, por la discriminación racial. Se basaron en el marco establecido en *Village of Arlington Heights v. Metropolitan Housing Development Corp.*, según el cual los demandantes no necesitan demostrar que la discriminación fuera el único motivo detrás de la acción gubernamental; basta con demostrar que fue un «factor motivador».

El juez Alito reconoció las pruebas del expediente, pero concluyó que existía una explicación alternativa: que la Administración pretendía poner fin a todas las designaciones de TPS porque se oponía al programa como cuestión de política general. Según la mayoría, esto constituía una «explicación sólida y no discriminatoria por motivos raciales» para la decisión.

Ese razonamiento se aleja del propio caso *Arlington Heights*. La doctrina constitucional reconoce desde hace tiempo que las decisiones gubernamentales suelen tener múltiples motivaciones. La existencia de una justificación no basada en la raza no niega la posibilidad de que la raza también haya desempeñado un papel. Se viola la Cláusula de Igual de Protección cuando la intención discriminatoria es un factor motivador entre otros; no se requiere exclusividad.

La disidencia de la jueza Elena Kagan resaltó con firmeza este punto. Explicó que la mayoría transformó, en la práctica, *Arlington Heights* en una prueba de «todo o nada» que la Corte nunca ha adoptado. La Constitución exige a los tribunales que evalúen si la raza fue un factor motivador en el proceso de toma de decisiones, no si fue la única causa.

Quizá aún más revelador sea el tratamiento que la mayoría da a las declaraciones públicas en las que se basaron los demandantes. La Corte concluyó que «ninguna de las declaraciones citadas, ni del presidente ni del secretario, era abiertamente racial, y en esencia todas expresaban opiniones políticas que podían basarse en

justificaciones no raciales». Esas dos palabras — «abiertamente racial» — pueden resultar ser una de las señales doctrinales más significativas del fallo.

La jueza Kagan no se limitó a caracterizar las declaraciones; las reprodujo. Entre ellas figuraban afirmaciones de que los haitianos «se comían a los perros» y «se comían a los gatos», sugerencias de que los haitianos «probablemente tienen sida», descripciones de Haití como un «país de mierda» que es «asqueroso, sucio [y] repugnante», advertencias de que la inmigración haitiana era «como una pulsión de muerte para nuestro país», referencias a los inmigrantes como «envenenadores de la sangre» de los Estados Unidos, y comparaciones que favorecerían la inmigración procedente de Noruega o Suecia frente a la de Haití o Somalia.

La mayoría desestimó estos comentarios por no ser «abiertamente racistas». La jueza Kagan respondió que estaban «impregnados de estereotipos y tropos raciales» y que «gritan a las claras» que la raza influyó en el proceso de toma de decisiones. Los jueces, observó, «no están obligados a mostrar una ingenuidad de la que los ciudadanos de a pie están exentos».

Ese desacuerdo afecta al núcleo de la doctrina moderna de la igual de protección. Rara vez los funcionarios anuncian explícitamente una intención discriminatoria. Precisamente por eso *Arlington Heights* instruye a los tribunales a tener en cuenta el contexto, la secuencia de los hechos, los antecedentes históricos y el lenguaje en clave o indirecto. La discriminación en la gobernanza moderna se expresa a menudo a través de insinuaciones más que de declaraciones.

Al hacer hincapié en si las declaraciones eran «abiertamente raciales», la mayoría parece elevar el umbral probatorio más allá de lo que exige *Arlington Heights*. Si las repetidas descripciones de una población inmigrante predominantemente negra como enferma, criminal, contaminante o inferior son insuficientes incluso para desencadenar un escrutinio judicial significati-

vo, resulta difícil imaginar qué podría violar la Cláusula de Igual Protección.

La decisión sobre el asilo refleja un enfoque judicial paralelo. El juez Alito planteó la cuestión como un simple problema de interpretación legal: si una persona que espera en un puerto de entrada ha «llegado a Estados Unidos». Dado que el uso común sugiere que alguien que se encuentra físicamente fuera del país no ha «llegado a» él, la mayoría concluyó que dichas personas ni siquiera tienen derecho a solicitar asilo.

Si se analiza el texto de forma aislada, el razonamiento tiene cierta claridad superficial. Pero las leyes no son palabras aisladas, sino marcos legislativos integrados. El Congreso creó el sistema moderno de asilo para garantizar que las personas que huyen de la persecución tuvieran una oportunidad real de solicitar protección. La interpretación del Tribunal permite al Poder Ejecutivo anular de hecho esa garantía al impedir que los solicitantes de asilo superen un umbral procesal que determina si la ley es aplicable en absoluto.

Las consecuencias humanas son considerables. A las personas que huyen de la persecución política, la opresión religiosa, la violencia étnica, la tortura o amenazas creíbles contra su vida se les puede impedir ahora incluso presentar solicitudes de asilo prima facie ante las autoridades estadounidenses. Muchas nunca llegarán a ver a un funcionario de asilo ni a un juez de inmigración. Sus solicitudes nunca serán escuchadas.

Consideradas por separado, cada una de estas decisiones podría verse como un ejercicio de textualismo y moderación judicial. Consideradas en conjunto, reflejan una transformación constitucional más amplia: la expansión sistemática de la autoridad ejecutiva en materia de

inmigración, acompañada de una reducción del control judicial y de la aplicación de la Constitución.

Esta tendencia resulta especialmente preocupante en el contexto de la inmigración, donde las garantías constitucionales son más necesarias. Si bien los poderes políticos poseen una amplia autoridad en materia de inmigración, no tienen una autoridad ilimitada. Desde hace tiempo se entiende que la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda incorpora principios de igual protección que limitan la actuación federal. Aun así, el juez Clarence Thomas, en un voto concurrente separado, sugirió reconsiderar si los no ciudadanos gozan de derechos de igualdad de protección frente al Gobierno federal — una postura que supondría una ruptura radical con la doctrina constitucional establecida.

Estadounidenses sensatos pueden discrepar sobre la política de inmigración. Pero la resolución constitucional requiere algo más que preferencias políticas. Requiere una aplicación judicial significativa de los límites constitucionales y legales al Poder Ejecutivo.

El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema reafirmó la amplia autoridad ejecutiva en materia de inmigración. Al hacerlo, redujo el alcance práctico de la revisión judicial y disminuyó la fuerza de la Cláusula de Igual Protección. Las consecuencias inmediatas recaerán sobre cientos de miles de beneficiarios del TPS y solicitantes de asilo. La consecuencia a largo plazo podría ser estructural: un sistema constitucional en el que las garantías procesales y las normas de igual protección sean cada vez más difíciles de hacer valer precisamente en el contexto en el que se necesitan con mayor urgencia. ■

La Crítica del Derecho

Año 2, Vol. 6 — junio de 2026

En este número: Adrián Federico Ambroggio, Andrés Sajó, Cass Sunstein, Catalina Finn, David Dyzenhaus, Emiliano Vitaliani, Ezequiel Kostenwein, Gianella Bardazano, Giuseppe Martinico, Gustavo Pereira, Irwin Stotzky, Mariela Puga, Martín César Giorgi, Mijhail Pavel Pardo Lafuente, Morella Riemersma, Natalia Sobrevilla Perea, Pablo Secchi, Pedro Caminos, Roberto Gargarella, Yascha Mounk.

WWW.LACRITICA.AR